การค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ

โดย

นางสาวประภัสสร ประกอบแก้ว

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554

Private place searching according to the Criminal Procedural Law Code : Comparative Study to American and English Law

By

Miss Prapassorn Pragobkaew

A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Law

Criminal Law

Faculty of Law

Thammasat University

2011

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

ของ

นางสาวประภัสสร ประกอบแก้ว

เรื่อง

การค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา :
ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(อาจารย์ ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ)

บทคัดย่อ

การค้นในที่รโหฐานเป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยเป็นมาตรการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแทรกแซงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่มีอยู่เหนือสถานที่ซึ่งเขามีเจตนาหวงกันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในฐานะที่มาของอำนาจดังกล่าวจึงต้องสร้างหลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจรัฐที่มีความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและการแสวงหาผู้กระทำความผิดและพยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกับหลักการค้นสถานที่ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเพื่อให้ทราบถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์การค้นที่รโหฐานของกฎหมายทั้งสามประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียเพื่อเสนอแนะแนวทางที่ทำให้การใช้อำนาจค้นในที่รโหฐานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ผลการศึกษา พบว่าหลักกฎหมายของทั้งสามประเทศมีหลักเกณฑ์พื้นฐานในการค้นที่รโหฐานที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ การค้นที่รโหฐานจะต้องกระทำโดยอาศัยหมายค้นที่ออกโดยศาลเป็นหลัก เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดซึ่งได้แก่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคคล ป้องกันการหลบหนี หรือป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐาน และหากเจ้าพนักงานไม่มีหมายในการค้นหรือค้นโดยไม่มีเหตุที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นจะส่งผลให้เป็นการค้นโดยไม่มีอำนาจซึ่งศาลอาจไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้จากการค้นนั้น

อย่างไรก็ดี ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษมีการกำหนดหลักเกณฑ์บางประการที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย กล่าวคือ มีมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่กำหนดการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานอย่างรัดกุม ได้แก่ การพิจารณาความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่รัฐจะได้รับกับผลกระทบต่อบุคคล เช่น การพิจารณาความรุนแรงของการกระทำความผิดในการออกหมายค้นและการค้นโดยไม่มีหมายตามกฎหมายอังกฤษ ซึ่งทำให้เจ้าพนักงานไม่สามารถใช้อำนาจค้นที่รโหฐานได้ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ รวมทั้งการจำกัดขอบเขตในการค้นตามหลักการค้นต้องเฉพาะเจาะจงซึ่งทำให้หมายค้นจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะทำการค้น และสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการพบให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ รวมทั้งมีเงื่อนไขในการจำกัดการใช้ดุลยพินิจในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเนื่องจากความฉุกเฉิน โดยเฉพาะกรณีการค้นเพื่อ

ป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานสามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ โดยมีข้อที่จะต้องพิจารณาว่า พยานหลักฐานที่ต้องการค้นเป็นพยานหลักฐานในความผิดที่ร้ายแรงได้สัดส่วนกับการใช้มาตรการค้นโดยไม่มีหมาย บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นมีเหตุที่จะล่วงรู้ได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจพบการกระทำความผิดของเขาแล้ว และการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานนั้นไม่ได้เป็นผลจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงาน

นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษยังมีมาตรการที่ทำให้การค้นที่รโหฐานมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การให้อำนาจเจ้าพนักงานทำการค้นโดยไม่มีหมายค้นเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในสถานที่ที่มีการจับกุมหรือสถานที่ที่ผู้ถูกจับกุมครอบครองได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น เพื่อป้องกันอันตรายแก่เจ้าพนักงานและบุคคลอื่นหรือป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐาน ซึ่งตามมาตรา 85 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยยังคงมีข้อจำกัดให้ค้นได้เพียง “ตัวบุคคล” ที่ถูกจับกุมเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ ศาลและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมของไทยควรนำแนวทางการค้นในที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะหลักความได้สัดส่วนในการใช้อำนาจค้น อันประกอบด้วย การเลือกใช้มาตรการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการค้น โดยไม่มีมาตรการที่ผ่อนผันหรือร้ายแรงน้อยกว่า อีกทั้งมาตรการค้นที่รโหฐานต้องเกิดผลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดมากกว่าโทษที่จะเกิดต่อบุคคล รวมทั้งอาจนำแนวทางการจำกัดดุลยพินิจของเจ้าพนักงานในการค้นที่รโหฐานเพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานมาประกอบการใช้อำนาจตามมาตรา 92 (4) นอกจากนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจค้นหาพยานหลักฐานสืบเนื่องจากการจับกุมได้เช่นเดียวกับหลักสากล จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 85 เพื่อให้เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นที่รโหฐานในบริเวณรอบๆ ตัวผู้ถูกจับกุมได้เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นในที่รโหฐานมีมาตรการคุ้มครองสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยไม่ได้เป็นภาระแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจนเกินสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Abstract

Private place searching is an important measure in acquiring persons or objects relating to the offence committal as the measure for controlling the public officer's exercising of power in interfering the private right and the property right of person over the place where other persons are barred from being involved without permission. For this reason, the criminal procedural law code, as the source of such power, must create the standard in effectively exercising the public power with the balance between the personal right protection and the seeking of offenders and evidences. This thesis is the study in comparison of the principle of law concerning the private place searching according to Thailand's Criminal Procedural Law Code and the place searching principle according to the U.S. and UK laws to know about the similarities and the differences of rules for the private place searching of the three countries' laws which shall lead to the analysis of advantages and disadvantages in order to provide the recommendation and guidelines for achieving the exercise of private place searching power.

The result of the study found that all three countries' principle of laws have the similar basic rules in searching the private place. That is to say, the private place searching must be mainly done by way of search warrant issued by the court, except as required by law in the cases of, for examples, emergency for personal protection, guarding against the flight or preventing the evidences from being removed or destroyed and in case the authority has no search warrant or the search is made without reasonable cause as required by law, such search would be considered as unauthorized search that might not be accepted as evidence by the court.

In the United States and England, however, some rules have been determined differently from Thailand's Code of Criminal Procedures. The measures for the individuals' right and freedom protection require the thorough controlling of authority's exercise of power, for instance, the consideration of ratio between the interest received by the state or government and the personal affects, the consideration of offence severity in issuing the search warrant and the search made without warrant as required by English law, causing the authority to unable to exercise the power for the search of private place for the minor offences, as well as the restraint of search, according to the principle, must specifically indicate the details of the place to be searched and the object or person most wanted to be seen as much as possible,

including the conditions in limiting the use of discretion in searching the private place without search warrant due to the emergency, particularly for the search to prevent the evidences from being removed or destroyed and the discretion can be extensively used by the authority. There is, however, the matter to be considered that the evidence needed to be searched is the evidence for the severe offence proportioned to the use of searching measure without warrant. The person in that place has the reason to know that the police officer has detected his offence committal and the removal or destruction of evidence is not the result of intentional or gross negligent conduct of the authority.

In addition, in the United States and England, there are measures for the effective search of private place, for example, providing power to the authority to make the search without warrant to seek for the evidences in the place where the arrest is made or in the place occupied by the arrested person without search warrant in order to prevent the authority and other persons from being harmed or to prevent the evidence from being removed or destroyed in which, according to Thailand's Code of Criminal Procedures, Section 85, the search is restricted to be made only against the arrested "individual".

Recommendation - The court and authorities in the judicial process should follow and adopt the guidelines in searching the private place as required by the U.S. and English law, specifically for the principle of proportion in exercising the searching power which consists of choosing to use the measure that can achieve the search objective without any relaxed measure or less severity. Furthermore, the private search measure must be more effective for the prevention and suppression of the offence committal than penalty against the individuals. The guidelines for limiting the authority's discretion in searching the private place is also applied to prevent the removal and destruction of evidences as in Section 92 (4). In addition, to enable the authority to exercise the power in searching evidence due to the arrest in the same taken as in international standard, Section 85 should be amended to permit the authority to have power to search the private place at the surrounding area of the arrested person in the same way as in the United States of America and in England and to allow the right to search the private place to be protected as required in the constitution without burden to the authority and is beneficial to the provision of justice with speed and effectiveness.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ที่กรุณาสละเวลารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ท่านอาจารย์ ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละและได้ให้คำแนะนำรวมถึงชี้แนะข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ที่กรุณาสละเวลารับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ตรวจแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้เขียนเป็นอย่างดียิ่งจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณท่านอื่นๆ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คอยชี้แนะ และให้กำลังใจแก่ผู้เขียนเรื่อยมา

ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คุณยาย ที่ได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้โอกาสและกำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วง

ส่วนดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

นางสาวประภัสสร ประกอบแก้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2554

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... (1)

กิตติกรรมประกาศ..... (5)

บทที่

1. บทนำ 1

1.1 ข้อความทั่วไป..... 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4
1.3 วิธีการศึกษา 4
1.4 สมมุติฐานในการศึกษา..... 5
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5

2. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากกระบวนการค้น
และยึดในที่รโหฐาน 6

2.1 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน..... 6
2.1.1 สิทธิในความเป็นส่วนตัว 10
2.1.2 สิทธิในทรัพย์สิน..... 13
2.2 ภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล 16
2.3 ความสำคัญของการค้นในที่รโหฐาน
ต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 19
2.4 แนวคิดในการกำหนดกรอบการค้นในที่รโหฐาน..... 21
2.4.1 ทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา..... 21
2.4.2 หลักการจำกัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่..... 23

3. หลักการค้นในที่รโหฐานตามกฎหมายไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา
และกฎหมายอังกฤษ..... 26

3.1 ความหมายของการค้นในที่รโหฐาน..... 26
3.1.1 ความหมายของ “การค้น” 26
3.1.2 ความหมายของ “ที่รโหฐาน” 28
3.2 หลักการค้นที่รโหฐานโดยมีหมายค้น..... 37
3.2.1 เหตุในการออกหมายค้น..... 37
3.2.2 รายการที่ต้องระบุในหมายค้นและการบังคับตามหมาย 45
3.3 หลักการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น..... 50
3.3.1 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 50
3.3.2 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายในประเทศอังกฤษ 56
3.3.3 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายตามกฎหมายไทย..... 62
3.4 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการออกหมายค้น
และการค้นโดยไม่มีหมาย 65
3.5 วิธีการค้นที่รโหฐาน..... 70
3.5.1 ช่วงเวลาที่ทำการค้น..... 70
3.5.2 การแสดงตนในการค้น..... 77
3.5.3 หลักการแจ้งให้ทราบถึงการค้นที่รโหฐาน 78
3.6 ขอบเขตในการค้นในที่รโหฐาน 81
3.7 ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด..... 88
3.7.1 ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา..... 88
3.7.2 ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายอังกฤษ..... 95
3.7.3 ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายไทย..... 98
3.7.4 ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
ต่อความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงาน..... 108

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศ..... 124

4.1 วิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย 136
4.2 ความหมายและขอบเขตของคำว่า “การค้นในที่รโหฐาน” 139
4.3 เหตุในการออกหมายค้นที่รโหฐาน 141
4.4 เหตุในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น 143
4.5 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการออกหมายค้น
และการค้นโดยไม่มีหมาย 151
4.6 หลักการค้นต้องกระทำในเวลากลางวัน 153
4.7 การยึดสิ่งของที่ได้จากการค้นในที่รโหฐาน 156
4.8 ผลของค้นโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 160
4.8.1 ผลของการค้นที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 161
4.8.2 ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
ในกรณีที่เจ้าพนักงานมีความสุจริต 163

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 166

5.1 บทสรุป 166
5.2 ข้อเสนอแนะ 170

บรรณานุกรม 173

ประวัติการศึกษา 180

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ข้อความทั่วไป

สิทธิของบุคคลสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในเคหสถาน หรือสิทธิในทรัพย์สินต่างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย แต่สิทธิดังกล่าวก็ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดที่รัฐไม่อาจจำกัดตัดรอนได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศทั่วโลกต่างมีบทบัญญัติทั้งในส่วนที่เป็นการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิดังกล่าวและบทบัญญัติในส่วนที่ให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิดังกล่าวในบางกรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับกระบวนการยุติธรรมที่มีขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิอื่นๆ ของบุคคลทั่วไปแล้ว ย่อมจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวผู้กระทำความผิดและพยานหลักฐาน หนึ่งในนั้นคือมาตรการค้นในที่รโหฐาน ซึ่งในกรณีที่รัฐคาดได้ว่าจะพบตัวผู้กระทำความผิดหรือพยานหลักฐานในที่รโหฐานแล้ว สิทธิในความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่เหนือสถานที่ของบุคคลย่อมถูกจำกัดลงเพื่อให้กระบวนการแสวงหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษสัมฤทธิ์ผล

อย่างไรก็ตาม รัฐไม่อาจจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยไม่มีขอบเขต ดังที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนแนวคำพิพากษาของประเทศทั้งในระบบคอมมอนลอว์และประเทศในระบบซีวิลลอว์ ได้สร้างหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจรัฐในการค้นในที่รโหฐานต้องถือปฏิบัติ และสร้างมาตรการลงโทษการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวโดยการไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น ตลอดจนสร้างมาตรการลงโทษในทางอาญาเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน

สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[1] และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธศักราช 2550[2] ต่างบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลไว้สอดคล้องกันว่า การค้นในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาล หรือเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการค้นในที่รโหฐานไว้ในลักษณะ 4 หมวด 2 ส่วนที่ 1 หลักทั่วไป และส่วนที่ 2 หมายค้น รวมถึงในลักษณะ 5

---

[1]ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 238

[2]ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 33

หมวด 2 การค้น ทั้งนี้ หลักการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น มีความมุ่งหมายที่สำคัญสองประการ กล่าวคือ การกำหนดกระบวนการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น การกำหนดมาตรการในการค้นในที่รโหฐานที่ดีจึงต้องมีความสมดุลย์ระหว่างการปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลในเคหสถานแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ทำให้กระบวนการแสวงหาตัวผู้กระทำความผิดและพยานหลักฐานไม่อาจเป็นไปได้หรือเป็นไปโดยล่าช้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักการค้นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยแล้ว

จะเห็นได้ว่ามีการใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานนับแต่พุทธศักราช 2478 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล็กน้อยในบางประเด็น ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจในการออกหมาย การเพิ่มประเภทของพยานหลักฐานที่เป็นเหตุการค้นโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 (4) ให้ครอบคลุมถึงสิ่งของที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดโดยให้มีการส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้น บัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น และบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ ในขณะที่มาตรา 92 ซึ่งเป็นเรื่องการกำหนดให้เจ้าพนักงานเข้าค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเปิดช่องให้เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้เองอย่างกว้างขวาง ซึ่งต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายใกล้เคียงกับข้อยกเว้นตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอย่างมาก แต่โดยที่แนวคำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ในการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

ดังนั้น กรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่จึงมีอย่างจำกัดและถูกควบคุมจากศาลอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การค้นโดยไม่มีหมายตามหลัก Exigent circumstance ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรา 92 (1) และ (4) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การค้นโดยไม่มีหมายต้องเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายต่อตัวเจ้าพนักงานเองหรือบุคคลอื่น หรือเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานโดยที่ความฉุกเฉินนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าพนักงาน และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานอยู่บนพื้นฐานของหลักความได้สัดส่วน กล่าวคือ การค้นโดยไม่มีหมายเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในความผิดเล็กน้อยแล้ว การค้นโดยไม่มีหมายในกรณีเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานได้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น การกำหนดให้หมายค้นจะออกได้เมื่อเป็นการค้นเนื่องจากมีการกระทำความผิดร้ายแรงระดับ Indictable only offences หรือ Either-way offences ตามกฎหมายอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ศาลและฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษไม่ได้สร้างมาตรการในการค้นในที่รโหฐานโดยมุ่งพิจารณาในแง่การจำกัดดุลยพินิจของเจ้าพนักงานเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงลักษณะของการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่อสร้างมาตรการที่ทำให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองจนเกินควร เช่น การสร้างหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อยกเว้นของหลักการค้นต้องจำกัดสิ่งที่ค้น ในกรณีที่พบพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในหมายโดยที่พยานหลักฐานชิ้นนั้นเห็นได้ประจักษ์ชัดว่าเป็นสิ่งของที่ได้จากการกระทำความผิด เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจยึดพยานหลักฐานนั้นๆ เพื่อใช้พิสูจน์ความผิดได้ต่อไป ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับการดำเนินคดีในปัจจุบันที่ความผิดสามารถเชื่อมโยงถึงกันในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมหรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

แต่ตามมาตรา 98 (1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้คนมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย” นั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำการยึดพยานหลักฐานหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้ต่อเมื่อมีหมายค้นที่ระบุให้ค้นโดยไม่จำกัดสิ่งและเฉพาะในคดีที่ออกหมายค้นนั้นหรือไม่ หรือแม้แต่กรณีตามมาตรา 92 (3) ซึ่งกำหนดว่าการค้นโดยไม่มีหมายกระทำได้เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปในที่รโหฐาน ซึ่งตามหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกา กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด หรือ Hot pursuit ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ที่การไล่ติดตามผู้ที่หลบหนี ดังนั้น จึงไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นการหลบหนีของผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าเท่านั้น แต่รวมถึงกรณีการค้นที่รโหฐานต่อเนื่องจากการไล่ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับหรือผู้ต้องหาตามคำให้การของผู้เสียหายด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ทำให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เจ้าพนักงานเข้าทำการค้นที่รโหฐานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ครอบครองสถานที่ทราบถึงการค้นนั้น เรียกว่า Delayed notice search ซึ่งใช้กับการกระทำความผิดที่ต้องการสืบสวนให้ถึงตัวผู้กระทำความผิดรายใหญ่ในองค์กรอาชญากรรมโดยไม่ให้ผู้กระทำความผิดรู้ตัวเสียก่อน เป็นต้น

จากที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้นจึงเห็นได้ว่า หากพิจารณาเปรียบเทียบหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทยแล้ว บทบัญญัติในเรื่องการค้นในบางมาตราของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการ หรือมาตรการเสริมที่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและเป็นการสนับสนุนให้กระบวนการค้นหาพยานหลักฐานและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษโดยละเอียดจะทำให้เข้าใจถึงที่มาและความแตกต่างของหลักกฎหมายในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาหลักกฎหมายไทยต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเรื่องการค้นในที่รโหฐาน

2. เพื่อศึกษาที่มา แนวคิด หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาศาลเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อต่างของหลักกฎหมายในเรื่องการค้นในที่รโหฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ

4. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของหลักกฎหมายไทยและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้มีความเหมาะสมต่อไป

1.3 วิธีการศึกษา

ผู้เขียนจะทำการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) จากตำรา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติกฎหมาย ตลอดจนแนวคำพิพากษาของศาลไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน

1.4 สมมุติฐานการศึกษา

โดยที่การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนของการค้นในที่รโหฐานจะต้องคำนึงถึงทั้งหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเคหสถานและการแสวงหาตัวผู้กระทำความผิดและพยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ แต่การค้นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในบางมาตรายังไม่มีความชัดเจน ทำให้กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่มีกรอบในการกำหนดดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงทำให้ขาดความชัดเจนในบางเรื่องเจ้าพนักงานก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้

1.5 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาที่มา แนวคิด และหลักกฎหมายในเรื่องการค้นในที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษ โดยเฉพาะการศึกษาบทบัญญัติและแนวคำพิพากษาต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับหลักการค้นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือมาตรการที่ทำให้การค้นที่รโหฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องการค้นในที่รโหฐาน

2. เพื่อทราบที่มา แนวคิด หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาศาลเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ

3. เพื่อให้ทราบข้อดีและข้อเสียของหลักกฎหมายไทยและต่างประเทศซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักการค้นในที่รโหฐานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย

บทที่ 2

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากกระบวนการค้นในที่รโหฐาน

ในบทนี้จะเป็นการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้นในที่รโหฐาน โดยจะได้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์และความสำคัญของการค้นในที่รโหฐานกับความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีดังกล่าว ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางการกำหนดกรอบในการค้นทั้งในแง่ของการถ่วงดุลย์ระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด และในแง่ของหลักทั่วไปในการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบกระบวนการค้นในที่รโหฐานตามกฎหมายไทยและต่างประเทศในบทต่อไป

2.1 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน

แนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีที่มาจากหลักการที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และบุคคลทุกคนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ ตลอดจนปกครองดูแลตัวเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมมีความจำเป็นที่ต้องสร้างหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขโดยไม่ล่วงล้ำก้าวก่ายซึ่งกันและกัน นั่นคือการกำหนดขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่า “สิทธิและเสรีภาพของบุคคล” โดยสิทธิ (Right) เป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทำการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น[1] ในขณะที่เสรีภาพ (Liberty) เป็นอำนาจในการกำหนดตนเอง (Self – determination) สิทธิและเสรีภาพจึงมีความแตกต่างในสาระสำคัญตรงที่สิทธิเป็นอำนาจที่ใช้ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เกิดประโยชน์แก่ตน แต่เสรีภาพเป็นอำนาจของ

---

[1]จิรนิติ หะวานนท์, สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2544), น. 14.

บุคคลในอันที่จะกระทำในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระทำและที่จะไม่กระทำในสิ่งที่ตนไม่ประสงค์กระทำ และการมีอำนาจดังกล่าวมีผลเพียงเป็นการก่อหน้าที่ที่จะต้องละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้เสรีภาพของเขาเท่านั้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการใช้คำว่าสิทธิและเสรีภาพรวมๆ กันไป โดยเรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์แต่ละคนพึงมีในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ว่า “สิทธิมนุษยชน” หรือ”สิทธิขั้นพื้นฐาน” อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวหาใช่อำนาจของบุคคลที่จะเรียกร้องให้รัฐกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตนไม่ แต่เป็น “สิทธิในเสรีภาพ” (Right of Liberty) ซึ่งเป็นอำนาจตามกฎหมายในอันที่บุคคลจะกระทำการต่างๆ โดยปราศจากการรบรวนขัดขวางของรัฐ[2]

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในความหมายของสิทธิของมนุษยชนเป็นการจำแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพโดยคำนึงถึงการกำเนิดของสิทธิ กล่าวคือเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด จึงแตกต่างจากสิทธิพลเมืองที่เกิดจากการเป็นสมาชิกของรัฐใดรัฐหนึ่ง สิทธิมนุษยชนนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สิทธิในครอบครัว สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ฯลฯ

เสรีภาพทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น เช่น เสรีภาพในการถือศาสนานิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ

สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการทำสัญญาก่อตั้งนิติสัมพันธ์กับผู้อื่น ฯลฯ

สำหรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ซึ่งเรียกว่า “ที่รโหฐาน” นั้น แม้จะไม่ใช่สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรองรับไว้โดยตรงในกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกับสิทธิในเคหสถานที่ได้รับการรับรองโดยข้อ 12 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal

---

[2]วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2543), น. 22-23.

Declaration of Human Rights)[3] และข้อ 17 ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant On Civil and Political Rights)[4] ที่ระบุไว้โดยสอดคล้องกันว่า การเข้าไปแทรกแซงโดยพลการในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการลบหลู่ชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคลจะทำมิได้ และบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการแทรกแซงและลบหลู่ดังกล่าว โดยมาตรา 2 (13) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้บัญญัติว่า “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดั่งบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา ในขณะที่มาตรา 1 (3) ของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า “สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ คำว่า “ที่รโหฐาน” จึงหมายถึงสถานที่ที่บุคคลมีอำนาจหวงกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งมีความหมายแตกต่างจาก “เคหสถาน” (home) อันเป็นสถานที่ที่บุคคลใช้ในการอยู่อาศัย โดยที่รโหฐานย่อมรวมถึงเคหสถานใดๆ ที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองมิได้ประสงค์บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สอยได้ดังที่สาธารณสถานด้วย

อย่างไรก็ตาม สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานนี้ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ทุกประเทศต่างให้การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันแก่ประชาชนในรัฐว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งที่เป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรม

---

[3] Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

[4] Article 17

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

ทางอาญาโดยไม่มีเหตุผลหรือโดยไม่จำเป็น ดังที่ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้...”

เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ (The Fourth Amendment) ที่ได้สร้างหลักการเพื่อเป็นการรับรองว่า สิทธิของประชาชนในอันที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย เคหสถาน และเอกสารจากการค้นและยึดโดยไม่มีเหตุอันควรจะถูกล่วงละเมิดมิได้[5] ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้บทบัญญัติดังกล่าวจะกล่าวถึง “เคหสถาน” (houses) แต่นักกฎหมายและศาลของสหรัฐอเมริกาก็ได้ยึดถือเป็นหลักตลอดมาว่า The Fourth Amendment เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในสถานที่ที่บุคคลนั้นมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในที่รโหฐาน โดยไม่ได้จำกัดว่าเป็นการให้ความคุ้มครองเฉพาะสถานที่ที่บุคคลใช้อยู่อาศัยเท่านั้น[6] ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในประเทศอังกฤษ ในการใช้อำนาจสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจตาม The Police and Criminal Evidence Act 1984 ที่ระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน

---

[5] The Fourth Amendment

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

[6] The U.S. Government Printing Office, “4th Amendment US Constitution-Search and Seizure,” pp. 1205-1206, < www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con015 .pdf>.

(Search of premise) และได้ให้ความหมายของ “premise” ว่า สถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยให้รวมถึงยานพาหนะ หรือสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น เต็นท์[7] ด้วย

จึงอาจกล่าวได้ว่า การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานครอบคลุมพื้นที่ใดๆ ที่อยู่ภายใต้การหวงกันของบุคคลในอันที่จะป้องกันหรือต่อสู้ขัดขวางมิให้บุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซง ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นเคหสถานหรือไม่ก็ตาม แต่เนื่องจาก “ที่รโหฐาน” เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของบุคคล ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับที่รโหฐานซึ่งได้รับการคุ้มครองจากการใช้อำนาจของรัฐนี้จึงประกอบด้วยสิทธิที่สำคัญสองประการ นั่นคือ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในทรัพย์สิน[8] ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้

2.1.1 **สิทธิในความเป็นส่วนตัว** (The Right to Privacy)

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกิดจากแนวคิดทางปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่สำคัญหลายแนวคิดประกอบกัน เช่น แนวความคิดมนุษย์นิยม แนวความคิดเสรีนิยม แนวความคิดปัจเจกชนนิยม และทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตย โดยมีหลักการว่า ความเป็นส่วนตัวเป็น “คุณค่า” ประจำตัวมนุษย์ โดยมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีวิถีชีวิตตามธรรมชาติแบ่งได้เป็นสองส่วน กล่าวคือ

1. ส่วนที่เป็นชีวิตสาธารณะ (Public Life) คือ การดำเนินชีวิตที่ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสาธารณชน

---

[7] 23. Meaning of “premises”

In this Act—

“premises” includes any place and, in particular, includes—

(a) any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft;

(b) any offshore installation;

(ba) any renewable energy installation;

(c) any tent or movable structure; ...

[8]Vinesh Basdeo, “A Constitutional Perspective of Police Powers of Search and Seizure in the Criminal Justice System,” (Master ‘s thesis University of South Africa, 2009), pp. 31-32.

2. ส่วนที่เป็นชีวิตส่วนตัว (Private Life) คือ การดำเนินชีวิตด้วยตนเอง เป็นชีวิตส่วนที่แยกออกจากสังคมหรือจากผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกชีวิตส่วนตัวและสาธารณะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังแปรผันไปตามสมัยนิยมและแนวความคิดว่าด้วยศีลธรรมอันดีในแต่ละยุคสมัย โดยนักวิชาการได้พยายามให้ความหมายของขอบเขตความเป็นส่วนตัวไว้ดังนี้

Alan F. Westin อธิบายว่า ขอบเขตส่วนตัว สามารถพิจารณาได้ในแง่มุมที่ต่างกันสามประการคือ

1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่อย่างสันโดษ ซึ่งเป็นมุมมองในทางกายภาพ กล่าวคือเป็นการจำกัดการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก

2. เกี่ยวกับความลับเฉพาะตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถรู้และเห็นได้เฉพาะบุคคล บุคคลภายนอกหรือสาธารณชนไม่สามารถเข้าร่วมรู้เห็นได้

3. การมีอิสระในการกำหนดตนเอง บุคคลมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของตน การมีชีวิตที่เป็นอิสระปราศจากการควบคุมโดยรัฐ[9]

Samuel D. Warren และ Louis D. Brandeis อธิบายการพิจารณาขอบเขตความเป็นส่วนตัวว่า สามารถพิจารณาได้สองด้าน

1. ความเป็นส่วนตัวในทางนามธรรม คือ การที่บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงอารมณ์และความรู้สึก เสรีภาพในทางความคิด เสรีภาพในการเชื่อถือศรัทธาในลัทธิของศาสนา

2. ความเป็นส่วนตัวในทางรูปธรรมหรือทางกายภาพ คือ การอยู่โดยลำพังปราศจากการรบกวน กล่าวคือ เป็นสถานะที่บุคคลจะรอดพ้นจากการสังเกต การรู้เห็น การสืบความลับ การรบกวนต่างๆ และปราศจากการแทรกแซงจากสังคม[10]

Warren และ Brandeis อธิบายว่าการอยู่อย่างสันโดษไม่ติดต่อสัมพันธ์กับสังคมเป็นขอบเขตที่บุคคลควรได้รับการเคารพและได้รับการคุ้มครองเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลิกลักษณะ

---

[9]David H. Flaherty, Privacy Edition, Privacy and Data Protection : An International Bibliodraphy, (NewYork : Knowledge Industry Publication Inc, 1984), p.14 อ้างในศิริกุล ภู่พันธ์ “ข้อความคิดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) น. 31.

[10]วรวิทย์ ฤทธิทิศ, “สื่อมวลชนกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิในชีวิตส่วนตัว,” ดุลยพาห, เล่มที่ 4, ปีที่ 39, น. 82 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2535).

ตามที่ต้องการ และมีสิทธิแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิธีทางที่อาจเป็นไปได้และเป็นความพอใจตราบเท่าที่ความสนุกนั้นไม่ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่นหรือสาธารณะ[11]

สำหรับความหมายของพื้นที่สาธารณะ Hannah Arendt ได้อธิบายว่า

1. เป็นพื้นที่ที่ทุกอย่างสามารถเปิดเผยได้ เป็นที่ที่ทุกอย่างสามารถปรากฏแก่สายตาของทุกคน สามารถได้ยิน ได้ฟัง และเป็นสิ่งที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง

2. เป็นที่ที่บุคคลดำเนินชีวิตในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนคนอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้แย้ง พูดคุยถึงความแตกต่างเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในสิ่งที่สังคมให้ความสนใจหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมได้

ในทางตรงข้ามพื้นที่ส่วนตัวคือ พื้นที่ที่มีลักษณะตรงข้ามหรือส่วนที่แยกตัวออกจากพื้นที่สาธารณะ และลักษณะทั้งสองประการที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในพื้นที่ส่วนตัว[12]

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับกันว่า สิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิที่จะปลอดจากการเข้าถึงหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในเรื่องส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสาธารณชนไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวหรือปลอดจากการละเมิดอันมิชอบต่อกิจกรรมส่วนตัวของบุคคลซึ่งเป็นการทำลายหรือเป็นมูลเหตุให้ได้รับความอับอายตามความรู้สึกของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังหมายถึงสิทธิที่จะอยู่โดยลำพัง

จากคำอธิบายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สิทธิในความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยความเป็นส่วนตัวของบุคคลในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยความเป็นส่วนตัวในทางนามธรรม ได้แก่ สิทธิในความเชื่อ ความคิด การแสดงออก รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิที่เป็นเรื่องของรูปธรรมหรือกายภาพ ซึ่งได้แก่ ความเป็นส่วนตัวเหนือเนื้อตัวร่างกาย (privacy in one 's body) และความเป็นส่วนตัวเหนือพื้นที่ส่วนบุคคล (privacy in one 's personal space)

ความเป็นส่วนตัวเหนือพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นอำนาจของบุคคลในการกำหนดการเข้าถึงสถานที่ที่เป็นที่ส่วนตัว (the right to control access to one 's personal space) ซึ่งการพิจารณาว่าบุคคลมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเหนือพื้นที่หรือไม่นั้น พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า

---

[11]Maurizio Passerrin d' Entréves and Ursula Vogel Editor, Public and Pravate : Legal, political and philosophical perspectives, (New York : Routledge, 2000), p.52 อ้างในศิริกุล ภู่พันธ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9*, น. 34-35.

[12]ชูชีพ ปิณฑะศิริ, "การละเมิดสิทธิส่วนตัว," (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), น. 3.

ในพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆ บุคคลมีเหตุสมควรที่จะคาดหวังในสิทธิความเป็นส่วนตัว (reasonable expectation of privacy) หรือไม่ ซึ่งหากเป็นสถานที่ที่บุคคลมีความคาดหวังดังกล่าวแล้ว แม้สถานที่นั้นจะไม่ใช่ที่อยู่อาศัย บุคคลก็ย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว และมีอำนาจห้ามมิให้มีการรบกวนการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์โดยลำพังในสถานที่นั้น ซึ่งแน่นอนว่าในทางตรงกันข้าม หากเป็นสถานที่ที่ยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง มองเห็น หรือได้ยินแล้ว แม้จะเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บริเวณบ้านที่ดัดแปลงเป็นร้านค้า บุคคลที่อยู่ในนั้นก็ไม่มีสิทธิในความเป็นส่วนตัวเหนือพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด

2.1.2 **สิทธิในทรัพย์สิน** (The Right to Private Properties)

สิทธิในทรัพย์สินมีความเกี่ยวพันกับการค้นในที่รโหฐานทั้งในแง่ที่การค้นเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์ในที่รโหฐานซึ่งเป็นทรัพย์สินของบุคคลอย่างปกติสุข และในแง่ที่การค้นนำไปสู่การยึดทรัพย์สินในที่รโหฐานซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยตรง ในส่วนนี้จึงขอกล่าวถึงสิทธิในทางทรัพย์สินที่สำคัญ 2 ประเภท ได้แก่ กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการจำกัดสิทธิของบุคคลในกระบวนการค้นในที่รโหฐาน ดังนี้

(1) กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์เป็นอำนาจที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สินที่เป็นวัตถุมีรูปร่างซึ่งสามารถใช้ยันได้กับคนทั่วไป และประกอบด้วยสิทธิย่อยๆ ดังนี้[13]

1. สิทธิในการใช้สอยทรัพย์สิน หมายถึงอำนาจที่จะทำประโยชน์ ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามความต้องการโดยไม่เป็นการทำลายภาวะแห่งทรัพย์สินนั้น เช่น เจ้าของบ้านเรือนมีสิทธิที่จะอาศัยในอาคารบ้านเรือนนั้น หรือใช้ทำประโยชน์อื่นใด

2. สิทธิที่จะได้ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ รวมถึงผลผลิตทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากทรัพย์สินนั้น

3. สิทธิในการจำหน่ายทรัพย์สิน สิทธิในการจำหน่ายนี้มิได้จำกัดเฉพาะการจำหน่ายจ่ายโอน หรือขายให้คนอื่นไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจำหน่ายทำลายภาวะ เช่น การรื้อถอน

---

[13] วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551), น. 123-128.

ทำลายบ้านเรือนที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งประการใดอันเป็นสาระสำคัญในตัวทรัพย์สินนั้น เช่น เอาข้าวมาผลิตเป็นสุรา เป็นต้น

4. สิทธิในการติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล แต่ต้องเป็นการติดตามเอาคืนจากผู้ที่ยึดถืออยู่เท่านั้นและเป็นกรณีที่ผู้อื่นไม่ได้โต้แย้งสิทธินั้นอยู่ หากบุคคลอื่นโต้แย้งว่าตนมีสิทธิจะยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้โดยชอบ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่อาจแย่งเอาคืนซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยพลการ

5. สิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของจะมีสิทธิขัดขวางต่อเมื่อได้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ และการป้องกันขัดขวางนี้ย่อมกระทำได้โดยพละกำลังของตนโดยพลการถ้าได้กระทำลงพอสมควรแก่เหตุและไม่ได้ใช้กำลังเกินความจำเป็นในอันที่จะป้องกันขัดขวางแล้ว แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นย่อมไม่ต้องมีความรับผิดทางแพ่งและอาญา

(2) สิทธิครอบครอง

สิทธิครอบครองเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่ผู้ครอบครอง จึงเป็นสิทธิที่ผูกพันอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ย่อมมีสิทธิครอบครอง ต่างจากกรรมสิทธิ์ที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องครอบครองทรัพย์แต่เป็นสิทธิอันได้มาตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ แม้ทรัพย์นั้นได้มาโดยการกระทำความผิด ผู้ครอบครองทรัพย์โดยผลของการกระทำความผิดนั้นก็ยังคงได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เหตผลก็คือเพื่อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยในสังคมและป้องกันการกระทำความผิดในทำนองเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก การใช้กำลังโดยพลการเพื่อแย่งเอาการครอบครองคืนจึงกระทำมิได้[14]

ผู้มีสิทธิครอบครองย่อมได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายในการใช้สิทธิป้องกันตัว ซึ่งหมายความว่า ผู้ครอบครองมีอำนาจที่จะป้องกันการครอบครองของตนต่อการละเมิดที่ผิดกฎหมายโดยการใช้กำลังได้ และสามารถใช้กำลังแย่งการครอบครองคืนมาได้หากได้กระทำไปในขณะที่มีการกระทำละเมิดกฎหมายหรือในการที่ได้ติดตามไปทันทีที่ได้มีการกระทำละเมิดกฎหมายเช่นนั้น แต่หากผู้กระทำละเมิดต่อกฎหมายแย่งการครอบครองสำเร็จแล้ว ผู้ที่ถูกแย่งการครอบครองมีสิทธิเพียงการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง เช่นเดียวกับการขจัดการรบกวนการครอบครอง ที่หากบุคคลอื่นทำให้ผู้ครอบครองได้รับความเดือดร้อนเกินกว่าปกติ ถือว่าเป็นการรบกวนการครอบครองแล้ว แต่การใช้สิทธิดังกล่าวต้องฟ้องต่อศาล

---

[14] *เพิ่งอ้าง*, น. 59-60.

ในกรณีของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น บุคคลที่ครอบครองดูแลเคหสถานหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งย่อมมีสิทธิครอบครองใช้สอยสถานที่นั้นและมีสิทธิครอบครองครอบไปถึงทรัพย์สินอื่น เช่น ข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่นั้นทั้งที่เป็นของตนเป็นของบุคคลอื่น หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งอาจเป็นการยึดถือเพื่อตนเองหรือยึดถือแทนบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี แต่เมื่อทรัพย์สินนั้นอยู่ในเคหสถานที่เขาครอบครองแล้ว บุคคลดังกล่าวย่อมได้รับการสันนิษฐานโดยกฎหมายว่ามีเจตนายึดถือทรัพย์ทุกอย่างในสถานที่นั้นและมีสิทธิครอบครองในทรัพย์ ดังนั้น ผู้ครอบครองย่อมมีสิทธิป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้อำนาจโดยพลการเข้ามาแย่งชิงหรือพรากทรัพย์นั้นไปได้

จากที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่า ในขณะที่บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัวที่จะอยู่ตามลำพังในเคหสถานหรือที่รโหฐานโดยปราศจากการรู้เห็นแทรกแซงของบุคคลภายนอก แต่ในขณะเดียวกันบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต่างก็มีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินและป้องกันขัดขวางมิให้บุคคลอื่นเข้ามาหรือรบกวนการใช้สอยสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่อยู่ภายในสถานที่นั้น การเข้าไปในที่รโหฐานไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยมิได้รับความยินยอมหรือไม่มีเหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมายจึงเป็นการละเมิดทั้งต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินในส่วนของสิทธิที่จะครอบครองใช้สอยทรัพย์สินนั้น และยิ่งการเข้าไปนั้นเพื่อยึดทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยแล้วย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองโดยตรง

ด้วยเหตุนี้ สิทธิของบุคคลในที่รโหฐานจึงประกอบด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งสิทธิในที่รโหฐานนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิในเคหสถาน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือ<u>การตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน</u> จะกระทำมิได้...” กล่าวคือ สิทธิในเคหสถานก็ประกอบไปด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวเหนือเคหสถาน และสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นตัวเคหสถานและสิ่งของต่างๆ ในเคหสถานนั้น เพียงแต่สิทธิและเสรีภาพในเคหสถานเป็นสิทธิพื้นฐานของบุคคลและสิทธิแรกเริ่มที่ได้รับการสันนิษฐานและคุ้มครองโดยกฎหมาย เนื่องจากเคหสถานเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในฐานะปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งต่อมาการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้ขยายออกไปยังสถานที่อื่นๆ หรือที่รโหฐาน ซึ่งส่งผลให้สิทธิในที่รโหฐานมีความหมายกว้างและคลอบคลุมถึงสิทธิในเคหสถาน

2.2. ภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

แม้ว่าบุคคลทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็มีหน้าที่เคารพสิทธิของบุคคลอื่นด้วย ดังนั้น จึงต้องไม่ใช้สิทธิของตนไปล่วงละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น หรืออาจเรียกว่าข้อจำกัดสิทธิของบุคคลเพื่อประโยชน์ของเอกชนด้วยกัน ซึ่งการจำกัดสิทธิดังกล่าวมีตัวอย่างที่ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะในมาตรา 420 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” หรือมาตรา 421 ที่ว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” อย่างไรก็ตาม รัฐทุกรัฐย่อมมีภารกิจพื้นฐานที่ต้องกระทำเพื่อการดำรงอยู่ของรัฐ ทั้งที่เป็นภารกิจต่อภายนอก เช่น กิจการทหารเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ กิจการต่างประเทศ และภารกิจต่อภายใน นั่นคือทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีสันติสุขภายในชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐ หรือนัยหนึ่งรัฐต้องดำเนินการมิให้ประชาชนทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายทำลายชีวิต หรือแย่งชิงทรัพย์สินซึ่งกันและกัน รัฐจึงมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนแต่ละคนไม่ให้ถูกละเมิด[15]

แต่การรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยรัฐนั้น รัฐมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการต่างๆ ตั้งแต่ที่ร้ายแรงน้อยที่สุดคือการจำกัดเสรีภาพของบุคคล ไปจนถึงการจำกัดสิทธิเพื่อป้องกันมิให้บุคคลละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การเข้าแทรกแซงกิจการของเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อดำเนินการเสียเอง การเวนคืนทรัพย์สิน หรือแม้แต่การลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งในทางแพ่งและอาญา ซึ่งจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่การดำเนินการของรัฐจะไม่ไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่รัฐก็มีอำนาจที่จะกระทำได้เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะที่เป็นเรื่องของมหาชนและเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของเอกชนคนใดคนหนึ่ง จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดสิทธิของบุคคลหรือเข้าไปขัดขวางการใช้เสรีภาพบางประการของบุคคล ซึ่งภารกิจของรัฐอันป็นไปเพื่อประโยชน์มหาชนประการหนึ่งนั้นก็คือการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาซึ่งเป็นภารกิจของ

---

[15]สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2551), น. 128-129.

กฎหมายอาญาซึ่งประกอบด้วยภารกิจในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้[16]

(1) ภารกิจในการคุ้มครองสังคม กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม โดยธรรมชาติมนุษย์มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน เมื่อมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันจึงต้องกระทบกระทั่งกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กฎหมายอาญาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงมีความสำคัญมาก จริงอยู่ในสังคมมี “ระเบียบสังคม” อันเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความประพฤติที่มีมาแต่ดั้งเดิม แต่การใช้ระเบียบสังคมเป็นเรื่องของความสมัครใจของแต่ละบุคคลโดยปราศจากสภาพบังคับจากภายนอก ระเบียบสังคมอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสังคมจะมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาเสริม แม้ว่ากฎหมายทุกลักษณะจะมีสภาพบังคับอยู่ด้วย แต่กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีสภาพในเชิงบังคับที่รุนแรงที่สุด และหากกฎหมายอาญาไม่สามารถประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคมได้เมื่อใด สภาวะการจลาจลในบ้านเมืองก็จะเกิดตามมาเมื่อนั้น

อย่างไรก็ตาม การใช้กฎหมายอาญาเพื่อเป็นเครื่องมือคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมต้องกระทำเฉพาะเท่าที่จำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น เพราะหากกฎหมายอาญาบัญญัติขึ้นใช้อย่างพร่ำเพรื่อแล้ว สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะถูกกระทบกระเทือนจนเกินความจำเป็นอันไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย กฎหมายอาญาจึงต้องไม่เพียงแต่มุ่งจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท่านั้น แต่กฎหมายอาญาจะต้องเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย

(2) ภารกิจในการปราบปรามและในการป้องกันการกระทำความผิด กฎหมายอาญามีภารกิจในการคุ้มครองสังคมสองทาง คือในทางปราบปรามและในทางป้องกัน เมื่อการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็จะต้องใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นและการปราบปรามนั้นยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดนั้นในอนาคตด้วย แท้จริงแล้วภารกิจทั้งสองประการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการลงโทษหรือการใช้กฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทำความผิดจะต้องกระทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกต่อทั้งผู้กระทำความผิดและบุคคลทั่วไป กล่าวคือต้องกระทำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดเองเห็นว่าสังคมไม่ยอมรับการกระทำของเขา และในขณะเดียวกันต้องกระทำเพื่อเตือนบุคคลทั่วไปด้วยว่า ถ้ามีการกระทำ

---

[16]คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2551), น. 45-50.

นั้นเกิดขึ้นอีกก็จะต้องมีการลงโทษเช่นเดียวกันซึ่งจะทำให้การใช้กฎหมายอาญาบรรลุวัตถุประสงค์ของ “การป้องกันทั่วไป” อันเป็นการป้องกันโดยอ้อม

อย่างไรก็ตาม การใช้กฎหมายอาญาต้องบรรลุผลเป็นการ “ป้องกันโดยตรง” ด้วย กล่าวคือ จะต้องให้บรรลุผลของการป้องกันสำหรับผู้กระทำความผิดบางคนที่มีลักษณะเป็นอันตรายและเป็นที่คาดหมายได้ว่าเขาจะก่อเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนานั้นซ้ำอีก

(3) ภารกิจในการคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายและในการคุ้มครองคุณภาพของการกระทำ ปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์มีอยู่มากมาย แต่กฎหมายอาญาควรจำกัดตัวเองอยู่กับการคุ้มครอง “คุณค่าพื้นฐาน” ของระเบียบสังคมเท่านั้น สิ่งที่หล่อหลอมให้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นไปโดยปกติสุขเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่อาจสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัส แต่เป็นสิ่งที่เป็น “คุณค่า” (value) และเป็นคุณค่าที่จำเป็นที่เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เรียกว่า “คุณธรรมทางกฎหมาย” (Rechtsgut)

คุณธรรมทางกฎหมายที่กฎหมายยอมรับนั้นอาจเป็น “คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล” เช่น เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ หรืออาจเป็น “คุณธรรมที่เป็นส่วนรวม” เช่น “ความปลอดภัยในการจราจร” ในความผิดเกี่ยวกับการจราจร หรือ “ความบริสุทธิ์สะอาดของอำนาจรัฐหรือความบริสุทธิ์สะอาดแห่งตำแหน่ง” ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาญาไม่ได้เกี่ยวข้องในทางคุณค่าเฉพาะ “คุณธรรมทางกฎหมาย” เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องในทางคุณค่าไปถึงคุณภาพของการกระทำของมนุษย์ กล่าวคือ การกระทำที่เป็นการกระทำความผิดอาญานอกจากจะเป็นการละเมิด “คุณธรรมในทางกฎหมาย” แล้ว ยังเป็นการกระทำผิดหน้าที่ในขณะเดียวกันด้วย ผลงานที่เกิดจากการทำผิดหน้าที่นี้ย่อมเป็นผลงานที่ไม่มีคุณภาพและเป็นผลงานที่ไม่พึงเกิดขึ้น กฎหมายอาญาจึงมีภารกิจในการคุ้มครอง “คุณภาพของการกระทำ” ด้วย

อย่างไรก็ดี การที่จะทำให้กฎหมายอาญามีผลใช้บังคับและทำให้ภารกิจของกฎหมายอาญาเกิดผลในทางปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันเป็นกระบวนการนับแต่มีการกระทำความผิดอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่การสอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาและพิพากษา ตลอดจนการบังคับโทษทางอาญา

2.3 ความสำคัญของการค้นในที่รโหฐานต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การค้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น คอยสอดส่องดูว่ามีบุคคลจะกระทำความผิดหรือไม่ และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด คดีอาญาจะเริ่มต้นด้วยการสืบสวนก่อน แต่เมื่อเริ่มทำการสอบสวนแล้วไม่ได้หมายความว่าการสืบสวนจะยุติลง เนื่องจากเพื่อให้การสอบสวนถูกต้องจะต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดอยู่เสมอ ซึ่งในต่างประเทศนั้นไม่ปรากฏว่าแยกการสืบสวนออกจากการสอบสวนเช่นกฎหมายไทย สำหรับการสอบสวนเป็นกระบวนการที่กระทำเพื่อประโยชน์ 3 ประการคือ (1) เพื่อจะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เช่น ความตายได้เกิดจากที่มีบุคคลทำให้ตายหรือไม่ (2) เพื่อพิสูจน์ความผิด เช่น พิสูจน์ว่าความตายของนาย ก ที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดโดยนาย ข กระทำโดยเจตนา (3) เพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เช่น การจับและควบคุมผู้ต้องหา โดยการสอบสวนประกอบด้วยการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ นอกจากนี้การรวบรวมพยานหลักฐานยังรวมถึงการจัดให้มีสิ่งต่างๆ ซึ่งจะพิสูจน์ถึงความเชื่อถือของพยานหลักฐานดังกล่าว และการกระทำอื่นๆ นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เช่น การบันทึกว่าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การในชั้นสอบสวน[17]

การค้นและยึดในที่รโหฐานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนและสอบสวนที่มีความสำคัญ เพราะเป็นขั้นตอนของการนำตัวผู้กระทำความผิดตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่มีการกล่าวหาแล้วเข้าสู่คดี และในหลายๆ กรณีเป็นการนำเจ้าหน้าที่ไปพบผู้ร่วมกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดที่ต่อเนื่องกับการกระทำนั้นรวมถึงการกระทำความผิดอื่น เนื่องจากที่รโหฐานเป็นสถานที่ซึ่งมิใช่สถานที่สาธารณะที่บุคคลใดจะเข้าไปได้โดยพลการ ดังนั้น ที่รโหฐานจึงมักถูกใช้เป็นที่แอบซ่อน อำพรางตัวบุคคลหรือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดอยู่เสมอ

---

[17]หยุด แสงอุทัย, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคำพิพากษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน, 2507), น. 85-86.

การค้นนอกจากจะมุ่งประโยชน์โดยตรงต่อรัฐในการคุ้มครองสังคม และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดผ่านการแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระทำความผิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการลงโทษแล้ว ยังเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในการค้นหาบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย เพราะการค้นประกอบด้วยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ

1. เพื่อพบบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด หรือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือ จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ที่รโหฐานเป็นสถานที่ที่บุคคลมีอำนาจหวงกันไม่ให้คนอื่นเข้ามารบกวนการอยู่ในสถานที่นั้นโดยลำพัง ในกรณีที่ต้องการตัวบุคคลที่ต้องหาว่ากระทำความผิดซึ่งหลบซ่อนอยู่ในที่รโหฐานย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เจ้าพนักงานใช้แต่เพียงวิธีการควบคุมพื้นที่อยู่ภายนอกสถานที่นั้นเพื่อรอให้บุคคลดังกล่าวออกมา การใช้มาตรการบังคับค้นสถานที่ย่อมมีความจำเป็นอยู่ในตัว เช่นเดียวกับกรณีที่กำลังมีการกระทำละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอยู่ในที่รโหฐานนั้น หากไม่มีการเข้าช่วยเหลือโดยทันท่วงทีด้วยการใช้กำลังบังคับเข้าตรวจค้นแล้ว การช่วยเหลือย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

2. เพื่อพบและยึดสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยการกระทำความผิด ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด รวมถึงสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สิ่งของใดที่บุคคลมีไว้เป็นความผิด เช่น ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกเด็ก หากผู้ครอบครองรู้ถึงความผิดนั้นแล้วไม่ทำลายเสียเอง บุคคลนั้นย่อมเจตนาครอบครองทรัพย์นั้นต่อไปโดยซุกซ่อนไว้ในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่อาจพบเห็น การทำให้ทรัพย์นั้นออกมาจากการครอบครองของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดห้ามการครอบครองทรัพย์นั้น ย่อมไม่มีหนทางอื่นใดนอกเสียจากการเข้าค้นในที่รโหฐานเพื่อยึดเอาทรัพย์นั้นมา

ในขณะเดียวกัน หากทรัพย์นั้นเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือเป็นพยานหลักฐานในความผิดนั้น หากอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเองบุคคลดังกล่าวย่อมซุกซ่อนหรือเตรียมทำลายทรัพย์นั้นเพื่อปกปิดความผิด การจะแสวงหาสิ่งของนั้นมาใช้ในการดำเนินคดีและได้มาทันท่วงทีก่อนที่จะมีการโยกย้ายทำลายทรัพย์นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการค้นในที่รโหฐานซึ่งหลายกรณีต้องเป็นการเข้าค้นโดยฉุกเฉิน ยิ่งคดีนั้นเป็นคดีอุกฉกรรจ์ คดีที่มีความร้ายแรง หรือของกลางมีราคาสูงมีจำนวนมากแล้ว ทรัพย์นั้นย่อมถูกปิดบังซ่อนเร้นอย่างดี ยากแก่การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากที่อื่นโดยที่ไม่มีการเข้าไปในที่รโหฐานที่ผู้นั้นอยู่ ซึ่งผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดย่อมไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานเข้าไปตรวจหาพยานหลักฐานแต่โดยดี

นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่พยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น แม้เจ้าพนักงานจะมีอำนาจเรียกให้บุคคลนั้นส่งพยานหลักฐานมาให้ แต่หากบุคคลนั้นมีเจตนาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดแล้ว ย่อมเป็นการสร้างโอกาสให้มีการโยกย้ายทำลายทรัพย์สินนั้นไปเสียก่อน การใช้มาตรการบังคับเข้าตรวจค้นที่รโหฐานของบุคคลที่สามจึงมีความจำเป็นเช่นกัน

ดังนั้น แม้ว่าการค้นในที่รโหฐานจะเป็นการใช้อำนาจเหนือสิทธิและเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวของบุคคล อีกทั้งการค้นในที่รโหฐานเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งอาจเป็นการกระทำต่อบุคคลทั่วไปแม้จะมิใช่ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด แต่ก็เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อมิให้การค้นในที่รโหฐานเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในความเป็นส่วนตัวในสาระสำคัญจนเกินจำเป็น กฎหมายจึงต้องกำหนดให้รัฐเท่านั้นเป็นผู้ใช้อำนาจค้น ราษฎรด้วยกันเองแม้จะเป็นผู้เสียหายก็ไม่มีอำนาจค้นในที่รโหฐานได้ และเจ้าหน้าที่ที่จะทำการค้นได้ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ กล่าวคือ เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ซึ่งหากการค้นในที่รโหฐานได้กระทำภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายบัญญัติแล้ว ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐในการค้นที่รโหฐานย่อมน้อยกว่าประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหายและสมาชิกในสังคมจะได้รับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม

2.4 **แนวคิดในการกำหนดกรอบการค้นในที่รโหฐาน**

เมื่อได้ทราบแล้วว่าการค้นเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์และมีความสำคัญอย่างไรแล้ว สมควรที่จะได้ศึกษาต่อไปว่าการค้นที่ทำให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาจะต้องคำนึงถึงหลักการอะไรบ้างที่ใช้เป็นกรอบในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการค้นและการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่

2.4.1 **ทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา**

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่แต่ละประเทศยึดถือย่อมมีผลต่อแนวการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศนั้นๆ ซึ่งในการศึกษาระบบความยุติธรรมทางอาญาได้แบ่งรูปแบบที่แตกต่างกันเป็นสองทฤษฎี ดังนี้

(1) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model)[18]

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในรูปแบบนี้เน้นการควบคุมและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาย่อมเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของคนส่วนร่วมได้ดีที่สุด จึงมุ่งหมายให้ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะต้องรวบรัดและมีประสิทธิภาพ การค้นหาข้อเท็จจริงในคดีจะพยายามให้ยุติในขั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมให้มากที่สุด อาธิเช่น ในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ มากกว่าการนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จำเป็น ความมุ่งหมายของทฤษฎีนี้จึงอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับว่าการค้นหาข้อเท็จจริงในชั้นตำรวจและอัยการเพียงพอที่จะเชื่อถือได้

(2) ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due Process Model)[19]

รูปแบบนี้เป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งที่เป็นผู้เสียหายและที่เป็นผู้ต้องหาโดยเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เป็นการวางมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของบุคคลอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าอุดมการณ์ของทฤษฎีนี้แตกต่างจากทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม เพียงแต่ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมยึดถือหลักกฎหมายมากกว่าความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรมว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะการค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการจะเชื่อถือได้เพียงใด เพราะวิธีปฏิบัติของตำรวจและอัยการเป็นการดำเนินงานในที่รโหฐาน ซึ่งอาจจะใช้วิธีการล่อลวง ขู่เข็ญ และการสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่ ดังนั้น ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมจึงไม่เห็นพ้องกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม และต้องการให้มีการพิจารณาคดี หรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการและเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรมทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อหน้าองค์คณะผู้พิพากษาที่เป็นกลางไม่ลำเอียงเข้ากับฝ่ายใด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทฤษฎีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมจะเป็นรูปแบบในอุดมคติที่นักนิติศาสตร์แสวงหา แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่มีประเทศใดที่ยึดถือเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหากแต่ได้ผสมผสานทฤษฎีทั้งสองเข้าด้วยกัน ดังนั้น ในการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณา

---

[18] ประธาน วัฒนพานิช, “ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม, ” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, น. 150-151 (กันยายน-พฤศจิกายน 2520).

[19] *เพิ่งอ้าง*, น. 152-154.

ความอาญาเพื่อกำหนดตัวผู้ใช้อำนาจ เงื่อนไขในการใช้อำนาจ และการตรวจสอบการใช้อำนาจ ค้นและยึด ตลอดจนการใช้อำนาจอื่นๆ ในคดีอาญา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ร่างกฎหมายต้องคำนึงถึงการสร้างมาตรการหรือวิธีการที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลทั้งสองประการ ดังต่อไปนี้

1. มาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อการพัฒนารูปแบบการกระทำความผิด

2. การดำเนินคดีอาญามีขั้นตอนกระบวนการที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและไม่เป็นการสร้างความทุกข์ยากแก่ผู้กระทำความผิดเกินกว่าความผิดที่เขาได้กระทำลง รวมถึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกินจำเป็น

2.4.2 **หลักการจำกัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่**

หลักการที่สำคัญซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจำกัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คือหลักที่เรียกว่า “หลักความได้สัดส่วน” (Principle of Proportionality) ซึ่งรู้จักกันดีในฐานะข้อจำกัดการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในทางปกครอง แต่แท้จริงแล้วหลักการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นหลักการพื้นฐานในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเหนือประชาชนในกฎหมายมหาชนทุกประเภท ซึ่งรวมถึงกฎหมายอาญาด้วย[20] โดยหลักความได้ลัดส่วนประกอบด้วยหลักการย่อยๆ สามประการ ดังต่อไปนี้

1. หลักความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Suitability) ซึ่งมีความหมายว่า มาตรการที่รัฐใช้ในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นมาตรการที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้น เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณเลือกมาตรการที่สามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ ลุล่วง มาตรการใดก็ตามที่ไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้เลย ย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักการดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักความสัมฤทธิ์ผลนี้เรียกร้องความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยให้มาตรการที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับเป็นเหตุและสิ่งที่กฎหมายให้อำนาจเป็นผล ดังนั้น ถ้าจะกล่าวไปแล้วหลักความสัมฤทธิ์ผลจึงเป็นสิ่งเดียวกับสามัญสำนึก หากเจ้าหน้าที่ตัดสินใจออกมาตรการที่ไม่

---

[20]Arturas Panomariovas, “Egidijus Losis Proportionality : From the Concept to the Procedure,” the Jurisprudence of University of Wroclaw. 2, 120, p. 260 (2010).

.

สามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่แท้ จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีความมุ่งหมายในใจที่จะใช้มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือดำเนินการให้เกิดผลอย่างอื่นนอกเหนือจากผลที่กฎหมายนั้นประสงค์จะให้เกิดขึ้น เข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ[21]

2. หลักความจำเป็น (Principle of Necessity) หมายความว่า การใช้อำนาจรัฐต้องเป็นการกระทำที่ไม่เกินความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งเรื่องหรือไม่มีมาตรการที่ผ่อนผันหรือร้ายแรงน้อยกว่าที่จะทำให้เป้าหมายของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นสัมฤทธิ์ผลได้[22] ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการแสวงหาพยานหลักฐาน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน หากมีมาตการที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของราษฎรมากน้อยแตกต่างกันแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจเลือกมาตรการที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดดังที่มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น...”[23]

3. หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense) ความเสียหายที่คาดหมายได้จากการใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่างความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่เอกชนหรือแก่สังคมโดยส่วนรวมกับประโยชน์อันมหาชนพึงได้รับจากมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ใช้บังคับ หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบนี้เรียกร้องว่ามาตรการที่ใช้บังคับนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เจ้าหน้าที่จึงต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีและผลเสีย มาตรการใดก็ตามที่เห็นได้ชัดว่าจะยังให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชน เจ้าหน้าที่ต้องละเว้นจากการใช้อำนาจดังกล่าว[24] การใช้

---

[21]วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2*, น. 86-87.

[22]Volker Krey, German Criminal Procedure Law, (Stuttgart Germany : W. Kohlhammer, 2009), pp. 13-15.

[23]ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29

[24]วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่* 2, น. 91-94.

อำนาจของเจ้าหน้าที่จึงต้องได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด หรือได้สัดส่วนกับความสงสัยว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น (Tatverdacht) กล่าวคือ ยิ่งมาตรการที่ใช้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมากเท่าใด ข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดอาญาก็จะต้องมากขึ้นเท่านั้น

บทที่ 3

หลักการค้นในที่รโหฐานตามกฎหมายไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายอังกฤษ

เมื่อได้ศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานในเรื่องการค้นที่รโหฐานแล้ว ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของการค้นในที่รโหฐาน หลักการใช้อำนาจค้นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย หลักการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกา (United States Code : Title 18 Crimes and Criminal Procedure) ตลอดจนหลักการค้นที่รโหฐานตาม The Police and Criminal Evidence Act 1984 ซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญซึ่งวางหลักการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในประเทศอังกฤษ เพื่อให้ทราบถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบในบทต่อไป

3.1 ความหมายของการค้นในที่รโหฐาน

3.1.1 ความหมายของ “การค้น”

การค้นในความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเป็นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐเหนือประชาชนโดยผ่านเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งนักกฎหมายได้ให้ความหมายของการค้นไว้ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ได้ให้ความหมายของการค้นว่าหมายถึง มาตรการบังคับในการดำเนินคดีอาญาของรัฐที่เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจดำเนินการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัย หรือเพื่อพบสิ่งของที่สามารถใช้เป็นพยานเอกสาร เป็นของกลาง หรือเป็นพยานวัตถุ หรือเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือบุคคล ดังนั้น การตรวจค้นเป็นการกระทำที่กระทบถึงสิทธิของเจ้าบ้าน และในการตรวจค้นตัวบุคคล การตรวจค้นเป็นการกระทำที่กระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลหรือเสรีภาพในร่างกาย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได้วางเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจค้นไว้เพื่อความเป็นเสรีนิยม[1]

ดร. จิรนิติ หะวานนท์ ได้ให้ความหมายของการค้นว่า ความหมายของการค้นมี 2 ประเภท

1. ความหมายทั่วไป การตรวจค้น คือ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงล้ำสิทธิส่วนตัวของบุคคลโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเพื่อหาสิ่งของหรือบุคคล เงื่อนไขประการแรกคือ ต้องมีการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคล ประการที่สองคือต้องอาศัยอำนาจกฎหมายและต้องกระทำโดยเจ้าพนักงาน ประการที่สามคือ เพื่อค้นหาสิ่งของหรือบุคคล

2. ความหมายในทางเทคนิคของกฎหมาย บทบัญญัติว่าด้วยการค้นมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิ่งใดนั้น เดิมเข้าใจกันว่าหลักการค้นคุ้มครองเคหสถาน คุ้มครองทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นการเข้าไปค้นเป็นการบุกรุก เพียงแต่ว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจจะเข้าไปได้ การค้นจึงยึดหลักบุกรุก เพราะเข้าใจว่าการค้นจะต้องมีการกระทำอันเป็นการบุกรุก การดักฟังโทรศัพท์จึงไม่ใช่การค้น เพราะไม่ได้เข้าไปในบ้านของบุคคลแต่ต่อโทรศัพท์ที่ชุมสายโทรศัพท์[2]

อีกหลักหนึ่งเข้าใจว่าการค้นไม่ใช่เรื่องบุกรุก แต่เป็นการคุ้มครองสิทธิ (privacy) การดักฟังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว แม้ไม่ได้เข้าไปในบ้านของบุคคลแต่ก็เป็นการค้นอย่างหนึ่ง จึงมีปัญหาว่า การพูดโทรศัพท์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะปิดประตูมิดชิดไม่มีใครได้ยิน ปรากฏว่าเจ้าพนักงานไปติดตั้งเครื่องดักฟังจากตู้โทรศัพท์สาธารณะถือว่าเป็นการค้นหรือไม่ ถ้าใช้หลักบุกรุกไม่ใช่การค้นเพราะไม่ใช่เคหสถาน ไม่ใช่ที่รโหฐานเจ้าพนักงานย่อมทำได้ แต่ถ้าถือว่าการค้นเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนตัว เจ้าพนักงานย่อมกระทำโดยไม่มีหมายไม่ได้ เพราะเมื่อเขาเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะแล้วปิดประตูแสดงว่าไม่ประสงค์จะให้ใครได้ยิน ประสงค์ที่จะให้มีความเป็นส่วนตัว (expectation of privacy) กฎหมายต้องคุ้มครอง หลักการนี้จึงมีเงื่อนไขอยู่ว่าบุคคลต้องแสดงให้ประจักษ์ว่าต้องการความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันก็ต้องพิสูจน์ทางอัตวิสัย (subjective) ให้เห็นว่า ได้แสดงออกไปแล้วว่าต้องการความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันก็ต้องพิสูจน์ในทางภาวะวิสัย ให้เห็นว่า การแสดงออกนั้นบุคคลอื่นก็เข้าใจได้ว่าคนผู้นั้นต้องการความ

---

[1]คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2549), น. 152.

[2]จิรนิติ หะวานนท์, สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2544), น. 19.

เป็นส่วนตัว เมื่อพิสูจน์ได้ทั้งสองด้านถือว่าเกิดสิทธิที่จะมีความเป็นส่วนตัวขึ้นแล้ว ในทางตรงข้าม แม้เราจะอยู่ในบ้านแต่แต่งกายไม่มิดชิด เดินยกแขนยกขาออกกำลังกายซึ่งมองเห็นได้จากถนนหรือตึกตรงข้าม เจ้าพนักงานเอากล้องส่องไปก็มองเห็นโดยที่ไม่ต้องบุกรุกเข้าไปในบ้านนั้น ถ้าใช้หลักการบุกรุกในการวินิจฉัยปัญหาก็จะได้คำตอบว่าเมื่อไม่ได้บุกรุกเข้าไปในเคหสถานก็ไม่ใช่การค้น แต่ถ้าใช้หลักความเป็นส่วนตัวกรณีดังกล่าวเท่ากับว่าเราไม่ประสงค์ที่จะปกปิดให้เป็นเรื่องส่วนตัว เมื่อมองเห็นได้จากที่สาธารณะแสดงว่าเราไม่มีความเป็นส่วนตัวในเรื่องนั้น เมื่อไม่ต้องการความเป็นส่วนตัว กฎหมายก็ไม่คุ้มครอง[3]

จากแนวทางการให้ความหมายของการค้นที่กล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การค้นเป็นการที่รัฐแสวงหาบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งอยู่ในความดูแลครอบครองของบุคคล โดยการใช้อำนาจเข้าบังคับแทรกแซงสิทธิของบุคคลในส่วนของสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่จะอยู่โดยลำพังปราศจากการรบกวนและใช้สอยทรัพย์สินโดยปกติสุข ดังนั้น บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการค้น จึงเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของบุคคลมากกว่าการคุ้มครองสถานที่

3.1.2 **ความหมายของ “ที่รโหฐาน”**

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้แบ่งประเภทการค้นออกเป็นการค้นสถานที่ และการค้นตัวบุคคล ซึ่งหากพิจารณาในแง่สถานที่ที่ทำการค้นแล้ว การค้นสถานที่ยังแบ่งออกเป็นการค้นในที่รโหฐาน และการค้นที่สาธารณสถาน การจำแนกว่าการค้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นที่รโหฐานหรือเป็นสาธารณสถานย่อมมีความสำคัญต่อการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน เนื่องจากหากสถานที่นั้นเป็นที่รโหฐานแล้วการค้นต้องกระทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เคร่งครัด กล่าวคือ จะต้องมีหมายที่ออกโดยศาลเพื่อทำการค้นตามนัยของมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ระบุว่า “ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น”

ปัญหาว่า “ที่รโหฐาน” เป็นสถานที่อย่างไรนั้น มาตรา 2 (13) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกำหนดไว้เพียงว่า “ที่รโหฐาน” หมายความถึงที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดั่งบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา โดยกฎหมายลักษณะอาญาหรือประมวล

---

[3] *เพิ่งอ้าง*, น. 20.

กฎหมายอาญาในปัจจุบันได้นิยามความหมายของ “สาธารณสถาน” ไว้ในมาตรา 1 (3) ว่า “สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ โดยนายรองพล เจริญพันธุ์ ได้ให้คำอธิบายว่า คำว่าที่รโหฐานนี้ได้บัญญัติขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี คือ Halsbury Law of England ซึ่งไม่ได้นิยามคำว่าที่รโหฐานเอาไว้โดยเฉพาะ แต่ได้บัญญัติคำว่า “ที่สาธารณสถาน” ว่าหมายถึงสถานที่ที่บุคคลทั่วไปมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เช่น ทุ่งนาเปิดโล่งหลายร้อยไร่ต่อเนื่องกัน โดยถือว่าสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็คือที่รโหฐานอันมีแนวเดียวกับกฎหมายไทย ส่วนกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็เป็นอย่างเดียวกันดังปรากฏหลักฐานจาก Black’ s Law Dictionary[4]

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่ามีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยที่อธิบายและยกตัวอย่างสถานที่อันเป็นที่รโหฐาน ดังต่อไปนี้

1. ที่ตอนในของร้านขายอาหารซึ่งเจ้าของแบ่งไว้เป็นที่อาศัยนอน ผู้คนจะเข้าไปได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่เป็นที่สาธารณสถาน[5]

2. การค้นสถานที่อาจจะเป็นการค้นที่สาธารณสถานหรือที่รโหฐานก็ได้ การค้นที่สาธารณสถาน กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีหมายค้น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงมีอำนาจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น สถานที่บนขบวนรถไฟโดยสารไม่ใช่ที่รโหฐานแต่เป็นที่สาธารณสถาน เจ้าพนักงานสรรพสามิตค้นจับฝิ่นในที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น และไม่จำเป็นต้องค้นในเวลากลางวันหรือแสดงความบริสุทธิ์ก่อน สถานที่บนขบวนรถไฟโดยสารนั้นไม่ใช่ที่รโหฐาน เป็นที่สาธารณสถาน[6]

3. ที่เกิดเหตุเป็นร้านค้าและเป็นที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ จึงเป็นสาธารณสถานตามมาตรา 1(3)[7]

4. สถานที่ใดจะเป็นสาธารณสถานหรือไม่ ไม่ต้องคำนึงว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ผิดกฎหมาย เช่น สถานการค้าประเวณีหรือไม่ เพียงแต่พิจารณาว่าสถานที่นั้นประชาชนมี

---

[4]สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ครั้งที่ 919-23/2527 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2527, น. 3-4.

[5]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 606/2475 16 ธส. 551.

[6]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2024/2497 ฎ. 1776.

[7]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1362/2508 2508 ฎ. 2063

ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้หรือไม่และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป ถ้าประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ สถานที่นั้นก็เป็นสาธารณสถานไม่ใช่ที่รโหฐาน ได้ความว่าเจ้าของสถานการค้าประเวณีหรือซ่องโสเภณีมิได้หวงห้ามผู้หนึ่งผู้ใดที่จะไปหาความสุขกับหญิงโสเภณีหรือไปธุระอื่นที่จะเข้าไปในห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่รับแขกในสถานการณ์ค้าประเวณีหรือซ่องโสเภณีนั้น ห้องโถงจึงเป็นสถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้เป็นสาธารณสถานไม่ใช่ที่รโหฐาน พนักงานตำรวจมีอำนาจค้นและจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93,78 (3) จำเลยมีและใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ขัดขวางมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140, 289 (2), 80, 52[8]

5. บ้านของจำเลยยังไม่มีประตูรั้วกับประตูบ้านทั้งยังสร้างไม่เสร็จ แต่โดยสภาพของบ้านที่พักอาศัยย่อมถือเป็นที่รโหฐาน บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต[9]

นอกจากคำพิพากษาของศาลดังกล่าวข้างต้น นักกฎหมายของไทยยังได้ให้คำอธิบายไว้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาว่า “ที่รโหฐาน” ได้แก่สถานที่ที่บุคคลมีเจตนาหวงกันมิให้บุคคลอื่นเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งการหวงกันดังกล่าวอาจเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยสภาพแห่งสถานที่นั้น เช่น บริเวณเคหสถานบ้านเรือนของบุคคลใดย่อมเป็นที่รโหฐาน สถานที่แห่งใดที่เจ้าของปิดป้ายห้ามเข้าหรือสร้างรั้วรอบย่อมเป็นเจตนาหวงกัน การยินยอมให้ประชาชนเข้าไปแต่อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นที่สาธารณสถาน เช่น โรงภาพยนตร์ หรือโรงมหรสพอื่นๆ ที่ผู้เข้าชมต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าไป[10]

จึงเห็นได้ว่า หากเป็นสถานที่ซึ่งบุคคลสามารถแสดงออกให้เห็นได้โดยชัดเจน โดยปริยาย หรือโดยสภาพว่าไม่ประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ที่ดิน โรงเรือน หรือแม้แต่อาคารบ้านเรือนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จก็ตาม ย่อมเป็นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย

---

[8]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2520 (ประชุมใหญ่) เน. 5 น. 503.

[9]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6557/2547, http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp.

[10]คนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 211.

สำหรับยานพาหนะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปมา เช่น รถไฟ และรถเมล์ ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการนั้น ย่อมไม่ใช่ที่รโหฐานแต่เป็นที่สาธารณสถานตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2024/2497 อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่า หากเป็นยานพาหนะหรือตู้เก็บของส่วนบุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งโดยสภาพเห็นได้ว่าไม่ใช่ “สาธารณสถาน” เนื่องจากบุคคลทั่วไปไม่อาจเปิดดูหรือเข้าไปในยานพาหนะนั้นได้โดยพลการ จะถือว่าเป็นที่รโหฐานตามนัยของมาตรา 92 ประกอบกับมาตรา 2 (13) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จะต้องมีหมายค้นด้วยหรือไม่ ในกรณีนี้ยังไม่มีแนวคำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยไว้โดยตรงว่ารถยนต์เป็นที่รโหฐานหรือไม่ และนักกฎหมายไทยยังคงมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่าย กล่าวคือ

ฝ่ายแรกเห็นว่า ยานพาหนะเป็นที่รโหฐาน เนื่องจากบุคคลย่อมต้องการความเป็นส่วนตัวในยานพาหนะของเขา

ส่วนฝ่ายที่สอง เห็นว่า รถยนต์ไม่ใช่ที่รโหฐาน เนื่องจากเห็นว่า การค้นรถยนต์ในที่สาธารณสถานคงไม่แตกต่างอะไรกับการค้นกระเป๋าใส่เอกสาร หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้า หากแปลว่ารถยนต์เป็นที่รโหฐาน ต้องไปขอหมายค้นจากศาลมาก่อน จึงจะค้นได้ คนร้ายก็คงจะเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะกว่าจะขอหมายค้นมาจากศาลได้รถยนต์คงแล่นไปไกลเกินกว่าจะตามไปตรวจค้นได้ทัน ครั้นจะกักรถยนต์ไว้รอหมายค้นของศาล ประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็จะเดือดร้อน ถ้าแปลว่ารถยนต์ไม่ใช่ที่รโหฐาน พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีความสงสัยว่าจะมีของผิดกฎหมายอยู่ในรถยนต์ ก็ค้นได้ทันที ค้นไม่พบของผิดกฎหมาย รถยนต์นั้นก็สามารถแล่นไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอหมายค้นจากศาล พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าในรถยนต์นั้นมีสิ่งของผิดกฎหมายย่อมมีอำนาจค้นรถยนต์นั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 โดยถือว่าเป็นการค้นบุคคลที่ครอบครองรถยนต์นั้นในที่สาธารณสถาน[11]

ทั้งนี้ การค้นยานพาหนะในถนนหลวงมีลักษณะเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข[12]

---

[11]ประดิษฐ์ เอกมณี, “ค้น,” ดุลพาห, เล่ม 4, ปีที่ 44, น. 124-125 (ตุลาคม-ธันวาคม 2540). .

[12]ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552), น. 270.

นอกจากนี้ ในการศึกษาคำพิพากษาของศาลไม่ปรากฏแนวคำพิพากษาที่วินิจฉัยว่ายานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือยนต์ หรือเครื่องบิน เป็นที่รโหฐานซึ่งการค้นจะต้องกระทำโดยมีหมายจากศาล โดยมีเพียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ระบุว่าการค้นรถยนต์ของเจ้าพนักงานโดยไม่มีหมายค้นไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คือคำพิพากษาฎีกาที่ 2281/2534[13] ซึ่งวินิจฉัยว่า ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าการตรวจค้นรถโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 กระทำไปโดยมีเจตนากลั่นแกล้งไม่มีเหตุอันสมควรจะตรวจค้น การตรวจค้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อหานี้เป็นการไม่ชอบนั้น ในข้อนี้จำเลยมีพยานมาเบิกความยืนยันว่า เห็นโจทก์หยิบอาวุธปืนสั้นออกมาจากรถโจทก์ โดยไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะแกล้งเบิกความปรักปรำโจทก์ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ตรวจค้นรถโจทก์จึงเป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควรที่จะตรวจค้น มิใช่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อนี้จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ด้วยผลของคำพิพากษาดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อมา ดังที่ได้มีหนังสือกรมตำรวจ ด่วนที่สุด ที่ 0606.6/150066 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2540 เรื่องการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ การค้นรถยนต์ว่า “เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทั่วไปมีอำนาจตรวจค้นรถยนต์ในที่สาธารณะได้โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 93 (ตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 2281/2534)”

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ จะเป็นการรับรองสิทธิที่จะมีความปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และทรัพย์สิ่งของจากการถูกค้นและยึดโดยไม่มีเหตุอันควร[14] ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เคหสถานของบุคคลเท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันดีว่า รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ

---

[13]สืบค้นจาก http://deka2007.supremecourt. or.th/ deka/web/searchlist.jsp.

[14]The fourth Amendment.

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated [...]

อเมริกามุ่งคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล (privacy) ไม่ใช่ตัวสถานที่ (place)[15] ดังนั้น การให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่มีอยู่เหนือพื้นที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่จึงไม่จำกัดเพียงเคหสถาน หรือ houses ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากแต่ขยายขอบเขตไปถึงพื้นที่ใดๆ ที่บุคคลมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วย

อย่างไรก็ตาม สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอันพึงคาดหมายได้ที่มีอยู่เหนือสถานที่นั้นมีระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยศาลได้อธิบายว่าสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (The Fourth Amendment) ที่มีอยู่เหนือเคหสถาน (house) และรถยนต์ (car) นั้น มีความแตกต่างกัน[16] ซึ่งส่งผลต่อการค้นว่าจะสามารถกระทำได้โดยไม่มีหมายหรือไม่ ด้วยแนวคิดดังกล่าวเป็นผลให้ศาลฎีกาสหรัฐได้วางหลักไว้ในคดี Carroll v. United States[17] ว่า การค้นยานพาหนะสามารถกระทำได้โดยไม่มีหมายค้น หากเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นมีเหตุอันเป็นไปได้ที่ทำให้เจ้าพนักงานเชื่อได้ว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกสิ่งของผิดกฎหมาย ศาลฎีกาสหรัฐอธิบายว่ายานพาหนะสามารถเคลื่อนตัวพ้นไปจากเขตอำนาจศาลได้อย่างรวดเร็วหากต้องรอหมายจากศาลก่อน โดยในระยะเริ่มแรกศาลได้จำกัดขอบเขตของคำพิพากษาในคดี Carroll ว่า เจ้าพนักงานจะสามารถขอให้ยานพาหนะที่กำลังวิ่งหยุดเพื่อทำการค้นได้ แต่การค้นจะต้องกระทำทันทีที่ขอให้หยุดรถซึ่งหมายความว่าเจ้าพนักงานไม่อาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปที่อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานเพื่อทำการค้นโดยที่ไม่มีหมาย[18]

ต่อมาศาลได้ลดความสำคัญของเหตุผลความเป็นส่วนตัวลง โดยอธิบายว่าบุคคลสามารถคาดหมายถึงการลดลงของความเป็นส่วนตัวในยานยนต์ลงได้เพราะว่าโดยหน้าที่ของมันคือการขนส่งมากกว่าที่จะใช้ในฐานะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่เก็บรักษาสิ่งของส่วนตัว เนื่องจากรถยนต์สามารถวิ่งไปตามถนนหนทาง ซึ่งเราสามารถมองเห็นผู้ครอบครองและสิ่งของที่บรรทุกอยู่อย่างชัดเจน บรรทัดฐานดังกล่าวครอบคลุมไปถึงยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่ด้วย เพราะแม้จะเห็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเก็บรักษาสิ่งของส่วนตัว

---

[15]Katz v. United States, (1967) 389 U.S. 347, 353.

[16]Chambers v. Maroney, (1970).399 U.S. 42, 52.

[17]Carroll v. United States, (1925) 267 U.S. 132

[18]เรวัต ฉ่ำเฉลิม และคณะ, “งานวิจัย เรื่อง เหตุให้มีอำนาจจับและค้น,” สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551, น. 44.

ก็ตาม แต่สิ่งของที่บรรทุกอยู่ภายในทั้งหลายก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตาของสาธารณชนและยานพาหนะดังกล่าวยังพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปได้เสมอ[19]

นอกจากนี้ ศาลได้กลับคำวินิจฉัยเดิมและวางหลักว่า เจ้าพนักงานสามารถเคลื่อนย้ายยานพาหนะเพื่อทำการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ เพราะอำนาจในการค้นโดยไม่มีหมายไม่ได้สิ้นสุดลงในทันทีที่รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อีกต่อไปด้วย[20] และแม้ว่าเจ้าพนักงานจะสามารถตรวจค้นยานพาหนะได้โดยไม่ต้องมีหมาย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีมูลเหตุอันเป็นไปได้สำหรับการค้นอยู่

ในประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในการแสวงหาพยานหลักฐานในลักษณะเดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยคือ The Police and Criminal Evidence Act 1984 ซึ่งบัญญัติถึงการค้นที่สำคัญ 2 กรณี ได้แก่

1. การเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้น (Powers to Stop and Search person, vehicle etc.) ซึ่งกระทำได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นเมื่อมีเจ้าพนักงานตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควร (reasonable suspicion) ตามมาตรา 1 ของ PACE

2. การค้นสถานที่ (Power to entry and search of premises) ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อมีหมายค้นที่ออกโดยศาล ตามมาตรา 8 ของ PACE

การค้นสถานที่ หรือ premises นี้ มีนิยามศัพท์อยู่ในมาตรา 23[21] ซึ่งบัญญัติว่า “สถานที่” หมายถึง สถานที่ใดๆ และในกรณีเฉพาะให้หมายความรวมถึง

---

[19]*เพิ่งอ้าง*.

[20]California v. Carney, (1985) 471 U.S. 386,393

[21]23. Meaning of “premises” etc.

In this Act—

“premises” includes any place and, in particular, includes—

(a) any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft;

(b) any offshore installation;

(ba) any renewable energy installation;]

(c) any tent or movable structure

(1) ยานพาหนะ เรือ เครื่องบิน เครื่องร่อน

(2) สิ่งก่อสร้างนอกชายฝั่ง ซึ่งได้แก่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน

(3) เต็นท์ หรือสิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้

ความแตกต่างของการค้นยานพาหนะตามมาตรา 1 และมาตรา 8 คือ การค้นตามมาตรา 1[22] เป็นการเรียกให้ยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจค้น ซึ่งในขณะที่จะทำการค้น ยานพาหนะนั้นอยู่ในสถานที่ ดังนี้

(1) สถานที่ซึ่งตามปกติของสถานที่นั้น บุคคลทั่วไปได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้เข้าไปได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะต้องเสียค่าเข้าหรือไม่ก็ตาม

"offshore installation" has the meaning given to it by section 1 of the Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971.

["renewable energy installation" has the same meaning as in Chapter 2 of Part 2 of the Energy Act 2004.]

[22]1. Power of constable to stop and search persons, vehicles etc.

— (1) A constable may exercise any power conferred by this section—(a) in any place to which at the time when he proposes to exercise the power the public or any section of the public has access, on payment or otherwise, as of right or by virtue of express or implied permission; or

(b) in any other place to which people have ready access at the time when he proposes to exercise the power but which is not a dwelling.

(2) Subject to subsection (3) to (5) below, a constable—

(a) may search—

(i) any person or vehicle;

(ii) anything which is in or on a vehicle,

for stolen or prohibited articles , any article to which subsection (8A) below applies or any firework to which subsection (8B) below applies] ; and

(b) may detain a person or vehicle for the purpose of such a search.

(3) This section does not give a constable power to search a person or vehicle or anything in or on a vehicle unless he has reasonable grounds for suspecting that he will find stolen or prohibited articles , any article to which subsection (8A) below applies or any firework to which subsection (8B) below applies [...]

(2) สถานที่ซึ่งในขณะที่เจ้าพนักงานจะเข้าค้นนั้นได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้แต่สถานที่นั้นจะต้องไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ การค้นตามมาตรา 1 เจ้าพนักงานจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะพบของที่ถูกขโมย หรือสิ่งของต้องห้าม (prohibited articles) ได้แก่ อาวุธร้ายแรง สิ่งของที่มีไว้หรือทำขึ้นเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ทำให้เสียทรัพย์ เป็นต้น

ดังนั้น ตามกฎหมายอังกฤษยินยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจค้นรถยนต์ในที่สาธารณะได้โดยไม่มีหมายค้น แต่หากจะค้นรถยนต์ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะมาตรา 8[23] ให้ถือว่าการค้นรถยนต์คือการค้น “สถานที่” ซึ่งต้องมีหมายในการค้นด้วย

จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยจะระบุไว้ชัดเจนว่าการค้นสถานที่ที่บุคคลไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปจะต้องกระทำโดยมีหมายจากศาลซึ่งอาจตีความได้ว่ารวมถึงยานพาหนะต่างๆ ที่อยู่ในความหวงกันของบุคคลก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่ รวมถึงศาล และทางปฏิบัติที่ผ่านมาของเจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย ก็มิได้ถือว่ายานพาหนะเป็นที่รโหฐานที่จะต้องมีหมายศาลในการค้นแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

---

[23]8. Power of justice of the peace to authorise entry and search of premises.

— (1) If on an application made by a constable a justice of the peace is satisfied that there are reasonable grounds for believing—

(a) that an indictable offence] has been committed; and

(b) that there is material on premises which is likely to be of substantial value (whether by itself or together with other material) to the investigation of the offence; and

(c) that the material is likely to be relevant evidence; and

(d) that it does not consist of or include items subject to legal privilege, excluded material or special procedure material; and

(e) that any of the conditions specified in subsection (3) below applies,he may issue a warrant authorising a constable to enter and search the premises.

3.2 หลักการค้นที่รโหฐานโดยมีหมาย

3.2.1 เหตุในการออกหมายค้น

ตามมาตรา 69 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยได้กำหนดให้ศาลเป็นองค์กรผู้มีอำนาจออกหมายค้นโดยได้ระบุเหตุในการออกหมายค้นไว้ 5 ประการ ดังนี้

(1) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา หมายความว่า จะต้องมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนหรือมีการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาโดยศาลอยู่แล้วจึงจะออกหมายได้ โดยศาลต้องเชื่อว่าสิ่งของนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน และสิ่งของนั้นจะพบในสถานที่ที่ออกหมายค้น

(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด โดยทรัพย์ซึ่งมีไว้เป็นความผิด คือ สิ่งของที่กฎหมายห้ามมิให้บุคคลมีไว้ เช่น ธนบัตรปลอม ทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด หมายถึงได้มาโดยการกระทำความผิดโดยตรง เช่น ทรัพย์ของผู้เสียหายที่ผู้ต้องหาไปขโมยมา แต่ไม่รวมถึงทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอ้อม เช่น ขโมยเงินแล้วเอาไปซื้อรถยนต์ รถยนต์ที่ซื้อมาจากเงินที่ขโมยมานั้นไม่ใช่ของที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ส่วนทรัพย์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด ได้แก่ อาวุธปืนที่ใช้ฆ่าคนตาย ในขณะที่ทรัพย์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด ย่อมได้แก่ อาวุธปืนที่จะพยายามใช้ในการฆ่าคนตาย แต่ยังไม่ทันได้ใช้ในการพยายามฆ่านั้น[24]

(3) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขอให้ออกหมายเพื่อพบหญิงที่ถูกฉุดคร่าไปเพื่อการอนาจาร หรือเพื่อพบเด็กซึ่งถูกจับไปเรียกค่าไถ่

(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ อนุมาตรานี้เป็นการบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรา 70 ที่บัญญัติว่า หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามมิให้ออก เว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วย และเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ เพื่อให้การจับบุคคลในที่รโหฐานเป็นการกลั่นกรองให้แน่ใจถึงสองครั้ง กล่าวคือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะพบตัวบุคคลในที่รโหฐานนั้นจริงๆ และมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าว

---

[24]หยุด แสงอุทัย, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคำพิพากษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บ้านการเรือน, 2507), น. 580.

กระทำความผิดจริงๆ[25] เพราะการค้นเพื่อจับบุคคลย่อมกระทบต่อทั้งเสรีภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายและเสรีภาพในการอยู่อาศัยในเคหสถานซึ่งเป็นเสรีภาพของ “ผู้ทรงสิทธิ” ที่แตกต่างกัน

(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว เช่น ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สิน แต่เจ้าพนักงานยังไม่ได้ทรัพย์สินนั้นมาไว้ในครอบครองก็ต้องขอให้ออกหมายค้น

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดให้ศาลเป็นองค์กรผู้มีอำนาจออกหมายค้นตามคำร้องขอของเจ้าพนักงานตำรวจหรืออัยการ โดย Rule 41 (C)[26] ซึ่งออกตามความใน Title 18 Crimes and Criminal Procedure กำหนดให้ผู้พิพากษาศาลมาจิสเตรท (magistrate judge) อาจออกหมายค้นเพื่อพบสิ่งของหรือบุคคลในกรณีต่อไปนี้

(1) พยานหลักฐานในการกระทำความผิดอาญา

(2) สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด สิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือสิ่งของอย่างอื่นที่ได้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย

(3) ทรัพย์ที่ทำไว้ หรือตั้งใจมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้ในการกระทำความผิด

(4) บุคคลที่ต้องการจับหรือบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

---

[25]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2553), น. 436.

[26] Rule 41

(c) Persons or Property Subject to Search or Seizure.

A warrant may be issued for any of the following:

(1) evidence of a crime;

(2) contraband, fruits of crime, or other items illegally possessed;

(3) property designed for use, intended for use, or used in committing a crime; or

(4) a person to be arrested or a person who is unlawfully restrained.

ส่วนหลักเกณฑ์ในการออกหมายค้นสถานที่ในประเทศอังกฤษเป็นไปตามมาตรา 8[27] ของ The Police and Criminal Evidence Act 1984 หรือ PACE ที่วางหลักไว้ว่าการออกหมายค้นของผู้พิพากษาจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้พิพากษามีเหตุอันควรเชื่อ (reasonable grounds for believing) ว่า มีการกระทำความผิดอาญาประเภทที่เรียกว่า indictable offence[28] ซึ่งหมายถึง

1. ความผิด “indictable only offences” ซึ่งเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่มีโทษสูงในบรรดาความผิดอาญาทั้งสามประเภทของประเทศอังกฤษ ที่แบ่งออกเป็น Summary offences, Either-way offences และ Indictable only offences[29] ความผิดในระดับ Indictable only offences นี้ จะต้องพิจารณาโดยวิธีอินไดท์เมนท์ซึ่งโจทก์จะต้องจัดทำคำฟ้องเป็นหนังสือเรียกว่า Indictment มีการไต่สวนมูลฟ้องโดยศาล Magistrate หากศาลเห็นว่าคดีมีมูลก็จะส่งคำฟ้องเพื่อให้มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและผู้พิพากษาในศาล Crown Court

---

[27]Section 8. Power of justice of the peace to authorise entry and search of premises.

(1) If on an application made by a constable a justice of the peace is satisfied that there are reasonable grounds for believing—

(a) that an indictable offence has been committed; and

(b) that there is material on premises mentioned in subsection (1A) below] which is likely to be of substantial value (whether by itself or together with other material) to the investigation of the offence; and

(c) that the material is likely to be relevant evidence; and

(d) that it does not consist of or include items subject to legal privilege, excluded material or special procedure material; and [...].

[28] มาตรา 8 (a) ของ The Police and Criminal Evidence Act 1984 ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย Serious Organised Crime and Police Act 2005 (SOCAP) โดยแก้ไขจาก “serious arrestable offence” เป็น “Indictable offence”

[29]มาตรา 15 ของ The Criminal Law Act 1977 บัญญัติแยกประเภทความผิดทางอาญาตามวิธีพิจารณาออกเป็นสามประเภท

ความผิดในประเภทนี้ ได้แก่ ความผิดฐานฆ่าคนตายไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ความผิดฐานชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รีดทรัพย์ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัส ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ความผิดฐานเรียกค่าไถ่ เป็นต้น[30]

2. ความผิด "Either-way offences" เป็นความผิดที่กำหนดขึ้นใหม่โดย The Criminal Law Act 1977 ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 16 ประกอบกับตาราง 2 และ 3 ท้ายพระราชบัญญัติ และต่อมาถูกยกเลิกและบัญญัติไว้ในมาตรา 17 ประกอบกับตาราง 1 ของ The Magistrates' Courts Act 1980 ความผิดประเภทนี้ก่อนการพิจารณาคดี Magistrate Court จะต้องพิจารณาก่อนว่าวิธีพิจารณาแบบใดจะเหมาะสมที่สุด โดยศาลจะสอบถามโจทก์ก่อนแล้วจึงสอบถามจำเลย หลังจากนั้นศาลจะต้องพิจารณาลักษณะของความผิดว่ามีลักษณะเป็นความผิดอุกฉกรรจ์หรือไม่ โทษที่จำเลยควรได้รับหากฟังว่าจำเลยกระทำผิดจะอยู่ในอำนาจ Magistrate Court หรือไม่ หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ว่าคดีควรพิจารณาโดยวิธีอินไดท์เมนท์หรือซัมมารีทรัยล์ ยกเว้นคดีที่ฟ้องโดย Attorney-General หรือ Solicitor General หรือ Director of Public Prosecutions ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาโดยอินไดท์เมนท์ ซึ่งศาลต้องพิจารณาตามคำร้องดังกล่าวและดำเนินกระบวนพิจารณาไปในฐานะเป็นศาลชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีควรใช้วิธีซัมมารีทรัยล์ ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยผู้พิพากษาศาล Magistrate จำนวนสามคน โดยไม่มีการพิจารณาของคณะลูกขุน ศาลก็จะอธิบายเหตุผลให้จำเลยฟังและขอความยินยอมจากจำเลย หากจำเลยไม่ยินยอมก็ต้องพิจารณาโดยวิธีอินไดท์เมนท์ และหากจำเลยยินยอมให้พิจารณาโดยวิธีซัมมารีทรัยล์ ศาลต้องอธิบายว่าหากศาลฟังว่าจำเลยกระทำความผิด ศาลอาจจะส่งจำเลยเพื่อให้ศาลคราวน์คอร์ทลงโทษได้ เพื่อให้รับโทษเกินกว่าอำนาจศาลได้เมื่อได้พิจารณาความประพฤติและประวัติก่อนๆ ของจำเลยแล้ว เมื่อได้อธิบายดังกล่าวแล้วศาลจะถามจำเลยอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลือกวิธีพิจารณาแบบใด ถ้ายินยอมให้ใช้วิธีซัมมารีทรัยล์ ศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาแบบซัมมารีทรัยล์ แต่ถ้าจำเลยไม่ให้ความยินยอม ศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาไปในฐานะศาลชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามวิธีพิจารณาแบบอินไดท์เมนท์ หากศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีควรพิจารณาโดยวิธีอินไดท์เมนท์ ศาลจะแจ้งให้จำเลยทราบ และดำเนินคดีไปในฐานะศาลชั้น

---

[30]Leonard Jason-Lloyd, An Introduction to Policing and Police Powers (Great Britain : Cavendish Publishing, 2000), "Chapter Updates for Police Powers of Arrest 1/12/2006," < http://www.routledgelaw.com/textbooks/9781859417058/ updates/ 4.asp>.

ไต่สวนมูลฟ้อง ความผิดประเภทนี้ เมื่อเริ่มพิจารณาโดยวิธีหนึ่งดังกล่าวแล้ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่าควรจะพิจารณาอีกแบบหนึ่งจะเหมาะกว่า ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้[31]

ความผิด Either-way offences ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนรำคาญ ความผิดฐานลักทรัพย์ ฉ้อโกง รับของโจร ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ความผิดฐานทะเลาะวิวาท ความผิดฐานขัดขวางการจับกุม ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด[32]

สำหรับความผิด Summary Offences นั้น ได้แก่ ความผิดอาญาที่มีโทษเล็กๆ น้อยๆ เดิมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้ได้รับการพิจารณาโดยวิธีซัมมารีทรัยล์ แต่เมื่อรัฐสภาออก The Criminal Law Act 1977 แล้ว ได้นำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ มารวมไว้ในมาตรา 15 ประกอบกับตาราง 1 ท้ายพระราชบัญญัติ ความผิดประเภทนี้ต้องพิจารณาใน Magistrate Court[33] ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยกตัวอย่างเช่น

ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน (Betting Gaming and Lotteries Act 1963)

ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนในที่สาธารณะตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน (Firearms Act 1968)

ความผิดฐานทำลายการชุมนุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมของประชาชน (Public Meeting Act 1908)

ความผิดฐานใช้หรือพาไปซึ่งยานพาหนะของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (Theft Act 1968)

ความผิดฐานบุกรุกสนามบินตามมาตรา 39 (1) ของพระราชบัญญัติสนามบินเอกชน (Civil Aviation Act 1982)

ความผิดฐานกระทำประทุษร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย หรือ Common Assault ตามมาตรา 39 ของ Criminal Justice Act 1988

---

[31]วีระพงษ์ บุญโญภาส, “โครงการวิจัย การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด,” สำนักงานศาลยุติธรรม, พฤษภาคม 2551, น. 7-8.

[32] Leonard Jason-Lloyd, *supra note 24*.

[33]วีระพงษ์ บุญโญภาส, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31*, น. 7.

ความผิดฐานขับขี่ในขณะที่ไร้ความสามารถในการควบคุมยานพาหนะตามมาตรา 103 (1) (b) ของพระราชบัญญัติการจราจรทางบก (Road Traffic Act 1988)

ความผิดฐานข่มขู่เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ตามมาตรา 89 (1) ของพระราชบัญญัติตำรวจ (Police Act 1996)

ความผิดฐานข่มขู่ตามมาตรา 2 ของ The Protection from Harassment Act 1997 เป็นต้น

นอกจากจะมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิด indictable only offences หรือ Either-way offences แล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงตามมาตรา 8 (3) ว่า[34]

1. เชื่อได้ว่ามีสิ่งของในสถานที่ดังกล่าวที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน ไม่ว่าโดยสภาพของตัววัตถุนั้นเองหรือการนำไปใช้ประกอบกับวัตถุอื่น

2. สิ่งของนั้นมีแนวโน้มจะเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นพยานหลักฐานใดๆ ก็ตามที่สามารถเสนอต่อศาลในคดีนั้น

3. ไม่สามารถติดต่อบุคคลที่มีสิทธิให้เจ้าพนักงานเข้าไปในสถานที่นั้นหรือบุคคลที่มีสิทธิให้เจ้าพนักงานเข้าถึงพยานหลักฐานนั้น หรือหากไม่มีหมายค้นแล้วจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่นั้นได้ หรือวัตถุประสงค์ของการค้นจะเสียไปหากไม่สามารถเข้าไปในสถานที่นั้นได้ทันทีเมื่อไปถึง

---

[34]Section 8 [...] (3) The conditions mentioned in subsection (1)(e) above are—

(a) that it is not practicable to communicate with any person entitled to grant entry to the premises;

(b) that it is practicable to communicate with a person entitled to grant entry to the premises but it is not practicable to communicate with any person entitled to grant access to the evidence;

(c) that entry to the premises will not be granted unless a warrant is produced;

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่าประเทศอังกฤษไม่มีการออกหมายค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเล็กน้อย แต่จะมีการออกหมายเรียก (summon) โดยศาลมาจิสเตรทตามมาตรา 97 ของ Magistrates' Courts Act 1980

นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษไม่มีการออกหมายจับในความผิดเล็กน้อยจึงไม่มีเหตุที่จะออกหมายค้นเพื่อจับบุคคลในที่รโหฐานในความผิดเล็กน้อยด้วย เพราะถือว่าในคดีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพียงพอที่รัฐจะใช้อำนาจบังคับค้นที่รโหฐานไม่ว่าเพื่อหาพยานหลักฐานหรือจับกุมบุคคล โดยหลักเกณฑ์ในการออกหมายเรียกที่เรียกว่า summon เพื่อเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนี้ออกโดยอาศัยอำนาจในมาตรา 1[35] ของ Magistrates' Courts Act 1980 ซึ่งบัญญัติให้ผู้พิพากษาศาลมาจิสเตรทออกหมายเรียกบุคคลมาให้การต่อศาล เว้นแต่

(d) that the purpose of a search may be frustrated or seriously prejudiced unless a constable arriving at the premises can secure immediate entry to them [...].

[35] 1. Issue of summons to accused or warrant for his arrest.

(1) On an information being laid before a justice of the peace that a person has, or is suspected of having, committed an offence, the justice may issue—

(a) a summons directed to that person requiring him to appear before a magistrates' court to answer the information, or

(b) a warrant to arrest that person and bring him before a magistrates' court.

(2) . . . . . .

(3) No warrant shall be issued under this section unless the information is in writing . . . .

(4) No warrant shall be issued under this section for the arrest of any person who has attained the age of 18 years unless—

(a) the offence to which the warrant relates is an indictable offence or is punishable with imprisonment, or

(b) the person's address is not sufficiently established for a summons to be served on him.

(5) . . . . . .

(6) Where the offence charged is an indictable offence, a warrant under this section may be issued at any time notwithstanding that a summons has previously been issued.

(1) ในคดีที่ผู้กระทำความผิดอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์ และต้องหาว่ากระทำความผิดที่มีโทษจำคุก หรือปรากฏแก่ศาลว่าผู้ต้องสงสัยในความผิดดังกล่าวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่จะจัดส่งหมายเรียกได้ ศาลมาจิสเตรทสามารถออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้

(2) ในกรณีที่บุคคลต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาร้ายแรงประเภท indictable offence ไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุถึง 18 ปีบริบูรณ์หรือไม่ ศาลมาจิสเตรทสามารถออกหมายจับได้ทันที

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีหมายจับเพื่อจับกุมบุคคลตาม (1) และ (2) ข้างต้น แต่เนื่องจากมาตรา 17 ของ PACE ระบุให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นเพื่อ (1) บังคับให้เป็นไปตามหมายจับและ (2) เพื่อจับกุมบุคคลที่กระทำความผิด indictable offence หรือความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นที่บัญญัติให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ จึงไม่จำเป็นต้องออกหมายค้นเพื่อจับกุมบุคคลตามหมายจับแต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุออกหมายค้นตามกฎหมายไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายอังกฤษแล้วจะเห็นได้ว่า เหตุออกหมายค้นตามมาตรา 69 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเป็นไปเพื่อพบวัตถุที่เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด สิ่งของต้องห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง สิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือสิ่งของที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิด ตลอดจนเพื่อพบบุคคลที่ต้องการจับและบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา

สำหรับประเทศอังกฤษกำหนดให้การออกหมายค้นเพื่อพบพยานหลักฐานในการกระทำความผิดจะต้องเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงในระดับ Indictable offence เท่านั้น ดังนั้นศาลจึงไม่อาจออกหมายค้นในความผิดประเภท summary offence ส่วนการออกหมายค้นเพื่อพบสิ่งของต้องห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง สิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือสิ่งของที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดนั้น แม้ว่ามาตรา 8 ของ PACE จะไม่มีกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง แต่ศาลก็มีอำนาจออกหมายค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของดังกล่าวได้เนื่องจากสิ่งของที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดย่อมเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น นอกจากนี้ ตามกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ The Theft Act 1968 ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ และกฎหมายที่เป็นการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการมีสิ่งของบางอย่างไว้ในครอบครอง เช่น Protection of Children Act

1978 ซึ่งกำหนดห้ามการมีรูปลามกของเด็กไว้ในครอบครองก็ได้ระบุให้อำนาจศาลออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของดังกล่าวได้[36]

อย่างไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษไม่ได้กำหนดกรณีการออกหมายค้นเพื่อจับกุมบุคคลไว้ เนื่องจากอำนาจค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีเหตุที่ทำให้มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงแตกต่างจากกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้ศาลสามารถออกหมายค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมบุคคลได้ด้วย

3.2.2 **รายการที่ต้องระบุในหมายค้นและการบังคับตามหมาย**

เหตุที่กฎหมายของประเทศต่างๆ กำหนดรายการที่ต้องระบุในหมายไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาเป็นไปเพื่อให้องค์กรผู้มีหน้าที่ออกหมายพิจารณากำหนดการใช้มาตรการค้นอย่างรอบคอบโดยให้มีผลกระทบต่อผู้ที่จะถูกบังคับโดยหมายน้อยที่สุด ในขณะที่รายการที่ระบุในหมายจะช่วยควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงช่วยให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของหมายทราบเหตุผลและขอบเขตในการค้นเพื่อให้สามารถให้ความร่วมมือในการค้นและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองจากการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการค้นเกินไปกว่าวัตถุประสงค์ในการออกหมายนั้นๆ ได้

สำหรับรายการในหมายค้นที่เป็นสาระสำคัญอันจะขาดไม่ได้เนื่องจากเป็นการแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการค้นโดยตรงคือการระบุ “สถานที่ บุคคล และสิ่งของที่ต้องการค้น” ซึ่งมีหลักการอยู่ว่าการค้นต้องจำกัดสิ่งที่ค้นหรือหมายค้นต้องมีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นหลักกฎหมายคอมมอนลอว์อันมีที่มาจากนโยบายของสหราชอาณาจักรในยุคสมัยที่มีอำนาจปกครองเหนืออาณานิคมต่างๆ และได้กำหนดให้มีการออกหมายทั่วไป (general warrant) ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “writ of assistance” เพื่อใช้ในการค้นหาสินค้าซึ่งหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร และให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปในบ้าน ร้านค้า โกดังเก็บสินค้า รวมทั้งสถานที่อื่นใด เพื่อค้นหาและยึดสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีศุลกากร นอกจากนี้หมายดังกล่าวยังให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการทำลายสิ่งกีดกั้นต่างๆ เช่น ประตู หีบ ห่อ กล่องบรรจุสินค้าที่ต้องสงสัยว่ามีสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีศุลกากรซุกซ่อนอยู่ รวมทั้งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถค้นสถานที่

---

[36]ธิติ สายเชื้อ, “พยานหลักฐานตามสมควรในการที่ศาลจะออกหมายค้น,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549), น. 18.

ใดๆ ก็ได้แม้มีความสงสัยเพียงเล็กน้อย หมายดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องระบุถึงสถานที่ที่จะต้องถูกค้นโดยเฉพาะเจาะจง[37] ซึ่งการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการค้นได้อย่างกว้างขวางด้วยหมายในลักษณะดังกล่าวนำไปสู่การฟ้องร้องคดีที่เป็นที่รู้จักกันดีคือคดี Entick v. Carrington ซึ่งเป็นการออกหมายค้นสถานที่จำนวนมากเพียงเพื่อค้นหาหนังสือที่เขียนโดย John Wilke ซึ่งมีเนื้อหาโจมตีรัฐบาลและกษัตริย์ของอังกฤษ และปรากฏว่าในการค้นบ้านของ Entick เจ้าหน้าที่ได้ยึดหนังสือและเอกสารที่พบทุกอย่างไปจากบ้านของเขา โดยในคดีที่ Entick ได้ฟ้องร้องในเวลาต่อมานั้น ศาลได้วินิจฉัยว่าการออกหมายดังกล่าวเป็นการทำลายความสุขของผู้คนในสังคมและขัดกับหลักกฎหมายที่ดีของอังกฤษ ซึ่งหลักการที่หมายค้นต้องมีความเฉพาะเจาะจงนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานในการออกหมายค้นในประเทศอังกฤษเรื่อยมา ในขณะที่คำพิพากษาดังกล่าวก็ได้รับการยกย่องจากศาลสูงสุดของสหรัฐและเป็นหลักการที่สหรัฐอเมริกาได้ยึดถือเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของตนในเวลาต่อมา ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ว่า “...ในหมายนั้นจะต้องระบุโดยเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่ที่จะถูกค้น บุคคลที่จะถูกจับหรือสิ่งของที่จะถูกยึด”

ในประเทศสหรัฐอเมริกา Rule 41 ตาม Title 18 Crimes and Criminal Procedure ระบุว่าเนื้อหาของหมายค้นจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลหรือทรัพย์ที่ต้องการค้นหา และระบุผู้พิพากษาที่จะเป็นผู้ได้รับหมายค้นคืนเมื่อมีการปฏิบัติการตามหมายเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้หมายค้นต้องระบุว่า

(1) ระบุให้บังคับการตามหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะต้องไม่เกิน 14 วันนับแต่วันที่ออกหมาย ระยะเวลาที่กำหนดนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เช่นรัฐนิวยอร์กระบุให้กระทำภายใน 10 วันนับแต่วันออกหมาย

(2) ระบุให้ค้นในเวลากลางวัน เว้นแต่มีเหตุผลสมควรให้ค้นในเวลาอื่นก็ให้ระบุให้ค้นในเวลาอื่นได้

---

[37] *เพิ่งอ้าง*, น. 19-20.

แนวทางในการระบุสถานที่ในการค้นตามหมายค้นในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องระบุโดยละเอียดทั้งในส่วนของที่ตั้งและลักษณะของสถานที่ที่จะทำการค้น ซึ่งทำให้แม้ระบุเลขที่ของสถานที่นั้นผิดพลาดก็ไม่ทำให้การค้นตามหมายนั้นเสียไป[38]

ส่วนการค้นหาสิ่งของต้องระบุถึงสิ่งของนั้นโดยเฉพาะเจาะจง โดยจะระบุเพียงว่าเพื่อค้นหา “สิ่งของที่หาย” มิได้ เว้นแต่การระบุโดยเฉพาะเจาะจงจะเป็นไปไม่ได้หรือกระทำได้ยาก เช่น ในกรณีที่มีการขโมยสิ่งของจากที่ทำการไปรษณีย์จำนวนมาก ศาลยอมให้ระบุว่า “สิ่งของใดๆ ได้แก่ ธนบัตร และสิ่งของที่อยู่ในระหว่างการจัดส่ง” ซึ่งย่อมรวมถึงจดหมาย แสตมป์ เช็ค และสิ่งของต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ได้ส่งมอบไว้ในความครอบครองของที่ทำการไปรษณีย์แห่งนั้นเพื่อจัดส่งต่อไป หรือเป็นกรณีที่สิ่งของที่ต้องการค้นหามีจำนวนมากและมีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่น การขโมยสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าสตรีจำนวนมากในระหว่างการขนส่ง เป็นต้น[39]

สำหรับการค้นหาสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ศาลกำหนดมาตรฐานที่ต่ำกว่าสำหรับการออกหมายค้นในการกระทำความผิดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการแพร่หลายของยาเสพติด โดยยินยอมให้ระบุในหมายว่า “เพื่อค้นหายาเสพติดและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใช้ หรือการปกปิดซุกซ่อนยาเสพติด” ได้ อย่างไรก็ตาม หากโดยสภาพของสิ่งของต้องห้ามนั้น เจ้าพนักงานสามารถกำหนดรายละเอียดลงในหมายได้ง่าย เช่น การค้นหาอาวุธปืนที่ไม่ได้จดทะเบียน ศาลวินิจฉัยว่าหมายค้นจะต้องระบุเจาะจงถึงชนิด ขนาด สี และลักษณะอื่นใดของอาวุธปืนนั้นด้วย และในกรณีที่เป็นการค้นหาวัตถุลามก ศาลในคดี Lo-ji Sales, Inc. v. New York[40] ได้วินิจฉัยว่าหมายค้นที่ระบุเพียงว่า “เพื่อค้นและยึดวัตถุลามกใดๆ” ไม่เป็นไปตามหลักหมายค้นต้องเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการให้เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าวัตถุใดเป็นวัตถุลามกเองเสียเองในขณะที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาล อีกทั้งไม่มีการกำหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ในหมายค้น[41]

---

[38]John N. Ferdico, Henry F. Fradella & Christopher D. Totten, Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional ,Tenth Edition (California : Wadsworth, 2009), p. 196.

[39]*Ibid,* p. 197.

[40] 442 U.S. 319, 325 (1979)

[41]John N. Ferdico, Henry F. Fradella & Christopher D. Totten, *supra note 38*, pp. 197-198.

ในประเทศอังกฤษ ได้กำหนดให้ในหมายจะต้องประกอบด้วย (1) ชื่อผู้ร้องออกหมาย (2) วันที่ที่ออกหมาย (3) กฎหมายที่ให้อำนาจออกหมายนั้น (3) กลุ่มของสถานที่จะทำการค้น หรือกรณีเป็นหมายค้นไม่จำกัดสถานที่ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองกับระบุเจาะจงสถานที่เท่าที่ทราบ (5) ระบุรายละเอียดของสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการค้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15[42] ของ PACE

การระบุรายละเอียดของสิ่งของที่ค้นหานั้น ต้องพยายามระบุให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่ทำได้ Code of practice for searches of premises by police officers and the seizure of property found by police officers on persons or premises (Code B) จึงได้วางแนวทางว่าในการขอออกหมายค้นสถานที่ตาม PACE ว่า เจ้าพนักงานจะต้องระบุว่ามีความสงสัยว่าจะพบสิ่งของหรือบุคคลนั้นในบริเวณใดของสถานที่นั้นเพื่อประโยชน์ในการระบุขอบเขตการค้นสถานที่โดยเฉพาะในกรณีที่สถานที่นั้นมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่แยกจากกันเป็นสัดส่วน เช่น อพาร์ทเมนท์ หรือบ้านที่แบ่งให้เช่า เป็นต้น ส่วนกรณีที่เป็นการร้องขอให้ออกหมายค้นสถานที่ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ครอบครองโดยไม่จำกัดจำนวนและไม่ระบุเจาะจงสถานที่นั้นเจ้าพนักงานผู้มีคำร้องจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่าเหตุใดจึงต้องค้นสถานที่นอกเหนือจากที่สามารถระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจง และ

---

[42]Sec. 15. Search warrants—safeguards.

[...]

(6) A warrant—

(a) shall specify—

(i) the name of the person who applies for it;

(ii) the date on which it is issued;

(iii) the enactment under which it is issued; and

(iv) each set of premises to be searched, or (in the case of an all premises warrant) the person who is in occupation or control of premises to be searched, together with any premises under his occupation or control which can be specified and which are to be searched; and

(b) shall identify, so far as is practicable, the articles or persons to be sought.

เหตุใดจึงไม่อาจระบุสถานที่ของบุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงทุกสถานที่ได้ นอกจากนี้มาตราเดียวกันของ PACE ยังระบุว่า ศาลอาจระบุไว้ในหมายให้การค้นสถานที่ตามหมายค้นสามารถกระทำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง (more than one occasion) หากเจ้าพนักงานสามารถแสดงได้ว่าเมื่อพิจารณาจากความผิดและลักษณะของสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการค้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำการค้นหลายครั้งจึงจะทำให้การค้นสัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามแม้จะมีการออกหมายค้นในลักษณะดังกล่าว แต่การค้นนอกเหนือจากการค้นครั้งแรกจะยังกระทำมิได้หากไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานในระดับ inspector ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนนั้น

มาตรา 8 ของ PACE ยังได้กำหนดให้มีสำเนาหมายค้นได้โดยต้องระบุว่าเป็นสำเนาและมีข้อจำกัดว่าจะระบุกลุ่มสถานที่ที่จะค้นได้เพียงกลุ่มเดียว อีกทั้งสำเนาหมายค้นนั้นไม่ให้อำนาจค้นสถานที่ที่ระบุมากกว่าหนึ่งครั้ง แม้ว่าในหมายค้นต้นฉบับจะเป็นหมายที่ให้อำนาจค้นสถานที่นั้นได้หลายครั้งก็ตาม

สำหรับประเทศไทย มาตรา 60[43] ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุว่า หมายค้นต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ (1) สถานที่ที่ออกหมาย (2) วันเดือนปีที่ออกหมาย (3) เหตุที่ต้องออกหมาย (4) สถานที่ที่จะค้น และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล หรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น (5) กำหนดวันเวลาที่จะทำการค้น (6) ชื่อกับตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้นนั้น และ (7) ระบุความผิดที่เป็นเหตุในการค้นนั้น

นอกจากนี้ ตามข้อ 20 ของข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ระบุว่า ในหมายค้นที่แนบท้ายคำร้องขอให้ศาลออกหมายค้นจะต้องระบุชื่อและตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการตามหมายค้นและอาจระบุชื่อไว้หลายคนตามคำร้องหากมีเหตุสมควร โดยเจ้าพนักงานดังกล่าวต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไป และหมายค้นต้องระบุวัน ระยะเวลาที่จะเริ่มทำการค้นให้ชัดเจน โดยให้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย หากไม่อาจระบุระยะเวลาสิ้นสุดได้ ให้ระบุว่าค้นติดต่อกันไปจนเสร็จสิ้น การขอหมายค้นโดยกำหนดสถานที่หลายแห่งเกินจำเป็น หรือกำหนดช่วงเวลาไว้หลายวัน เพื่อเลือกกระทำการค้นในวันใดวันหนึ่งจะกระทำไม่ได้ แต่ในกรณีที่สถานที่ที่จะค้นอยู่ห่างไกล อาจขอให้ศาลออกหมายค้นล่วงหน้าได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี

---

[43]ดูมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3.3 หลักการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

แม้ว่าโดยหลักการค้นที่รโหฐานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีหมายค้นที่ออกโดยองค์กรผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่ในหลายๆ ประเทศก็ได้ยอมรับการใช้อำนาจรัฐเพื่อค้นสถานที่โดยไม่มีหมายในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า “...การตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”

3.3.1 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่ได้มีบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กำหนดว่าการค้นโดยไม่มีหมายสามารถกระทำได้หรือไม่และในกรณีใด แต่ศาลฎีกาของทั้งสหรัฐและมลรัฐต่างๆ ก็ได้สร้างแนวคำพิพากษาที่เป็นการตีความรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ว่า แม้การค้นโดยมีหมายค้นซึ่งได้ออกโดยมีเหตุอันควรเชื่อ (probable cause) ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญจะเป็นการค้นที่มีเหตุผลสมควร (reasonable search) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการค้นโดยไม่มีหมายค้นจะกระทำมิได้เสียเลย และการค้นโดยไม่มีหมายในบางกรณีก็เป็นการค้นโดยมีเหตุผลสมควรซึ่งไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สี่ โดยศาลได้ยอมรับการค้นโดยไม่มีหมายค้นในหลายกรณี ดังต่อไปนี้

(1) หลักการค้นฉุกเฉิน (Exigent circumstance search)

(1.1) การค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายต่อบุคคล (imminent danger)

(1.2) การค้นฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวน (investigative emergencies)

การให้อำนาจค้นฉุกเฉินในกรณีนี้เป็นไปเพื่อป้องกันขัดขวางการหลบหนีหรือการทำลายพยานหลักฐานในการกระทำความผิดทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าวต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ กล่าวคือ

1. เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อ (probably cause) ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการหลบหนีหรือการทำลายพยานหลักฐานนั้น

2. ความฉุกเฉินนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ในส่วนของการค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันการหลบหนีประกอบด้วยการค้น 2 กรณีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้[44]

ก. หลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด (Search in hot pursuit)

อำนาจในการค้นสถานที่ในกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานพยายามที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยในที่สาธารณะแต่ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยนั้นได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านของตนหรือสถานที่ของบุคคลอื่น เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจติดตามเข้าไปในสถานที่นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น และการค้นตามหลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิดนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้าที่กำลังหลบหนีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไล่ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับตลอดจนการไล่ติดตามผู้ต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงกับคำให้การของผู้เสียหายด้วย

จะเห็นได้ว่าการไล่ติดตามนี้เป็นการติดตามในทางกายภาพ กล่าวคือต้องมีตัวเจ้าหน้าที่ที่ได้พบตัวผู้ต้องสงสัยและทำให้เกิดการหนีและไล่ติดตามกันมาจนกระทั่งถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและผู้ต้องสงสัยได้หลบเข้าไปในสถานที่นั้น โดยในคดี People v. Patino[45] ศาลได้วินิจฉัยว่าแม้ในการไล่ตามครั้งแรกผู้ต้องหาได้หลบหนีไปสำเร็จ แต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมง เจ้าพนักงานก็ได้พบผู้ต้องหาอีกครั้งและมีการไล่ติดตามเกิดขึ้นอีก เมื่อผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไปในอพาร์ทเมนท์ เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจตามเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น จึงอาจสรุปได้ว่า การค้นสถานที่ที่บุคคลซึ่งถูกไล่ติดตามหลบเข้าไปซ่อนตัวนั้นย่อมกระทำได้เสมอโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นครั้งแรกที่พบตัวเท่านั้น

ข. หลักการไล่ติดตามโดยต่อเนื่อง (Search in fresh pursuit)

การค้นฉุกเฉินในกรณีนี้เป็นการค้นสถานที่เพื่อพบตัวผู้กระทำความผิดอาญาในคดีที่เป็น serious felony ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิดในแง่ที่ว่าการไล่ติดตามโดยต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องมีการไล่ติดตามในทางกายภาพ และไม่จำเป็นต้องมีการติดตามโดยกระชั้นชิดหรือในทันทีทันใดเมื่อพบตัวผู้ต้องสงสัย แต่เจ้าพนักงานจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีความพยายามติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและกระตือรือล้นจนกระทั่งมีเหตุอันควรเชื่อจากข่าวสารที่ได้รับว่าผู้ต้องหาอยู่ในสถานที่นั้นและผู้ต้องหากำลังจะหลบหนี จึงได้ไปยังสถานที่นั้นเพื่อทำการค้นโดยมิล่าช้า

---

[44]The Alameda County District Attorney's Office “Exigent Circumstances,” Point of view, volume 38, Number 1, pp.14-15 (winter, 2010).

[45] (1976) 427 U.S. 38.

สำหรับการพิจารณาว่ามีเหตุอันควรเชื่อที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไม่นั้น ได้มีคำพิพากษาของศาลวางแนวทางว่า อาจพิจารณาได้จากพยานหลักฐานโดยตรงหรือพยาน หลักฐานแวดล้อม ดังต่อไปนี้[46]

คดี People v. Lopez[47] เจ้าพนักงานได้รับรายงานว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งและได้มีผู้ให้การช่วยเหลือโดยการจัดส่งเงินเพื่อช่วยให้ผู้ต้องสงสัยหลบหนีไปยังรัฐเท็กซัส ถือเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีเนื่องจากเจ้าพนักงานมีพยานหลักฐานโดยตรง

คดี People v. McDowell[48] ในคดีนี้เจ้าพนักงานได้ติดตามรอยเลือดจากสถานที่เกิดเหตุจนมาถึงบ้านของผู้ต้องสงสัย ย่อมมีเหตุอันทำให้เจ้าพนักงานเชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีทันทีที่ผู้นั้นได้ตระหนักว่าตนได้ทิ้งร่องรอยดังกล่าวไว้

คดี People v. Kilpatrick[49] เมื่อผู้เสียหายในคดีลักพาตัวหลบหนีออกมาได้ในขณะที่ผู้ต้องหาหลับ และผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความโดยทันที ย่อมเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อได้ว่าทันทีที่ผู้ต้องหารู้ตัวจะต้องหลบหนีไปจากสถานที่นั้น

คดี People v. Gilbert[50] การจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีได้ย่อมเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะรู้ตัวในไม่ช้าและจะหลบหนีไป

นอกจากนี้คำพิพากษาศาลในหลายคดียังได้ยอมรับว่าเจ้าพนักงานย่อมมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีในคดีที่มีความผิดร้ายแรง โดยเฉพาะในความผิดฐานฆ่าคนตาย การค้นสถานที่ในกรณีดังกล่าวโดยไม่มีหมายค้นจึงเป็นการค้นโดยมีเหตุผลอันสมควร

การค้นฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอีกประเภทหนึ่งคือ การค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐาน โดยในการใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้[51]

---

[46]The Alameda County District Attorney's Office, *supra note 44*, pp. 15-16.

[47](1979) 99 Cal. App.3d 754,766.

[48](1988) 46 Cal. 3d 551.

[49](1980) 105 Cal. App. 3d 401,410.

[50](1965) 63 Cal. App. 2d 690,697.

[51]The Alameda County District Attorney's Office, *supra note 44*, pp. 16-19.

1. เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพยานหลักฐานที่อาจถูกทำลายได้อยู่ในสถานที่นั้น การพิสูจน์เหตุอันควรเชื่อเกี่ยวกับการมีพยานหลักฐานในสถานที่นั้นๆ สำหรับความผิดบางประเภท เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ค่อยมีปัญหาดังที่ศาลในคดี People v. Miler[52] ได้กล่าวว่า "หากพิจารณาจากลักษณะของการกระทำความผิดและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบางประเภทแล้ว ศาลผู้มีอำนาจออกหมายย่อมวินิจฉัยได้ว่า ที่อยู่อาศัยของผู้กระทำความผิดนั้นย่อมเป็นสถานที่ที่จะพบพยานหลักฐานในการกระทำความผิด"

2. พยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานในความผิดที่ร้ายแรงซึ่งได้สัดส่วนกับการใช้มาตรการค้นโดยไม่มีหมาย กล่าวคือ การค้นฉุกเฉินในความผิดเล็กน้อยโดยเฉพาะความผิดที่ไม่มีโทษจำคุก เป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐาน

3. เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนที่จะได้รับหมายค้น ซึ่งหมายความว่า เจ้าพนักงานจะต้องสงสัยว่ามีบุคคลอยู่ในสถานที่นั้นและบุคคลดังกล่าวจะพยายามทำลายพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการทำลายพยานหลักฐานจะถือว่าเกิดขึ้นมิได้หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นมิได้ล่วงรู้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจพบการกระทำความผิดของพวกเขาแล้ว[53]

สำหรับการพิจารณาว่ากรณีอย่างใดที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยได้รู้ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังจะทำการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานนั้น อาจพิจารณาได้จากกรณีที่มีเสียงตะโกนจากภายในบ้านหรือภายนอกบ้านว่าตำรวจมาหรือมีพฤติการณ์แสดงถึงความชุลมุนวุ่นวาย มีเสียงเทของทิ้งลงชักโครก หรือเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานมองเห็นสิ่งของผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานจากนอกบ้านและผู้ต้องสงสัยเองก็เห็นเจ้าพนักงานตำรวจ หรือผู้ต้องสงสัยเห็นเพื่อนร่วมห้องกำลังพูดคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

4. ความฉุกเฉินเนื่องจากกำลังจะมีการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานนี้จะต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานเอง ยกตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานจะต้องไม่จงใจแสดงตัวหรือส่งเสียงให้ผู้กระทำความผิดรู้เพื่อให้ผู้กระทำความผิดตกใจและรีบทำลายพยานหลักฐานเพื่อเป็นข้ออ้างในการเข้าค้นสถานที่นั้นโดยไม่มีหมายค้น

---

[52](1978) 85 Cal. App. 3d 194, 204.

[53]U.S. v. Socey (D.C. Cir. 1988) 846 f.2d 1439,1445, fn.6.

(2) หลักการค้นในขณะจับกุม (Search incident to arrest)

ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับว่าการค้นที่ต่อเนื่องจากการจับกุมเป็นข้อยกเว้นที่เร่งด่วนให้กระทำการค้นโดยไม่ต้องมีหมาย ซึ่งหากเป็นการจับโดยชอบในที่รโหฐานแล้ว นอกจากเจ้าพนักงานจะสามารถค้นตัวผู้กระทำผิดได้แล้วเจ้าพนักงานยังสามารถค้นที่รโหฐานนั้นเพื่อที่จะตรวจหาอาวุธซึ่งผู้ถูกจับอาจใช้เพื่อหลบหนีหรือทำอันตรายแก่ชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือทำลายพยานหลักฐานที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อตัวเขา เนื่องจากการจับและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดเป็นการทำให้ผู้ถูกจับสูญเสียอิสรภาพ แม้จะในเวลาอันสั้น แต่ก็ย่อมส่งผลให้ผู้ถูกจับกระทำทุกวิธีทางเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุมหรือความรับผิดซึ่งได้แก่การทำลายเจ้าพนักงานหรือการทำลายพยานหลักฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการกระทำของผู้ถูกจับกุมดังกล่าว ศาลสหรัฐอเมริกาจึงได้สร้างหลักการค้นในกรณีพิเศษเรียกว่า “การค้นในขณะจับกุม” หรือ Search incident to arrest ขึ้น

ทั้งนี้ การค้นในขณะจับกุม เจ้าพนักงานไม่ต้องประเมินความเป็นไปได้ว่าผู้ถูกจับจะมีอาวุธในครอบครอง หรือกำลังปกปิดซ่อนเร้นหรือกำลังจะทำลายพยานหลักฐาน[54] กล่าวคือเจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจค้นที่รโหฐานในขณะจับกุมได้เมื่อมีการจับกุมโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องมีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) ว่าผู้กระทำความผิดมีอาวุธหรือจะมีการทำลายพยานหลักฐาน[55] ดังนั้น เจ้าพนักงานจึงทำการค้นในขณะจับกุมได้แม้ว่าผู้ถูกจับถูกใส่กุญแจมือ หรือเป็นการจับกุมในการกระทำความผิดเล็กน้อย (minor offence) ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่ผู้ถูกจับกุมจะใช้อาวุธในการหลบหนีหรือจะทำลายพยานหลักฐานก็ตาม[56]

---

[54]U.S. v. Chadwick (1977) 433 U.S. 1,15 ; U.S. v. Osife (9th Cir. 2004) 398 F.3d 1143,1145 ; Mary Beth G. v. City of Chicago (7th Cir. 1983) 723 F.2d 1263, 12969.

[55]The Alameda County District Attorney's Office “Search Incident to Arrest” point of view, (2005), pp. 1-2 <http://le.alcoda.org/publications/point_of_view/files/SITA.pdf>.

[56]เดิมศาลสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียเคยวางหลักว่าการค้นในขณะจับกุมจะทำได้ต่อเมื่อเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าเขาจะพบอาวุธหรือพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเท่านั้น แต่ข้อจำกัดดังกล่าวถูกลบล้างโดยแนวคำพิพากษาในเวลาต่อๆ มา ที่วินิจฉัยว่าแม้ในการกระทำความผิดเล็กน้อยเจ้าพนักงานก็มีอำนาจค้นในขณะจับกุมได้ เช่น การจับกุมในความผิดฐานผู้เยาว์มีสุราในครอบครอง (Washington v. Chrisman (1982) 455 U.S. 1) ความผิดฐาน

เงื่อนไขในการค้นในขณะจับกุม ประกอบด้วย[57]

1. มีการจับกุมโดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful arrest) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอำนาจจับกุมโดยชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นทันทีที่มีเหตุอันเป็นไปได้ในการจับกุม ดังนั้น แม้มีการค้นก่อนลงมือจับกุมจริงๆ ก็ถือว่าเป็นการค้นในขณะจับกุม เช่น ในคดี People v. Nieto[58] ศาลวินิจฉัยว่า การยึดพยานหลักฐานก่อนทำการจับกุมกระทำได้หากมีเหตุอันเป็นไปได้ในการจับกุมการกระทำความผิดนั้นในขณะที่เจ้าพนักงานทำการยึดสิ่งของนั้น และหากเจ้าพนักงานได้จับกุมโดยเชื่อว่ามีเหตุอันเป็นไปได้ในการจับกุมความผิดฐานหนึ่งแต่ศาลวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานไม่มีเหตุที่เป็นไปได้ในการจับกุมการกระทำความผิดนั้น การค้นในขณะจับกุมไม่เสียไปหากมีเหตุอันเป็นไปได้ที่เจ้าพนักงานจะจับกุมบุคคลนั้นในความผิดฐานอื่น[59]

2. มีการควบคุมตัวสืบเนื่องจากการจับ (Custodial arrest) ซึ่งหมายความว่า ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในความผิดที่เจ้าพนักงานสามารถควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจได้ ดังนั้น หากเป็นกรณีความผิดที่กำหนดให้เจ้าพนักงานตักเตือนแล้วปล่อยตัวผู้กระทำความผิดไป เช่น ความผิดฐานกระทำผิดกฎจราจรในเหตุเล็กน้อย เจ้าพนักงานย่อมไม่มีอำนาจค้นในขณะจับกุมได้

3. การค้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกับการจับกุม (Contemporaneous search) การค้นขณะจับกุมจะต้องกระทำในทันทีทันใดที่จับกุมโดยไม่ทิ้งช่วงระยะเวลาซึ่งศาลของสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยว่ากรณีต่อไปนี้ไม่ใช่การค้นในขณะเดียวกับการจับกุม ยกตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานไม่ทำการค้นในทันทีหากแต่ใช้เวลานาน 30-45 นาทีในการพูดคุยซักถามผู้ถูกจับกุม หรือเจ้าพนักงานยึดห่อของต้องสงสัยจากรถยนตร์ของผู้ถูกจับแต่ไม่เปิดดูในทันทีและปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึงสี่ชั่วโมง

ดื่มสุราในที่สาธารณะ (People v. Boren (1987) 188 Cal. App.3d 1171,1177) ความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต (U.S. v. Robinson (1973) 414 U.S. 218) เป็นต้น

[57]The Alameda County District Attorney 's Office, *supra note 55*, pp. 2-9.

[58](1990) 219 Cal.App.3d 1275, 1278.

[59]People v. Le (1985) 169 Cal.App.3d 186, 193 ; People v. Rodriguez (1997) 53 Cal.App.4th 1250,1252-6.

เมื่อเงื่อนไขในการค้นเกิดขึ้นทั้งสามประการแล้ว เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจค้นในขณะจับกุมได้ทั้งในส่วนของการค้นตัวผู้ถูกจับกุม (Suspect on the scene) และการค้นสถานที่ที่เกิดการจับกุม (Search at the arrest scene) อย่างไรก็ตาม ในการค้นสถานที่ที่จับกุมเจ้าพนักงานมีอำนาจค้นในขอบเขตที่จำกัดตามหลัก Immediate control test หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chimel search เนื่องจากคำพิพากษาในคดี Chimel เป็นคดีแรกที่วางหลักในการจำกัดการค้นในขณะจับกุมว่าจะกระทำการค้นที่รโหฐานในบริเวณทั้งหมดมิได้ หากแต่จะกระทำได้เพียงบริเวณที่อยู่ในความควบคุมของผู้ถูกจับกุม กล่าวคือ บริเวณที่ผู้ต้องหาสามารถเอื้อมไปถึง

ทั้งนี้ คำว่า “บริเวณที่เอื้อมไปถึง” หมายความว่า บริเวณที่บุคคลดังกล่าวอาจไปถึงในขณะที่รู้ตัวว่าจะถูกจับกุม หรืออาจไปถึงหากเจ้าพนักงานมิได้มาปรากฏตัว ณ ที่นั้น

ในคดี Giacalone v. Lucas[60] ศาลวินิจฉัยว่า หากผู้ถูกจับโดยความสมัครใจไปยังบริเวณอื่นของที่รโหฐานนอกเหนือจากบริเวณที่เขาถูกจับ เจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ติดตามควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวมิให้หลบหนีย่อมมีอำนาจค้นที่รโหฐานในบริเวณดังกล่าวซึ่งผู้ถูกจับสามารถหยิบอาวุธหรือทำลายพยานหลักฐานเสียได้ ซึ่งมีความหมายว่าเจ้าพนักงานจะสั่งให้ผู้ถูกจับเคลื่อนที่ไปอยู่ใกล้ๆ สิ่งของหรือบริเวณใดเพื่อให้ตนสามารถใช้อำนาจค้นในขณะจับกุมมิได้[61]

นอกจากนี้ ศาลวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานสามารถค้นห้องที่อยู่ติดต่อกับห้องที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมได้หากเห็นบุคคลดังกล่าวยืนอยู่บริเวณประตูซึ่งเชื่อมต่อห้องทั้งสอง[62] ส่วนในบริเวณอื่นนอกเหนือจากนี้ เจ้าพนักงานจะค้นได้ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินในการค้น

3.3.2 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายในประเทศอังกฤษ

ตาม Police and Criminal Evidence Act 1984 หรือ PACE ได้แยกประเภทของการค้นสถานที่โดยไม่มีหมายเป็น 3 ประเภท ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจับกุม ดังนี้

1) การค้นสถานที่เพื่อจับกุม

ตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นการกำหนดให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าค้นสถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจับกุม

---

[60] 445 F. 2d 1238 (6th Cir. 1971)

[61] U.S. v. Perca, 986 F.2d 633 (2d Cir. 1993)

[62] People v. Maier (1991) 226 Cal.App.3d 1670, 1675.

บุคคลที่กระทำความผิดอาญา อย่างไรก็ตาม มาตรานี้ยังเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ค้นได้โดยไม่มีหมายเพื่อบังคับตามหมายที่ออกโดยศาลมาจิสเตรทตามมาตรา 74 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยศาลมาจิสเตรท รวมถึงการค้นสถานที่เพื่อช่วยชีวิต ป้องกันอันตรายต่อกาย หรือป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของบุคคล โดยในส่วนของอำนาจค้นสถานที่โดยไม่มีหมายค้นเพื่อจับกุมบุคคลตามมาตรา 17 จะเป็นการค้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. เพื่อบังคับตามหมายจับในคดีอาญา[63]

2. เพื่อจับกุมผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาประเภท indictable offences[64]

3. เพื่อจับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นตามที่ได้ระบุไว้ในมาตราดังกล่าว เช่น เพื่อการจับกุมบุคคลที่กระทำความผิดอาญาฐานเข้าไปในสถานที่ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานทำให้กลัวหรือขู่ว่าจะทำอันตรายต่อบุคคลอื่น ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันการกระทำทารุณกรรมต่อสัตว์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความผิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่โดยสภาพต้องให้อำนาจเจ้าหน้าที่จับตัวบุคคลออกไปโดยทันทีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง หรือการบังคับจับตัวบุคคลมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ หรือเพื่อตามจับกุมบุคคลที่หลบหนีจากการจำคุกหรือการควบคุมตัวในกรณีใดๆ กลับคืนมา[65]

---

[63]Sec. 17. Entry for purpose of arrest etc.

(1) Subject to the following provisions of this section, and without prejudice to any other enactment, a constable may enter and search any premises for the purpose—

(a) of executing—

(i) a warrant of arrest issued in connection with or arising out of criminal proceedings; or

(ii) a warrant of commitment issued under section 76 of the Magistrates' Courts Act 1980 [...]

[64](b) of arresting a person for an indictable offence;

[65](c) of arresting a person for an offence under—

(i) section 1 (prohibition of uniforms in connection with political objects) of the Public Order Act 1936;

4. เพื่อจับกุมบุคคลที่เจ้าพนักงานกำลังไล่ติดตามและได้หลบหนีเข้าไปในสถานที่นั้น[66]

(ii) any enactment contained in sections 6 to 8 or 10 of the Criminal Law Act 1977 (offences relating to entering and remaining

(iii) section 4 of the Public Order Act 1986 (fear or provocation of violence);

(iiia) section 4 (driving etc. when under influence of drink or drugs) or 163 (failure to stop when required to do so by constable in uniform) of the Road Traffic Act 1988;

(iiib) section 27 of the Transport and Works Act 1992 (which relates to offences involving drink or drugs);

(iv) section 76 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994 (failure to comply with interim possession order);

(v) any of sections 4, 5, 6(1) and (2), 7 and 8(1) and (2) of the Animal Welfare Act 2006 (offences relating to the prevention of harm to animals);

(ca) of arresting, in pursuance of section 32(1A) of the Children and Young Persons Act 1969, any child or young person who has been remanded or committed to local authority accommodation under section 23(1) of that Act;

(caa) of arresting a person for an offence to which section 61 of the Animal Health Act 1981 applies;

(cb) of recapturing any person who is, or is deemed for any purpose to be, unlawfully at large while liable to be detained—

(i) in a prison, remand centre, young offender institution or secure training centre, or

(ii) in pursuance of section 92 of the Powers of Criminal Courts (Sentencing Act 2000) (dealing with children and young persons guilty of grave crimes), in any other place;

[66](d) of recapturing any person whatever] who is unlawfully at large and whom he is pursuing; or [...]

2) การค้นสถานที่ขณะจับกุม

ในขณะที่เจ้าพนักงานกระทำการจับกุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากเจ้าพนักงานผู้นั้นจะมีอำนาจตรวจค้นตัวผู้ถูกจับกุมเพื่อยึดสิ่งของหรืออาวุธที่จะเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น หรือถูกใช้ในการหลบหนี ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้ว มาตรา 32 (2) (b)[67] ยังได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการตรวจค้นสถานที่หากบุคคลนั้นถูกจับกุมในความผิดอาญาร้ายแรงเพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น โดยสถานที่ที่เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจค้น ได้แก่

1. สถานที่ที่บุคคลนั้นอยู่ในขณะถูกจับกุม

2. สถานที่ที่บุคคลนั้นเพิ่งเข้าไปในทันทีทันใดก่อนถูกจับกุม

ทั้งนี้ มาตรา 32 (6) ได้ระบุว่าการค้นสถานที่ดังกล่าวจะกระทำมิได้หากไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีพยานหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสถานที่นั้น และ (7) ของมาตราเดียวกันระบุว่าหากสถานที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งแยกออกจากกันได้ อำนาจค้นสถานที่จะจำกัดเฉพาะการค้นในส่วนที่ผู้นั้นอยู่ในขณะถูกจับกุมหรือเพิ่งเข้าไปในทันทีทันใดก่อนถูกจับกุม หรือการค้นพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสถานที่นั้นซึ่งได้จัดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น

หลักการค้นที่รโหฐานของบุคคลภายนอกซึ่งผู้ต้องหาอยู่ในขณะถูกจับกุมนี้เป็นหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ตามคำพิพากษาในคดี Ghani v. Jones[68] ซึ่งผู้พิพากษา คือ

---

[67]Sec. 32. Search upon arrest.

[...]

(2) Subject to subsections (3) to (5) below, a constable shall also have power in any such case—

(a) to search the arrested person for anything—

(i) which he might use to assist him to escape from lawful custody; or

(ii) which might be evidence relating to an offence; and

(b) if the offence for which he has been arrested is an indictable offence, to enter and search any premises in which he was when arrested or immediately before he was arrested for evidence relating to the offence.

[68]Ghani v. Jones, [1969] 3 All E.R. 1700.

Lord Denning ได้ให้เหตุผลว่าพลเมืองผู้บริสุทธิ์มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าพนักงานในการปราบปรามการกระทำความผิดโดยต้องไม่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดในการซุกซ่อนพยานหลักฐาน แต่ก็ได้วางหลักเกณฑ์ในการค้นเพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลมิให้ถูกกระทบจากการค้นในกรณีดังกล่าวจนเกินควร ดังนี้

ก. การค้นที่รโหฐานที่ผู้ถูกจับกุมอยู่ในขณะจับกุมจะต้องเป็นการค้นสืบเนื่องจากการกระทำความผิดร้ายแรง (a serious offence)

ข. เจ้าพนักงานเชื่อว่ามีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิด ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในความผิดอยู่ในสถานที่นั้น

ค. เจ้าพนักงานเชื่อว่าผู้ครอบครองสถานที่นั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด เป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนกระทำความผิด หรืออย่างน้อยที่สุดผู้ครอบครองสถานที่ปฏิเสธการค้นโดยไม่มีเหตุผลสมควรอย่างยิ่ง

ง. เจ้าพนักงานจะต้องไม่ยึดหรืออายัดสิ่งของนั้นเป็นระยะเวลานานเกินกว่าความจำเป็นเพื่อทำให้การสอบสวนคลุ่วง

3) การค้นสถานที่ภายหลังการจับกุม

กฎหมายอังกฤษได้บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้าไปและค้นสถานที่ที่ผู้ถูกจับในคดีความผิดอาญาร้ายแรง (indictable offence) เป็นผู้ครอบครองดูแลหากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น หรือมีพยานหลักฐานในคดีอาญาร้ายแรงอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกับการกระทำความผิดนั้น ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 18[69] ของ PACE

---

[69]Sec. 18. Entry and search after arrest.

(1) Subject to the following provisions of this section, a constable may enter and search any premises occupied or controlled by a person who is under arrest for an indictable] offence, if he has reasonable grounds for suspecting that there is on the premises evidence, other than items subject to legal privilege, that relates—

(a) to that offence; or

(b) to some other indictable offence which is connected with or similar to that offence.

[...]

constable may conduct a search under subsection (1)—

ทั้งนี้ การค้นในกรณีนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นการค้นก่อนที่จะนำตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจหรือก่อนที่จะได้รับการประกันตัวภายใต้มาตรา 30 A และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานในระดับ inspector หรือระดับที่สูงกว่า

ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่า การนำตัวบุคคลที่ถูกจับไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อทำการค้นมีความจำเป็น (necessary) เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวน (Effective investigation) ยิ่งกว่าการนำตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจ ซึ่งได้แก่ การที่เจ้าพนักงานเชื่อว่ามีพยานหลักฐานที่จะถูกโยกย้ายทำลายหากเจ้าพนักงานไม่พาผู้ถูกจับกุมไปค้นที่รโหฐานที่เขาครอบครองดูแลในทันใด[70] ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งต่อพนักงานผู้อื่นในระดับ inspector หรือระดับที่สูงกว่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายหลังจากที่ได้ทำการค้น

เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับแจ้งการค้นมีหน้าที่ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุในการทำการค้น ลักษณะของพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นนั้น โดยหากบุคคลที่ถูกจับกุมยังคงอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานตำรวจในขณะที่ทำบันทึก เจ้าพนักงานอาจทำบันทึกดังกล่าวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการจับกุม

---

(4) Subject to subsection (5) below, the powers conferred by this section may not be exercised unless an officer of the rank of inspector or above has authorised them in writing.

(5) A constable may conduct a search under subsection (1)

(a) before the person is taken to a police station or released on bail under section 30A, and

(b) without obtaining an authorisation under subsection (4), if the condition in subsection (5A) is satisfied.

(5A) The condition is that the presence of the person at a place (other than a police station) is necessary for the effective investigation of the offence.[...]

[70]M.D. A. Freeman, The Police and Criminal Evidence Act 1984, (London : Sweet & Maxwell, 1985), p. 19.

3.3.3 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายตามกฎหมายไทย

มาตรา 92 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น ความมุ่งหมายของข้อยกเว้นนี้ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานเข้าไปช่วยเหลือผู้ร้องขอให้ช่วยได้ทันท่วงที แต่ไม่จำกัดว่าจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยเท่านั้น ถ้าเป็นพฤติการณ์อื่นอันแสดงว่ามีเหตุร้าย เช่น มีเสียงคนทะเลาะกัน หรือมีเสียงปืนดังในบ้านก็สามารถเข้าไปค้นที่รโหฐานนั้นได้[71]

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน ความผิดซึ่งหน้าหมายความว่าซึ่งหน้าเจ้าพนักงานผู้ค้น ไม่ใช่ซึ่งหน้าบุคคลอื่นแล้วมาบอกกล่าวต่อเจ้าพนักงานอีกทอดหนึ่ง โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในฎีกาที่ 481/2491 ว่า เจ้าพนักงานต้องเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้าด้วยตนเอง ความผิดซึ่งหน้า อาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่มีโทษในทางอาญาก็ได้[72] โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นประเภทตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[73] เช่น

เจ้าพนักงานตำรวจเห็นคนหลายคนกำลังเล่นการพนันกันอยู่บนบ้านถือเป็นความผิดซึ่งหน้า หากไม่จับทันทีก็อาจจับผู้กระทำความผิดไม่ได้เลยเพราะปนเปกันอยู่มากทั้งบรรดาพยานหลักฐานทั้งหลายก็อาจสูญเสียหรือถูกทำลายไปหมด จึงเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ผู้เสียหายกับพวกจึงมีอำนาจเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุอันเป็นที่รโหฐานตามมาตรา 92 (2)[74]

เจ้าพนักงานตำรวจเห็นจำเลยซึ่งอยู่ในห้องนอนโยนเมทแอมเฟตามีนออกไปนอกหน้าต่าง เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจพบจำเลยกำลังกระทำความผิดซึ่งหน้าและได้กระทำลงในที่รโหฐาน เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจจับจำเลยโดยไม่มีหมายจับ หรือหมายค้น[75]

---

[71]คนึง ฦาไชย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10*, น. 274.

[72]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25*, น. 439.

[73]คนึง ฦาไชย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10*, น. 274-275.

[74]คำพิพากษาฎีกาที่ 698/2516 (ประชุมใหญ่) 2516 ฎ. 2149.

[75]คำพิพากษาฎีกาที่ 1164/2546 ฎ. 1862.

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น กรณีนี้เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานพบบุคคลกระทำความผิดซึ่งหน้าและจะเข้าจับกุมและผู้กระทำความผิดหนีเข้าไปในที่รโหฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานนั้นเอง หรือเจ้าพนักงานพบผู้กระทำซึ่งหน้าแล้วไล่จับแต่คลาดสายตาไป แต่มีเหตุแน่นแฟ้นอันควรสงสัยว่าเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐาน เช่น มีพลเมืองดีหลายคนบอกให้ทราบ หรือในบริเวณที่นั้นมีที่รโหฐานนั้นอยู่แห่งเดียว เป็นต้น

ความผิดซึ่งหน้าจะต้องเกิดขึ้นจริง ลำพังแต่พฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะกระทำความผิดยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะให้เจ้าพนักงานมีอำนาจติดตามเข้าไปในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายได้[76]

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่รโหฐานนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน การค้นโดยไม่มีหมายค้นในกรณีนี้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขของอำนาจทั้งสองประการ คือ

เงื่อนไขประการแรก คือ มีพยานหลักฐานตามสมควรว่า มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิด อยู่ในที่รโหฐานนั้น

เงื่อนไขประการที่สอง คือ มีเหตุอันควรเชื่อว่า หากเจ้าพนักงานไม่เข้าค้นที่รโหฐานในทันทีจะทำให้สิ่งของนั้นถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78

คำว่า “เจ้าบ้าน” ตามฎีกาที่ 1035/2536[77] วินิจฉัยว่า หมายความถึง ผู้เป็นหัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นและรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้าด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้นทุกคน ทั้งนี้ การจับเจ้าของบ้านในบ้านของเขานั้น มาตรา 92 (5) ให้อำนาจเจ้าพนักงานผู้จับเข้าไปจับในบ้านได้แม้การเข้าไปในบ้านจะถือว่าเป็นการ “ค้น” บ้านนั้น แต่มาตรา 92 (5) ก็ยอมให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่การจับจะต้องกระทำโดยชอบกล่าวคือมี

---

[76]คนึง ฦาไชย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10*, น. 276.

[77]คำพิพากษาฎีกาที่ 1035/2536 ฎส. 8 น. 83.

หมายจับหรือจับโดยไม่มีหมายตามมาตรา 78 ส่วนกรณีที่ได้มีการจับกุมตัวได้แล้ว ในระหว่างที่จะนำตัวผู้ถูกจับไปส่งที่สถานีตำรวจ ได้มีการหลบหนีเข้าไปในบ้านที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าบ้าน การวิ่งหนีหลังจากถูกจับและมีการควบคุมตัวไว้แล้ว แม้จะเป็นการควบคุมตัวในบริเวณที่ทำการจับก็เป็นการหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกคุมขังซึ่งเป็นการกระทำความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 190 และเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานจึงมีอำนาจเข้าไปในที่รโหฐานเพื่อจับกุมตามมาตรา 92 (3)

อย่างไรก็ตาม แม้ตามความเห็นของนักกฎหมายไทยส่วนใหญ่จะเห็นว่าการเข้าไปค้นในกรณีนี้จะเป็นการค้นเพื่อจับกุมเท่านั้น เนื่องจากมาตรา 92 (5) บัญญัติว่า “เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78” แต่เมื่อพิจารณาระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 4 การค้น ข้อ 74 ซึ่งระบุว่า “(5) เมื่อที่รโหฐานที่จะทำการค้นนั้น ผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นได้มีหมายจับ หรือผู้จับมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มีอำนาจค้นเพื่อหาตัวคนและสิ่งของกลางนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น” ประกอบกับหากตีความว่าการค้นโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 (5) เป็นการเข้าไปเพื่อจับเท่านั้น จะมีปัญหาว่าการไม่ให้อำนาจเจ้าพนักงานทำการค้นและยึดพยานหลักฐานในการกระทำความผิดจะเหมาะสมหรือไม่ เพราะหากต้องขอหมายค้นมาอีกครั้ง พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้ายทำลายไปแล้วโดยความช่วยเหลือของบุคคลอื่นในที่รโหฐานนั้น ซึ่งหากเทียบเคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษแล้ว ต่างก็ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานในขณะจับกุมได้

อนึ่ง เมื่อพิจารณา The Police and Criminal Evidence Act 1984 หรือ PACE ซึ่งเป็นกฎหมายหลักว่าด้วยการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานในประเทศอังกฤษแล้ว จะเห็นได้ว่า PACE ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานทำการค้นโดยไม่มีหมายค้นเพียงเพราะเหตุว่าเจ้าพนักงานเชื่อว่ากำลังจะมีการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานก่อนที่จะขอหมายค้นจากศาลได้ ตามหลัก Exigent-circumstance ของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรา 92 (4) ของประเทศไทย แต่การค้นโดยไม่มีหมายตาม PACE จะกระทำได้เมื่อมีเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับการจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นหลัก

3.4 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการออกหมายค้นและการค้นโดยไม่มีหมาย

การพิจารณาว่าข้อเท็จจริงอย่างไรที่เป็นเหตุสนับสนุนให้ศาลออกหมายค้นหรือเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานทำการค้นโดยไม่มีหมายนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องอำเภอใจของผู้พิพากษาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคน หากแต่จะต้องมีกรอบในการใช้ดุลยพินิจหรือมีมาตรฐานในการพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของเหตุในการค้นนั้นๆ ด้วย

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักการที่ใช้ในการพิจารณาออกหมายค้นหรือหมายจับบุคคลซึ่งถูกบัญญัติไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ (The Fourth Amendment) เรียกว่า หลักเหตุที่เป็นไปได้ หรือ probable cause โดยสำหรับการค้นที่รโหฐานนั้น ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับว่าหลักเหตุที่เป็นไปได้เป็นมาตรฐานในการใช้อำนาจค้นที่รโหฐานทั้งในฐานะที่เป็นเหตุในการออกหมายค้น และเป็นเหตุให้เข้าค้นที่รโหฐานได้โดยไม่มีหมายตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ความหมายของ probable หรือ “ความเป็นไปได้” ในพจนานุกรมโดยทั่วไปหมายถึง “น่าจะเป็นจริงมากกว่าไม่จริง” (more likely than not)) หรือมีสัดส่วนระหว่างความจริงกับไม่จริงอยู่ที่ 51/49 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการให้ความหมายของถ้อยคำดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายฉบับใดแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ซึ่งเป็นที่มาของหลักการดังกล่าว โดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ระยะเวลายาวนานในการตีความความหมายและขอบเขตของเหตุที่เป็นไปได้ในการค้นที่รโหฐาน โดยในปี 1813 ศาลสูงสุดของสหรัฐในคดี Locke v. U.S., 11 U.S. (7 Cranch) ซึ่งเป็นคดีแรกที่ได้ให้คำนิยามของคำว่า “เหตุที่เป็นไปได้” โดยในคดีดังกล่าว ผู้พิพากษา Justice Marshall Locke ได้วินิจฉัยว่า หลักเหตุที่เป็นไปได้ หรือ Probable cause เป็นมาตรฐานที่ต่ำกว่า “หลักพยานหลักฐานที่ดีกว่า” (preponderance of the evidence standard) และไม่ใช่ “ข้อสันนิษฐานบนพื้นฐานของพยานหลักฐาน” (presumptive evidence) แต่ “เหตุที่เป็นไปได้” คือพฤติการณ์ซึ่งทำให้มีเหตุอันควรสงสัยที่จะออกหมาย โดยแนวทางดังกล่าวได้รับการยอมรับโดยศาลสูงสุดของสหรัฐและรัฐอื่นๆ เป็นเวลานานถึง 11 ปี จนกระทั่ง

ศาลสูงสุดของสหรัฐโดยผู้พิพากษา Joseph Story ในคดี Apollon[78] ได้กลับคำวินิจฉัยว่า “เหตุที่เป็นไปได้” จะต้องอ้างอิงพยานหลักฐาน และไม่เป็นเพียงความสงสัยลอยๆ (general suspicion)[79]

แม้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่จะระบุว่าการค้นในที่รโหฐานจะต้องเป็นไปตามหลัก Probable cause ก็ตาม แต่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนปี 1968 ก็ได้ใช้คำว่า “Probable cause” “reasonable believe” “reasonable cause” และ “reasonable suspicion” ปะปนกันในการอธิบายกระบวนการดังกล่าว จนกระทั่งมีคำพิพากษาบรรทัดฐานในคดี Terry v. Ohio[80] ที่วินิจฉัยว่าอำนาจของเจ้าพนักงานในการเรียกให้บุคคลหรือยานพาหนะในทางสัญจรหยุดเพื่อถามข้อมูลตลอดจนทำการตรวจค้นซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลน้อยกว่าการค้นที่รโหฐานและการจับกุมจึงไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ probable cause โดยการใช้อำนาจดังกล่าวต้องการเพียงความสงสัยตามสมควร หรือ reasonable suspicion ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลที่เป็นการอธิบายความแตกต่างของหลัก probable cause และหลัก reasonable suspicion อย่างชัดเจน แต่ก็ได้มีนักวิชาการที่ได้ให้ความเห็นไว้ ยกตัวอย่างเช่น[81]

Wayne R. LaFave กล่าวว่า probable cause คือความเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริง ในขณะที่ reasonable suspicion คือ ความสงสัยอย่างมีเหตุผลว่าผู้ต้องหาดังกล่าวอาจจะกระทำความผิด[82]

---

[78]22 U.S. (9 Wheat.) 362 (1824)

[79]Craig S. Lerner, “The Reasonableness of Probable Cause,” George Mason Law & Economics Research Paper No. 05-18; Texas Law Review, Vol. 81, No. 4, pp. 981-984.

[80] 392 U.S. 1, 5–7 (1968).

[81]Kit Kinports, “Diminishing Probable Cause and Minimalist Search,” Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 6, 649, pp. 653-655 (2009).

[82]Wayne R. Lafave, Search and Seizure, 4th edition (2004) quoted in Kit Kinports, *supra note 72*, p. 654.

Silas J. Wasserstrom เห็นว่า probable cause คือ ความเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริง ส่วน reasonable suspicion คือ ความเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด[83]

นอกจากนี้ ในคดี United States v. Knights[84] ศาลวินิจฉัยว่าการค้นบ้านของบุคคลที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ไม่จำเป็นต้องมีเหตุที่เป็นไปได้ เพียงแต่มีความสงสัยตามสมควรก็เพียงพอ โดยให้เหตุผลว่า เมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของรัฐที่เกิดจากการใช้มาตรการที่ต่ำกว่าและผลเสียต่อประโยชน์ของเอกชนแล้ว การค้นดังกล่าวยังมีความสมเหตุสมผลในทางกลับกัน คำพิพากษาในคดี Maryland v. Pringle ได้วินิจฉัยไว้ว่า การที่ Pringle เพียงแต่นั่งข้างๆ คนขับอยู่ในรถที่มีคนนั่งอยู่สามคน โดยมีถุงใส่โคเคนอยู่บนเบาะหลังใกล้ๆ กับผู้โดยสารอีกคน ไม่เป็นพยานหลักฐานที่เพียงพอจะแสดงถึง “เหตุที่เป็นไปได้” ซึ่งให้อำนาจเจ้าพนักงานจับ Pringle ในความผิดฐานมีโคเคนในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น พยานหลักฐานที่เพียงพอจะใช้ในการสนับสนุนเหตุที่เป็นไปได้ต้องพิจารณาระดับความรุนแรงของการกระทำความผิดเพื่อให้มีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการค้นในที่รโหฐานนั้นเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วย กล่าวคือ ในคดีที่เป็นการกระทำความผิดที่รุนแรงน้อยกว่าหรือมีประโยชน์ต่อสังคมน้อยกว่า เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้เยาว์ ย่อมต้องใช้มาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงกว่าคดีที่มีความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม[85]

ทั้งนี้ Lerner ได้เสนอไว้ในบทความ เรื่อง The Reasonableness of Probable Cause ว่า จะถือว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งมี “เหตุที่เป็นไปได้” ต่อเมื่อ “มีความเป็นไปได้ที่สังคมจะได้รับประโยชน์จากความสำเร็จในการค้นเกินกว่าผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล”[86]

สำหรับในประเทศอังกฤษมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับใช้อำนาจค้นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญสองประการซึ่งปรากฏใน PACE คือ

---

[83]Silas J. Wasserstrom, “The Incredible Shrinking Fourth Amendment,” 21 AM. CRIM. L.REV, 257, pp. 327–329 (1984) quoted in Kit Kinports, *supra note 72*, p. 654.

[84] 534 U.S. 112, 121 (2001).

[85]Timothy P. O’Neill, “Lawyers’ Forum : Scope of ‘probable cause’ probably will widen,” Chicago Daily Law Bulletin, p.6 (Friday, May 9, 2003).

[86]Craig S. Lerner, *supra note 79*, pp. 1019-1022.

(1) เหตุอันควรเชื่อ หรือ reasonable grounds for believing ซึ่งใช้กับการพิจารณาออกหมายค้นตามมาตรา 8[87] และการค้นโดยไม่มีหมายเพื่อจับกุมบุคคลตามมาตรา 17[88]

(2) เหตุอันควรสงสัย หรือ reasonable grounds for suspect เป็นมาตรฐานในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานในการค้นสถานที่โดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 18[89] ซึ่งเป็นการค้นสถานที่ภายหลังการจับกุม การเรียกให้ยานพาหนะหรือบุคคลหยุดเพื่อการตรวจค้น รวมถึงการจับโดยไม่มีหมายจับ โดย reasonable grounds for suspect เกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานต้องมีเหตุที่จะกล่าวอ้างได้ชัดเจนหรือเป็นประจักษ์ในความสงสัยนั้น และสิ่งนั้นบุคคลทั่วไปก็เห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้สงสัยได้เช่นกัน reasonable grounds for suspect จึงต่างจากความสงสัยธรรมดาหรือ mere suspect ซึ่งเป็นแค่ความสังหรณ์ใจหรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถอธิบายหรือตัดสินว่าถูกต้องตรงกันได้ในสายตาของบุคคลทั่วไป

สำหรับปัญหาว่า เหตุอันควรเชื่อกับเหตุอันควรสงสัยมีความแตกต่างกันอย่างไรนั้น Lord Devlin ได้อธิบายว่าความสงสัยตามความหมายธรรมดาคือ การคาดเดา (conjecture) หรือการนึกคิดเอาเอง (surmise) ซึ่งไม่มีการพิสูจน์ ดังนั้น ความเชื่อจึงหมายถึงการมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำลายการคาดเดาหรือการนึกคิดเอาเองและยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เป็นจริง และหาก

---

[87]Sec. 8. Power of justice of the peace to authorise entry and search of premises.

— (1) If on an application made by a constable a justice of the peace is satisfied that there are reasonable grounds for believing—

(a) that an indictable offence has been committed; and [...]

[88]Sec. 17. Entry for purpose of arrest etc.

(2) Except for the purpose specified in paragraph (e) of subsection (1) above, the powers of entry and search conferred by this section—

[...]

(a) are only exercisable if the constable has reasonable grounds for believing that the person whom he is seeking is on the premises; and [...]

[89]Sec. 18. Entry and search after arrest.

(1) Subject to the following provisions of this section, a constable may enter and search any premises occupied or controlled by a person who is under arrest

เปรียบเทียบกับการนับหนึ่งถึงสิบแล้ว ระดับของเหตุอันควรสงสัย (reasonable grounds for suspect) จะอยู่ที่ช่วงต่ำกว่าขั้นที่สองหรือสาม ในขณะที่เหตุอันควรเชื่อ (reasonable grounds for believing) อาจจะอยู่สูงในช่วงระดับเก้าถึงสิบเลยก็ได้[90]

สำหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59/1 ได้กำหนดว่าก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏ “พยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้น ตามมาตรา 69” โดยหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 15 กำหนดว่าผู้ร้องขอต้องเสนอพยานหลักฐานที่ “น่าเชื่อ” ว่า

(1) บุคคลหรือสิ่งของที่ค้นหาน่าจะอยู่ในสถานที่ที่จะค้น และ

(2) สิ่งของหรือบุคคลนั้นเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลที่เป็นเหตุในการออกหมายค้น เช่น ในกรณีค้นหาสิ่งของ สิ่งของนั้นจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา เป็นต้น โดยในการรับฟังพยานหลักฐาน ศาลไม่จำต้องถือเคร่งครัดเช่นเดียวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิดของจำเลย

จากถ้อยคำที่ได้บัญญัติในมาตรา 59 และข้อ 15 ของข้อบังคับดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่า กรอบในการออกหมายค้นของไทยมีลักษณะเดียวกับหลัก probable cause ของประเทศสหรัฐอเมริกา และหลัก reasonable for believing ของประเทศอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม กรณีการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 ปรากฏว่าการระบุกรอบการใช้ดุลยพินิจในลักษณะเดียวกับมาตรา 69 มีอยู่เฉพาะในอนุมาตรา 3 ตอนท้าย ที่ระบุว่า มี “เหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัย” ว่าบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น และอนุมาตรา 4 ที่ระบุว่าเมื่อ “มีพยานหลักฐานตามสมควร” ว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น

---

for an indictable] offence, if he has reasonable grounds for suspecting that there is on the premises evidence, other than items subject to legal privilege, that relates—

[90]Vaughan Bevan and Ken Lidstone, The Investigation of crime a guide to Police Powers, (Landon : Butterworths, 1991), p. 5. อ้างใน ธิติ สายเชื้อ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 36*, น. 72.

ประกอบทั้งต้อง “มีเหตุอันควรเชื่อ” ว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน ในขณะที่อนุมาตราอื่นไม่มีการระบุถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวไว้

3.5 วิธีการค้นที่รโหฐาน

3.5.1 ช่วงเวลาที่ทำการค้น

(1) หลักการค้นต้องกระทำตอนกลางวัน

การค้นที่รโหฐานต้องกระทำในช่วงเวลาใดนั้น ย่อมต้องยึดถือหลักที่ว่าการค้นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนจนเกินสมควร การค้นที่รโหฐานจึงสมควรกระทำในเวลากลางวันอันเป็นช่วงเวลาที่ยังมีแสงสว่างซึ่งทำให้การตรวจค้นกระทำได้โดยสะดวกและยังไม่มีผลเป็นการรบกวนช่วงเวลาการพักผ่อนของบุคคลที่อยู่ในเคหสถานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดความผิดเรื่องการบุกรุกและลักทรัพย์ที่กฎหมายอาญาไทยได้กำหนดให้ผู้กระทำผิดต้องรับโทษหนักขึ้นหากการบุกรุกหรือลักทรัพย์นั้นได้กระทำในยามวิกาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิในเคหสถานที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมาตรา 96 จึงได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัดว่าการค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษพบว่ากฎหมายของทั้งสองประเทศดังกล่าวได้กำหนดช่วงเวลาในการทำการค้นที่แตกต่างจากของประเทศไทย กล่าวคือ ตาม section 16 ของ Police and Criminal Evidence Act 1984 กำหนดว่าการค้นต้องกระทำในช่วงเวลาอันเหมาะสม หรือ reasonable hour[91] ซึ่งโดยทั่วไปก็คือเวลากลางวัน อย่างไรก็ตาม คำว่า ช่วงเวลาอันเหมาะสมนี้ ย่อมเป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อสถานที่ที่จะทำการค้น ตลอดจนสิ่งของและบุคคลที่ต้องการค้นหา ด้วยเหตุนี้ หากสถานที่ที่ทำการค้นเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือภายในช่วงเวลาที่สถานที่นั้นเปิดทำการ ซึ่งหมายความว่า หากเป็นการค้นร้านอาหารที่เปิดตอนกลางคืนแล้ว การค้นในช่วงเวลานั้นย่อมมีความเหมาะสม

---

[91] 16. Execution of warrants.

— (1) A warrant to enter and search premises may be executed by any constable.[...]

สำหรับการค้นในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แม้ Rule 41 กำหนดให้การค้นจะต้องกระทำในช่วง “Day time” แต่ตามคำนิยาม “Day time” ที่กำหนดไว้ใน Rule 41 หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 22:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น[92] เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกามีช่วงเวลากลางวันในแต่ละฤดูกาลที่ยาวนานแตกต่างกัน ทำให้ในบางฤดูมีเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่นานมาก ดังนั้น จึงได้กำหนดช่วงเวลาทำการค้นให้สอดคล้องกับเวลากลางวันของประเทศ

(2) ข้อยกเว้นหลักการค้นต้องกระทำในเวลากลางวัน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 96 ได้กำหนดข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานสามารถค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนได้ในกรณีต่อไปนี้

1. เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้

2. ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้

ความหมายของฉุกเฉินอย่างยิ่ง หมายถึง ถ้าไม่ค้นในเวลากลางคืนจะเกิดภยันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลที่ต้องการค้นให้พบตัว หรือบุคคลนั้นอาจหลบหนีไป หรือพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในที่รโหฐานนั้นอาจถูกทำลายก็ได้ ทั้งคดีนั้นต้องมีลักษณะร้ายแรงไม่ใช่คดีเล็กๆ น้อยๆ[93] ยกตัวอย่างเช่น

การมีและการดื่มสุราซึ่งมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งอันจะทำให้พลตำรวจมีอำนาจเข้าค้นและจับกุมบุคคลผู้มีและดื่มสุราในที่รโหฐานในเวลากลางคืน

---

(4) Entry and search under a warrant must be at a reasonable hour unless it appears to the constable executing it that the purpose of a search may be frustrated on an entry at a reasonable hour.[...]

[92] Rule 41. Search and Seizure

(a) Scope and Definitions.

[...]

(B) “Daytime” means the hours between 6:00 a.m. and 10:00 p.m. according to local time.

[93] หยุด แสงอุทัย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24*, น. 706.

ได้ ฉะนั้น เมื่อพลตำรวจเข้าจับกุมผู้กระทำผิดและถูกผู้กระทำผิดขัดขวาง ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน[94]

สายลับแจ้งว่าจำเลยกลับมานอนบ้านเจ้าพนักงานจึงไปจับจำเลย เข้าจับเวลา 5:40 นาฬิกา ไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือไม่อาจขอได้ทันเพราะเหตุใด เช่นนี้ คดีไม่พอจะฟังว่าเป็นการฉุกเฉินอย่างยิ่ง การที่เจ้าพนักงานจับจำเลยในที่รโหฐานในเวลากลางคืนจึงไม่มีอำนาจที่จะทำได้[95]

ในขณะเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีหมายค้นและหมายจับ แต่เห็นว่าการเล่นการพนันเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าหากไม่เข้าตรวจค้นและจับกุมทันทีตามที่พลเมืองดีแจ้ง ผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปได้เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งจึงตรวจค้นในเวลากลางคืนได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (2) ประกอบด้วยมาตรา 96 (2)[96]

จ่าสิบตำรวจ ส.และร้อยตำรวจเอก ป. จับจำเลยได้ขณะที่จำเลยกำลังขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่จ่าสิบตำรวจ ส. ผู้ล่อซื้อ ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า ขณะนั้นธนบัตรที่ใช้ล่อซื้ออยู่ที่จำเลยและจำเลยดิ้นรนต่อสู้ ถ้าปล่อยให้เนิ่นช้ากว่าจะนำหมายจับและหมายค้นมาได้ จำเลยอาจหลบหนีและพยานหลักฐานอาจสูญหายจึงเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง จ่าสิบตำรวจ ส. และร้อยตำรวจเอก ป. จึงมีอำนาจเข้าไปในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุอันเป็นที่รโหฐานในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น[97]

โจทก์ได้กระทำผิดซึ่งหน้า แต่ความผิดที่โจทก์กระทำเป็นแต่เพียงความผิดฐานลหุโทษ ฐานฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เก็บค่าดูจากประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยทุกคนรู้จักหลักแหล่งของโจทก์แล้ว จึงไม่เป็นเหตุให้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 (2) การที่จำเลยทั้งหมดผู้เป็นเจ้าพนักงานไปทำการจับกุมโจทก์ในที่รโหฐานในเวลากลางคืนโดย ไม่มีหมาย[98]

---

[94] คำพิพากษาฎีกาที่ 575/2483

[95] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 162/2510 เน. 2 น. 93.

[96] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4950/2540

[97] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4461/2540

[98] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 706/2516 เน. 12 น. 723.

ขณะเกิดเหตุนั้นมีคนบนเรือนประมาณ 50 คน ทั้งที่กำลังเล่นและมิได้เล่นการพนัน ถ้าปล่อยให้เนิ่นช้าไปโดยไม่จับทันทีก็อาจจับผู้กระทำความผิดไม่ได้เลย เพราะปนเปกันอยู่มากทั้งบรรดาพยานหลักฐานต่างๆ ก็อาจสูญหายหรือถูกทำลายไปหมดจึงเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ผู้เสียหายกับพวกจึงมีอำนาจเข้าไปค้นในบ้านที่เกิดเหตุอันเป็นที่รโหฐานในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น[99]

(3) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา โดยข้อ 36 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ระบุว่า ในการร้องขอให้ออกหมายค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญในเวลากลางคืนนั้น นอกจากพยานหลักฐานตามข้อ 15 ผู้ร้องต้องเสนอพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ดุร้ายหรือเป็นผู้ร้ายสำคัญ และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำในเวลากลางคืน มิฉะนั้นผู้นั้นจะหลบหนีหรือก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการตามหมายต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับห้าหรือเป็นตำรวจยศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจเอกขึ้นไป

ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย ได้อธิบายความหมายของ “ผู้ดุร้าย” และ “ผู้ร้ายสำคัญ” ไว้ว่า ผู้ดุร้ายอาจจะยังไม่ใช่ผู้กระทำผิดก็ได้ เช่น เป็นคนที่มีจิตไม่ปกติ เคยทำร้ายคนอื่นมาก่อนแล้ว เป็นต้น แต่ต้องเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานจะจับตัวได้ เช่น มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้ดุร้ายอาจจะกระทำความผิดทำนองเดียวในที่รโหฐานนั้นอีก ส่วนผู้ร้ายสำคัญหมายถึงผู้กระทำผิดในคดีที่มีลักษณะร้ายแรงเช่นในคดีฆ่าคนโดยเจตนาหรือปล้นทรัพย์เป็นต้น[100]

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มีความเห็นว่า กรณีตามมาตรา 96 (3) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตพิเศษได้แก่การที่ “ผู้ดุร้าย” หรือ “ผู้ร้ายสำคัญ” อยู่ในที่รโหฐานโดยไม่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าใดๆ การจะเข้าไปในที่รโหฐานนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองให้แน่ชัดเสียก่อนโดยศาลเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้จะถูกจับเป็น “ผู้ดุร้าย” หรือ ผู้ร้ายสำคัญ” จริงๆ เพราะตามความเป็นจริงบุคคลนั้นๆ อาจจะไม่ดุร้ายหรือไม่ใช่ผู้ร้ายสำคัญก็ได้ ซึ่งควรรอให้พระอาทิตย์ขึ้นเสียก่อนจึงค่อยทำการค้นก็ได้[101]

---

[99]คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2516

[100]คนึง ฦาไชย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 10, น. 280.

[101]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25*, น. 449-450.

สำหรับการค้นในเวลากลางคืนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ตาม Rule 41 ของสหรัฐระบุว่า ศาลโดยมีเหตุผลอันสมควรอาจระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในหมายให้ค้นนอกเหนือจากช่วงเวลากลางวันได้ โดยศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป แม้ว่าไม่มีการร้องขอโดยเจ้าพนักงาน ศาลก็สามารถกำหนดไว้ในหมายให้เจ้าพนักงานสามารถทำการค้นตอนกลางคืนได้ ยกตัวอย่างเช่น

Title 11 Crimes and Criminal Procedure ของรัฐเดลาแวร์ มาตรา 2308[102] ระบุว่าการค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีหรือป้องกันการโยกย้ายสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการพบ

Minnesota Statues ในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal procedure) ของรัฐมินิโซตา มาตรา 626.14[103] บัญญัติว่าการออกหมายค้นในเวลากลางคืนสามารถกระทำได้เพื่อป้องกันการสูญหาย การโยกย้ายทำลายพยานหลักฐาน หรือเพื่อป้องกันอันตรายแก่เจ้าพนักงานผู้ทำการค้นหรืออันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน

---

[102] § 2308. Search at nighttime.

A search warrant shall not authorize the person executing it to search any dwelling house in the nighttime unless the judge, justice of the peace or magistrate is satisfied that it is necessary in order to prevent the escape or removal of the person or thing to be searched for, and then the authority shall be expressly given in the warrant. For purposes of this section the term "nighttime" shall mean the period of time between 10:00 p.m. and 6:00 a.m.

[103] § 626.14 Time of service.

A search warrant may be served only between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m. unless the court determines on the basis of facts stated in the affidavits that a nighttime search outside those hours is necessary to prevent the loss, destruction, or removal of the objects of the search or to protect the searchers or the public. The search warrant shall state that it may be served only between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m. unless a nighttime search outside those hours is authorized.

นอกจากนี้ ตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหมายค้นในเวลากลางคืนซึ่งจัดทำโดยศาลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา[104] ได้ระบุว่าการค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนต้องมีเหตุที่เป็นไปได้ในการค้นในเวลากลางคืน กล่าวคือ ต้องมีความฉุกเฉินตามหลัก Exigent circumstance สำหรับการพิจารณาว่ากรณีใดที่ถือว่ามีความฉุกเฉินที่จะทำการค้นในเวลากลางคืน บันทึกความเข้าใจได้อธิบายแนวทางในการพิจารณาตามที่เคยมีคำพิพากษา ดังนี้

(1) เมื่อผู้กระทำความผิดถูกเจ้าพนักงานควบคุมตัวอยู่แต่คาดการณ์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะถูกปล่อยตัวในเวลากลางคืนซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถกลับไปยังที่รโหฐานเพื่อทำลายพยานหลักฐานได้

(2) มีเหตุที่เป็นไปได้ว่ามีผู้สมคบคิดหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดที่รู้ถึงการจับกุมผู้กระทำความผิดและจะพยายามทำลายพยานหลักฐาน ซึ่งเจ้าพนักงานจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีตัวบุคคลดังกล่าวอยู่และบุคคลนั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่รโหฐานหรือเคยเข้าไปในที่รโหฐานนั้น

(3) สถานที่ที่จะเข้าค้นมีลักษณะเป็นที่อาศัยชั่วคราว กล่าวคือ หากโดยลักษณะของสถานที่นั้นบ่งบอกให้ทราบว่าบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการพบจะถูกเก็บหรือซ่อนอยู่เพียงชั่วคราวไม่เกินข้ามคืน เช่น ห้องพักในโรงแรม เป็นต้น

(4) มีรายงานว่าพบการกระทำความผิดอาญาในที่รโหฐาน และผู้กระทำความผิดยังคงอยู่ในที่รโหฐานนั้น เช่น

ในคดี Brown v. State 1988 WL 101236 (Del. Supr.) เจ้าพนักงานได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุร้ายในเวลากลางคืน โดยเจ้าพนักงานได้ทราบว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในบ้านของผู้ถูกกล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดยังคงอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว ศาลวินิจฉัยว่ามีเหตุอันเป็นไปได้ที่จะมีการทำลายพยานหลักฐานหากเจ้าพนักงานไม่ได้เข้าค้นที่รโหฐานในทันที เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานสามารถค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนได้

ในการพิจารณาความฉุกเฉินตาม (1) – (4) ศาลมักจะพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของความผิด ซึ่งได้แก่ เป็นการกระทำความผิดที่มักกระทำในเวลากลางคืนและพยานหลักฐานในความผิดดังกล่าวอาจถูกโยกย้ายทำลายได้โดยง่าย เช่น ความผิดฐาน

---

[104]Delaware court, “Legal Memorandum 02-264 : Nighttime Search Warrant,” <http://courts. delaware.gov/legal%20memoranda/List.aspx>.

ลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่มีการขนส่งไปยังสถานที่รับมอบของในเวลากลางคืน อีกทั้งสภาพของยาเสพติดยังง่ายต่อการซุกซ่อน โยกย้าย หรือทำลาย

อย่างไรก็ตาม ในคดี State v. White ศาลวินิจฉัยว่า แม้สถานที่ที่จะทำการค้นจะเป็นห้องพักค้างคืนในโรงแรม แต่การที่เจ้าพนักงานเพียงแต่ชี้แจงว่ามีความฉุกเฉินเนื่องจากตนเกรงว่าหากรอให้ถึงตอนเช้าพยานหลักฐานในคดี ได้แก่ หยดเลือดและร่องรอยต่างๆ ที่จะใช้ในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จะเสื่อมสภาพลง ไม่เป็นเหตุฉุกเฉินที่ศาลจะอนุญาตให้ค้นสถานที่นั้นในเวลากลางคืน

ทั้งนี้ การค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายระบุให้อำนาจค้นในเวลากลางคืนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็สามารถกระทำได้หากเป็นการค้นตั้งแต่เวลากลางวันโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือเป็นการค้นตามหมายค้นหรือการค้นโดยมีเหตุค้นได้โดยไม่มีหมายค้น แต่การค้นไม่เสร็จสิ้นจึงค้นต่อในเวลากลางคืน โดยศาลวินิจฉัยว่า แม้การค้นจะเริ่มขึ้นก่อนเวลากลางคืนเพียงครึ่งชั่วโมง ก็ไม่ทำให้การค้นในเวลากลางคืนเป็นการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และหากมีความจำเป็นที่ไม่อาจรอหมายค้นและไม่อาจรอให้ถึงเวลากลางวันเพื่อทำการค้นได้ย่อมเป็นกรณีที่มีความฉุกเฉิน (Exigent circumstance) ที่ทำให้ค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายค้นได้เช่นเดียวกัน

ส่วนในประเทศอังกฤษ ในมาตรา 16 ของ PACE ได้ระบุข้อยกเว้นของหลักการค้นต้องกระทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมว่า แม้ขณะที่ทำการค้นจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่หากการไม่ลงมือค้นในทันทีจะทำให้การค้นนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการค้น การค้นดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีความหมายว่า การรอให้ถึงเวลากลางวันจะเป็นเหตุให้การค้นสถานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการค้น กล่าวคือ ทำให้ไม่สามารถรักษาชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว้ได้ หรือทำให้ไม่พบสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้มาจากการกระทำความผิดที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิด หรือสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด

3.5.2 การแสดงตนในการค้น

หลักการแสดงตนเป็นหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหลายรัฐและใน Title 18 มาตรา 3109[105] ว่า เจ้าพนักงานอาจใช้กำลังบังคับเข้าไปในเคหสถานเพื่อทำการค้นได้เมื่อได้แจ้งถึงอำนาจทำการค้นและวัตถุประสงค์ของการค้นแล้ว ไม่ได้รับความยินยอมให้เข้าไปในเคหสถานนั้น ส่วนในประเทศอังกฤษ มาตรา 2 ของ PACE กำหนดว่าก่อนที่จะเริ่มทำการค้น เจ้าหน้าที่จะต้องแสดงชื่อและสถานีตำรวจที่ประจำอยู่ วัตถุที่ต้องการค้นหา เหตุผลในการตรวจค้นแก่ผู้ที่จะถูกตรวจค้นรวมทั้งสิทธิของผู้ถูกค้นในการได้รับสำเนาบันทึกการตรวจค้นทุกครั้ง และหากในการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่จะต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมในการแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ถูกตรวจค้นด้วย ซึ่งหลักการในลักษณะดังกล่าวปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 94 ที่ระบุว่า “...ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่ง” และมาตรา 62 “...เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามีคำขอร้อง ให้ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดู”

อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายไทยไม่ปรากฏว่าในกรณีใดที่เจ้าพนักงานจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้มีคำพิพากษาที่วางหลักเกณฑ์เพื่อยกเว้นหลักการแสดงตนดังกล่าวไว้โดยชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าการแสดงตนในการค้นมีความสำคัญในฐานะเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้ทราบถึงเหตุผลที่สถานที่ของตนจะต้องถูกตรวจค้น อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเพราะเมื่อเจ้าพนักงานได้แสดงตนแล้วจะต้องให้โอกาสผู้ครอบครองสถานที่นั้นมาเปิดประตูก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้กำลังบังคับเข้าไปในสถานที่นั้นด้วยการพังประตูหรือหน้าต่าง ตลอดจนเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตร่างกายของเจ้าหน้าที่เอง เนื่องจากการเข้าไปในที่รโหฐานของผู้อื่นโดยไม่บอกกล่าวย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่รโหฐานนั้นจะใช้สิทธิป้องกันตนเองต่อบุคคลที่บุกรุก

---

[105] § 3109

The officer may break any part of a house, or anything therein, to execute a search warrant, if, after notice of his authority and purpose, he is refused admittance.

เข้ามา โดยได้กำหนดยกเว้นของหลักการแสดงตนไว้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้[106]

(1) การแสดงตนจะก่อให้เกิดอันตราย เจ้าพนักงานจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากตนได้แสดงตนก่อนเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นจะได้รับอันตราย อย่างไรก็ตาม เพียงข้อเท็จจริงว่าผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นมีอาวุธไม่เป็นเหตุยกเว้นการแสดงตน ดังตัวอย่างในคดีที่ศาลของรัฐฟลอริดาได้พิพากษาว่าการที่เจ้าพนักงานเข้าไปในบ้านผู้ต้องหาโดยไม่ได้แสดงตนเนื่องจากผู้ต้องหาเคยก่อคดีปล้นทรัพย์และคดีข่มขืนกระทำชำเราโดยมีอาวุธเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นเนื่องจากเจ้าพนักงานไม่เพียงทราบว่าผู้ต้องหามีอาวุธแต่ยังทราบประวัติการกระทำความผิดและพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผู้ต้องหาด้วย

(2) การแสดงตนไม่มีความจำเป็น เนื่องจากผู้ครอบครองสถานที่นั้นทราบอยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานมาด้วยเหตุใด จึงถือว่าวัตถุประสงค์ของการแสดงตนนั้นได้สัมฤทธิ์ผลไปแล้ว เช่นเดียวกับในกรณีที่ผู้ครอบครองสถานที่นั้นไม่อยู่ การแสดงตนย่อมไม่มีประโยชน์อันใด โดยเจ้าพนักงานจะต้องไม่เพียงแค่เชื่อว่าผู้ครอบครองได้เห็นเจ้าพนักงานมาถึงแต่ยังจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ครอบครองมาด้วยเหตุอะไร เช่น เห็นบุคคลดังกล่าววิ่งหนีไป

(3) การแสดงตนจะทำให้มีการทำลายพยานหลักฐานหรือมีการหลบหนี เจ้าพนักงานจะต้องอธิบายได้ว่าตนรับรู้ได้ถึงข้อเท็จจริงบางประการที่เป็นการสร้างความเสี่ยงที่จะมีการทำลายพยานหลักฐาน เช่น ทราบว่าพยานหลักฐานถูกเก็บไว้ในหีบห่อที่ทำลายได้โดยสะดวก หรือจากลักษณะของพยานหลักฐานนั้นเองบอกได้ว่าจะถูกทำลายโดยง่าย เช่น ยาเสพติด อุปกรณ์ในการเล่นพนัน เป็นต้น

3.5.3 **หลักการแจ้งให้ทราบถึงการค้นที่รโหฐาน** (Notice Search)

ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษไม่ได้ห้ามการค้นสถานที่ของบุคคลในขณะที่ไม่มีผู้ครอบครอง แต่กฎหมายสหรัฐอเมริกาได้สร้างหลักเกณฑ์ว่าอย่างน้อยจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ที่อยู่หรือครอบครองสถานที่นั้นได้ทราบว่ามีการค้นเกิดขึ้นเสมอ เช่นเดียวกับ

---

[106]Michael J. Bulzomi, “Knock and Announce : A Fourth Amendment Standard, ” The FBI Law Enforcement Bulletin, (May 1997), <http://www2.fbi.gov/publications/leb/1997/may976. htm.>.

มาตรา 16 (7)[107] ของ PACE ที่กำหนดว่าในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่ ณ สถานที่นั้น ให้เจ้าพนักงานติดสำเนาหมายค้นไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนในสถานที่นั้น แม้ว่าโดยหลักทั่วไป การแจ้งให้ทราบถึงการค้นจะต้องกระทำโดยทันทีที่ได้มีการค้นตามหมาย อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ที่ยินยอมให้เจ้าพนักงานกระทำการค้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของหมายทราบในทันทีถึงการค้นนั้น ซึ่งต่อมาได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน The USA PATRIOT Act ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มมาตรา 3103 a[108] ใน Title 18 Crimes and Criminal Procedure เพื่อเป็นการวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นหลักการแจ้งการค้นให้มีความเคร่งครัดยิ่งขึ้นโดยให้กระทำได้ต่อเมื่อมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหมายค้นเท่านั้นและเรียก

---

[107]Sec. 16. Execution of warrants.

[...]

(7) If there is no person who appears to the constable to be in charge of the premises, he shall leave a copy of the warrant in a prominent place on the premises.

[108] § 3103a. Additional grounds for issuing warrant

(a) In General.— In addition to the grounds for issuing a warrant in section 3103 of this title, a warrant may be issued to search for and seize any property that constitutes evidence of a criminal offense in violation of the laws of the United States.

(b) Delay.— With respect to the issuance of any warrant or court order under this section, or any other rule of law, to search for and seize any property or material that constitutes evidence of a criminal offense in violation of the laws of the United States, any notice required, or that may be required, to be given may be delayed if—

(1) the court finds reasonable cause to believe that providing immediate notification of the execution of the warrant may have an adverse result (as defined in section 2705, except if the adverse results consist only of unduly delaying a trial) ;

(2) the warrant prohibits the seizure of any tangible property, any wire or electronic communication (as defined in section 2510), or, except as expressly provided. in chapter 121, any stored wire or electronic information, except where the court finds reasonable necessity for the seizure; and

หมายค้นในลักษณะนี้ว่า Delayed notice search warran[109]

เหตุผลและความจำเป็นในการยกเว้นหลักดังกล่าวเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อความเร่งด่วนที่จะต้องทำการค้นกับความจำเป็นที่จะต้องให้การสอบสวนยังเป็นความลับ ยกตัวอย่างเช่น ในคดีที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งว่ากำลังจะมีการขนส่งยาเสพติดจำนวนมาก หากไม่ดำเนินการยึดยาเสพติดเหล่านั้นก็จะทำให้ยาเสพติดจำนวนมากเข้าถึงผู้คนในชุมชน แต่ในทันทีที่ทำการค้นก็จะทำให้ผู้อยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดนั้นรู้ตัวและเป็นการตัดโอกาสเจ้าพนักงานที่จะสามารถสืบสาวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในวงจรการค้ายานั้น ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานสามารถยึดยาเสพติดโดยทำให้เข้าใจว่ายาเสพติดนั้นถูกผู้ค้ายาที่เป็นคู่แข่งขโมยไปย่อมทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปราบปรามการกระทำความผิดได้มากกว่า การออกหมายค้นประเภทนี้จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในส่วนของขั้นตอนการกระทำความผิดและผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด เพื่อให้สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวการสำคัญได้โดยที่ไม่ทำให้ผู้กระทำความผิดรู้ถึงตัวผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เป็นสายลับก่อนที่จะทำการจับกุมครั้งใหญ่ได้สำเร็จ ซึ่งความผิดดังกล่าว ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดฐานค้ายาเสพติด และความผิดร้ายแรงอื่นๆ เช่น ความผิดฐานปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ความผิดฐานฟอกเงินที่กระทำในลักษณะข้ามชาติ เป็นต้น[110]

สำหรับเหตุในการออก Delayed notice search warrant ต้องเป็นกรณีที่ศาลมีเหตุอันควรเชื่อว่าการแจ้งการค้นในทันทีจะทำให้เกิดผลในเชิงปฏิปักษ์ตามมาตรา 2705 ได้แก่

(1) ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(2) ทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีการฟ้องร้อง

(3) จะมีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพยานหลักฐาน

---

(3) the warrant provides for the giving of such notice within a reasonable period not to exceed 30 days after the date of its execution, or on a later date certain if the facts of the case justify a longer period of delay.

[109] U.S. Department of Justice, “Delayed notice search warrant : A Vital and Time-Honored Tool for Fighting Crime,” (2004), pp. 2-3, <http://www.justice.gov/dag/patriotact 213 report.pdf>.

[110] *Ibid*, pp. 4-7.

(4) จะก่อให้เกิดการข่มขู่พยาน

(5) จะทำให้การสอบสวนเสียหายอย่างร้ายแรงหรือทำให้การพิจารณาคดีล่าช้าเกินควร

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปหมายดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือดักฟังการสนทนา หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อรวบรวมข้อมูล หรือยืนยันขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการกระทำความผิด โดยไม่ได้ให้อำนาจยึดพยานหลักฐานหรือบันทึกการสนทนาหรือข้อมูลใดๆ ลงในเครื่องบันทึกข้อมูล แต่หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยึดสิ่งของหรือบันทึกข้อมูลใดดังกรณีที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น ก็สามารถระบุให้อำนาจไว้ในหมายได้[111]

ทั้งนี้ มาตรา 1301 a ระบุว่า Delayed notice search warrant จะต้องระบุให้เจ้าพนักงานแจ้งการค้นนั้นภายในระยะเวลาอันควรซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้มีการค้น เว้นแต่ข้อเท็จจริงในคดีนั้นสมควรที่จะขยายระยะเวลาออกไปเกินกว่า 30 วัน และศาลที่ออกหมายนั้นก็มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุในการออกหมาย ความผิดที่ระบุในหมาย และระยะเวลาที่ระบุให้แจ้งการค้นรวมถึงการขยายระยะเวลาดังกล่าว ไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมภายใน 30 วันนับแต่วันที่หมายดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับด้วย

3.6 ขอบเขตในการค้นที่รโหฐาน

การพิจารณาขอบเขตในการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 98 ซึ่งบัญญัติว่า

มาตรา 98 การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้

(1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้คนมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย

(2) เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า

---

[111] *Ibid*, p. 4.

มาตรา 98 วางหลักว่า การค้นที่รโหฐานเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นจะค้นได้เฉพาะตามที่หมายค้นนั้นได้ระบุเอาไว้เท่านั้น จะไปค้นจับคนอื่นๆ ด้วยไม่ได้ หรือหมายค้นให้ค้นเพื่อยึดอาวุธปืนกระบอกหนึ่งโดยระบุเฉพาะไป จะยึดอาวุธอื่น เช่น มีด ขวานซึ่งสงสัยว่าเคยใช้ในการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ ไม่ได้ เพราะถ้าหากว่าให้ค้นบุคคลอื่นหรือสิ่งของอื่นได้แล้ว มาตรา 60 (ค) (4) ก็ไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้มาตรา 98 ได้วางข้อยกเว้นไว้ตามมาตรา 98 (1) “สิ่งของไม่จำกัดสิ่ง” เช่น ในการปล้นทรัพย์ ผู้ร้ายได้ใช้อาวุธ ปืน มีด ขวาน ยิง แทง ฟันเจ้าทรัพย์บาดเจ็บล้มตาย ทั้งได้กวาดทรัพย์สินเงินทองไปมากมาย ในการค้นนั้น ไม่แน่ว่าจะมีสิ่งของอันใดบ้างที่สงสัยว่าจะซ่อนอยู่ในที่จะทำการค้น ผู้ออกหมายจึงระบุไปในหมายกว้างๆ เป็นสิ่งของแต่ละประเภทไป ดังนั้น ในการค้นนั้นถ้าเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นไปค้นพบปืนหลายกระบอก มีด ขวานหลายเล่ม ทรัพย์สินเงินทองถูกซ่อน ฝังไว้เป็นจำนวนมาก ก็ทำการยึดมาได้ หรือในกรณีกบฏอาจจะมีอาวุธต่างๆ ชนิด กับเอกสารต่างๆ ที่ผู้กระทำความผิดใช้ในการติดต่อกัน เมื่อเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นเห็นว่าน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ยันผู้ต้องหา หรือจำเลยใดแล้วก็มีอำนาจยึดมาได้[112]

ส่วนกรณีตามมาตรา 98 (2) “เมื่อมีหมายอีกต่างหาก” เช่นในหมายค้นให้จับนาย ก.แต่ในการค้นเพื่อจับนาย ก. นั้น เจ้าพนักงานมีหมายจับนาย ข. ผู้ร้ายในการปล้นทรัพย์รายเดียวกันด้วย เมื่อเจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นพบตัวนาย ข. ในสถานที่นั้น ก็มีอำนาจจับนาย ข. ตามหมายจับได้ด้วย

“ในกรณีความผิดซึ่งหน้า” หมายความว่าในกรณีค้นหาสิ่งของ ถ้าผู้ทำการค้นพบตัวบุคคลที่มีหมายจับก็จับได้ หรือถ้าบุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า ซึ่งอาจเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานนั้นเอง เช่น ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือกระทำความผิดอื่นๆ เช่น พบอาวุธปืนไม่จดทะเบียนไว้ในครอบครองก็จับได้เช่นเดียวกัน[113]

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อรายการที่ต้องระบุในหมายค้น ว่า ทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญกับการจำกัดขอบเขตของการค้นอันมี

---

[112]อนุมัติ ใจสมุทร, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยหลักทั่วไปตลอดถึงการไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 1 ถึงมาตรา 171, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2514), น. 656.

[113]หยุด แสงอุทัย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24*, น. 719-720.

ที่มาจากหลักหมายค้นต้องมีความเฉพาะเจาะจงสถานที่ที่จะค้น และสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการค้นตามบรรทัดฐานในคดี Entick v. Carrington ซึ่งหลักความเฉพาะเจาะจงนี้ถูกนำไปใช้กับการค้นโดยไม่มีหมายค้นด้วย โดยการค้นโดยมีหมายค้นซึ่งได้ระบุสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการค้นไว้แล้ว เจ้าพนักงานก็ต้องค้นหาบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ เช่น ค้นหารถยนต์ที่ถูกขโมยควรจำกัดเฉพาะบริเวณกว้างๆ รอบตัวบ้านหรือในโรงรถ โกดัง การค้นโดยไม่มีหมายค้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง ย่อมไม่มีอำนาจค้นลิ้นชัก ตู้เก็บของ สำหรับประเทศอังกฤษได้ระบุขอบเขตการค้นไว้ใน The Police and Criminal Evidence Act 1984 มาตรา 16 (8) เรื่องการค้นตามหมายค้น และมาตรา 17 (4) และมาตรา 18 (3) เรื่องการค้นโดยไม่มีหมายว่า การค้นจะต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการค้น (search to the extent reasonably required for the purpose for which the power of entry is exercised) ดังนั้น การค้นจึงต้องพิจารณาถึงขนาดหรือลักษณะของวัตถุ และสถานที่ที่จะมีวัตถุนั้นอยู่

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าหากในการค้นที่ได้กระทำโดยเหมาะสมกับสิ่งซึ่งเป็นเป้าหมายในการค้นแล้ว แต่ในการค้นนั้นทำให้พบสิ่งของหรือบุคคลอื่นที่เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจยึดโดยตรง กรณีเช่นนี้จะสามารถขยายขอบเขตการค้นได้หรือไม่ และจะขยายได้แค่ไหน เพียงใด

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ที่เป็นการขยายขอบเขตของหลักการค้นต้องจำกัดสิ่งที่ค้น เรียกว่า หลักพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง หรือ Plain view doctrine ซึ่งเป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานยึดสิ่งของนอกเหนือจากที่ระบุให้อำนาจไว้ในหมายหรือนอกเหนือจากสิ่งของที่เป็นเหตุให้มีอำนาจค้นได้โดยไม่มีหมาย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับข้อยกเว้นตามมาตรา 98 (1) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้[114]

---

[114]The Alameda County District Attorney's Office “Plain View ” Point of view, volume 36, Number 4, pp. 11-16 (Fall 2008).

(1) เจ้าพนักงานอยู่ในตำแหน่งที่สามารถพบสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful discovery) กล่าวคือ ขณะที่เจ้าพนักงานได้เห็นหรือตรวจพบได้โดยประสาทสัมผัสอย่างอื่น เช่น การได้ยินเสียง หรือได้กลิ่นเป็นครั้งแรกนั้น เจ้าพนักงานอยู่ในจุดที่สามารถเห็นหรือตรวจพบสิ่งของนั้นๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อ (Probable cause to seize) ว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นของที่ถูกขโมย หรือเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดนั้นหรือพยานหลักฐานในความผิดอื่น

(3) เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful access) มีความหมายว่า นอกจากเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถพบสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากสิ่งของนั้นไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันกับที่เจ้าพนักงานอยู่ การที่จะเข้าไปยึดสิ่งของนั้นยังต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานจะต้องสามารถเข้าไปถึงจุดดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย

เหตุอันควรเชื่อตาม (2) เช่น เชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ถูกขโมย ได้แก่ กรณีที่เจ้าพนักงานเห็นนาฬิกาข้อมือของสุภาพสตรีและเครื่องเพชรจำนวนมากในกระเป๋าของผู้ต้องหาขณะที่ผู้ต้องหาเปิดกระเป๋า[115] มีวิทยุรถยนตร์มากมายกองซ้อนกันอยู่บนพื้น[116] หรือกรณีที่เชื่อว่าเป็นยาเสพติด ได้แก่ เจ้าพนักงานได้กลิ่นเฉพาะตัวของยาเสพติดและมีอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการเสพยา เช่น เข็มฉีดยา อยู่ใกล้ๆ ห่อของที่สงสัย[117]

สำหรับการเข้าถึงสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมายตาม (3) อาจมาจากอำนาจตามหมายค้น ความยินยอมของผู้ครอบครองสถานที่นั้น หรืออำนาจค้นโดยไม่มีหมายค้น เช่น

เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยซึ่งเป็นผู้เยาว์ในข้อหาเป็นผู้เยาว์มีสุราในครอบครอง การจับกุมเกิดในที่สาธารณะ ผู้เยาว์อ้างว่าไม่ได้เป็นผู้เยาว์ แต่ขณะนั้นไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจึงพากลับไปที่ห้องพักเพื่อไปเอาบัตรประจำตัวประชาชน พอไปถึงห้องพักผู้เยาว์เปิดประตูเข้าไปในห้องพัก เจ้าพนักงานอยู่ข้างนอกห้องแต่มองเข้าไปเห็นกัญชาในห้องพัก เจ้าพนักงานเข้าไปยึดเอากัญชามาเป็นหลักฐาน ศาลสูงสุดของสหรัฐในคดี Washington v. Chrisman ตัดสินว่ามี

---

[115]People v. Clark (1989) 212 Cal.App.3d 1233,1236.

[116]People v. Curtis T. (1989) 214 Cal.App.3d 1391.

[117]Texas v. Brown (1983) 460 U.S. 730, 742-3.

ความชอบธรรมที่จะเข้าไปในห้องพักโดยไม่มีหมายค้นหรือหมายจับเพราะว่าจับในที่สาธารณสถานแล้วควบคุมตัวอยู่เจ้าพนักงานย่อมต้องอยู่ใกล้ชิดตัวบุคคลนั้นเสมอเพื่อไม่ให้หนี จึงตามผู้เยาว์เข้าไปในห้องได้เพื่อไม่ให้หนี[118]

เจ้าพนักงานส่องกล้องลงมาจากเครื่องบินเห็นต้นกัญชาอยู่ในบริเวณบ้านจำเลยซึ่งปลูกต้นไม้ล้อมรอบไว้ มองจากข้างนอกในระดับพื้นดินไม่เห็น เจ้าพนักงานเข้าไปยึดเอาต้นกัญชามาเป็นพยานหลักฐาน แม้ว่าท้องฟ้าเป็นที่สาธารณะการมองลงมาไม่ถือเป็นการค้น แต่พอตอนจะเข้าไปถึงตัววัตถุต้องมีหมาย[119]

เจ้าพนักงานเห็นผู้หญิงในห้องของจำเลยในโรงแรมกำลังนับห่อกระดาษฟอยล์โดยเชื่อว่าห่อดังกล่าวบรรจุเฮโลอีนจึงได้เข้าไปในห้องและจับกุม ศาลพิพากษาว่าเพียงการเห็นเฮโลอีนซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ภายในห้องผ่านประตูที่เปิดอยู่ไม่เป็นเหตุให้ค้นที่รโหฐานได้โดยไม่มีหมายค้น แต่เนื่องจากเจ้าพนักงานอยู่ห่างจากผู้ต้องหาเพียงไม่กี่ฟุต เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหญิงจะสังเกตเห็นเจ้าพนักงาน ประกอบกับผู้ต้องหามักพยายามทำลายหลักฐานเมื่อรู้ว่าถูกเจ้าพนักงานพบการกระทำความผิด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานเข้าไปในห้องของจำเลยโดยเชื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินที่พยานหลักฐานจะถูกทำลาย ทำให้การเข้าไปของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมาย[120]

แม้ว่าสิ่งของผิดกฎหมายจะถูกเห็นได้อย่างชัดเจนจากข้างนอกที่รโหฐาน แต่การค้นที่รโหฐานเพื่อยึดสิ่งผิดกฎหมายนั้นโดยไม่มีหมายค้นก็ไม่อาจกระทำได้หากไม่เป็นไปตามหลักการค้นโดยฉุกเฉิน (absent exigent circumstances)[121]

---

[118]จิรนิติ หะวานนท์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2*, น. 40.

[119]*เพิ่งอ้าง*.

[120] People v. Ortiz, (1995) 32 Cal.App.4th 286.

[121] G&G Jewery v. City of Oakland (9th Cir. 1993) 989 F. 2d 1093,1101.

สำหรับในมาตรา 19[122] ของ PACE ของประเทศอังกฤษ ได้ให้อำนาจยึดแก่เจ้าพนักงานอย่างกว้างขวางเพื่อขยายอำนาจค้นและยึดตามพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติอื่นในสถานการณ์ที่เจ้าพนักงานเข้าไปในที่รโหฐานโดยชอบด้วยกฎหมายและพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยบังเอิญแต่ไม่มีอำนาจยึดสิ่งนั้น ยกตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานเข้าไปในที่รโหฐานตามหมายค้นที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ (The Theft Act 1968) ซึ่งอนุญาตให้ยึดสิ่งของที่ถูกขโมย หากในการค้นครั้งดังกล่าว

---

[122] 19. General power of seizure etc.

— (1) The powers conferred by subsections (2), (3) and (4) below are exercisable by a constable who is lawfully on any premises.

(2) The constable may seize anything which is on the premises if he has reasonable grounds for believing—

(a) that it has been obtained in consequence of the commission of an offence; and

(b) that it is necessary to seize it in order to prevent it being concealed, lost, damaged, altered or destroyed.

(3) The constable may seize anything which is on the premises if he has reasonable grounds for believing—

(a) that it is evidence in relation to an offence which he is investigating or any other offence; and

(b) that it is necessary to seize it in order to prevent the evidence being concealed, lost, altered or destroyed.

(4) The constable may require any information which is stored in any electronic form] and is accessible from the premises to be produced in a form in which it can be taken away and in which it is visible and legible or from which it can readily be produced in a visible and legible form]if he has reasonable grounds for believing—

(a) that—

(i) it is evidence in relation to an offence which he is investigating or any other offenc; or

ทำให้พบยาเสพติด เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจยึดยาเสพติดดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตินี้[123]

ทั้งนี้ การขยายขอบเขตการค้นและยึดตามมาตรา 19 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของดังกล่าวได้มาโดยผลของการกระทำความผิด และมีความจำเป็นต้องยึดเพื่อป้องกันสิ่งของนั้นจากการสูญหาย ถูกปกปิด ทำให้เสียหาย ถูกโยกย้าย หรือถูกทำลาย

(2) เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เขากำลังสอบสวนหรือความผิดอื่นเพื่อป้องกันการปกปิด การสูญหาย การโยกย้าย หรือการทำลาย โดยการยึดพยานหลักฐานตาม (2) นี้ ต้องไม่ใช่สิ่งของที่มีเอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกยึด (subject to legal privilege)

(3) เจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะเรียกเอาข้อมูลทุกอย่างที่ถูกเก็บอยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากที่รโหฐานนั้นเพื่อให้สามารถนำกลับไปในรูปที่สามารถเห็นและเข้าใจได้ในกรณีที่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่า ข้อมูลนั้นเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เขากำลังสอบสวนหรือความผิดอื่น หรือได้มาโดยผลของการกระทำความผิดและมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการปกปิด การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลาย

จากการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้โดยหลักการแล้ว การค้นจะต้องเป็นไปตามขอบเขตที่

(ii) it has been obtained in consequence of the commission of an offence; and

(b) that it is necessary to do so in order to prevent it being concealed, lost, tampered with or destroyed.

(5) The powers conferred by this section are in addition to any power otherwise conferred.

(6) No power of seizure conferred on a constable under any enactment (including an enactment contained in an Act passed after this Act) is to be taken to authorise the seizure of an item which the constable exercising the power has reasonable grounds for believing to be subject to legal privilege.

[123]M.D. A. Freeman, *supra note 70*, pp. 19-20.

หมายค้นกำหนดเป็นสำคัญ กล่าวคือ เจ้าพนักงานจะค้นได้เพียงแค่ในสถานที่ที่หมายกำหนดเพื่อหาบุคคลและสิ่งของที่กำหนดในหมาย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการขยายขอบเขตของการค้นออกไปนอกเหนือจากการค้นโดยจำกัดสิ่งนั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเป็นการขยายอำนาจออกไปโดยอาศัยเหตุว่าในการค้นในบริเวณที่ตนเองมีอำนาจอยู่แล้วนั้น ได้ไปพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างชัดแจ้งเข้า หากไม่ยึดไปเสียในคราวเดียวกัน ทรัพย์สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายทำลายไปเสียก่อน ในขณะที่ตามกฎหมายไทยมีหลักตามมาตรา 98 วรรคหนึ่งว่า การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นตามหมายเช่นเดียวกัน แต่ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นให้มีหมายค้นที่ระบุสิ่งของที่จะค้นได้กว้างๆ ว่าเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่กำหนดในหมายให้ค้นและยึดได้ ซึ่งทำให้สามารถยึดสิ่งของได้กว้างขวางตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานในลักษณะเดียวกับการขยายขอบเขตการค้นตามหลัก Plain view ของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรา 19 ของ PACE ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศอังกฤษ แต่ข้อยกเว้นตามมาตรา 98 (1) นี้ ทำให้หมายค้นของไทยดังกล่าวเป็นหมายค้นที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของหมายค้นดังกล่าวในบทที่ 4 ต่อไป

3.7. **ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด**

เมื่อได้ศึกษาแล้วว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของทั้งสามประเทศ ได้แก่ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ และกฎหมายไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติการค้นที่รโหฐานไว้อย่างไรและเพื่อเหตุใดแล้ว สิ่งที่จะต้องศึกษาต่อมาก็คือการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนั้น จะส่งผลอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่การรับฟังพยานหลักฐานและความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้

3.7.1 **ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา**

3.7.1.1 หลักการพื้นฐานในการรับฟังพยานหลักฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ หรือ The Fourth Amendment ของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของบุคคลที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยในร่างกาย เคหสถาน เอกสาร และวัตถุสิ่งของจากการค้น ยึด และการจับโดยไม่มีเหตุอันควร และห้ามมิให้มีการออกหมายค้น เว้นแต่จะมีเหตุที่เป็นไปได้ในการออกหมาย หรือ probable cause และหมาย

ค้นนั้นจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่ซึ่งจะถูกค้น และสิ่งของที่จะยึด อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติถึงผลของการแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ชอบด้วยหลักการดังกล่าวเอาไว้ โดยศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยเริ่มแรกนั้นก็ยึดถือตามหลักการของคอมมอนลอว์เดิม คือศาลยังคงยอมรับพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานได้มาโดยการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แม้ในขณะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่จะมีผลใช้บังคับ โดยศาลจะอนุญาตให้พยานหลักฐานดังกล่าวสามารถเข้าสู่การพิจารณาของคณะลูกขุน ส่วนพยานหลักฐานนั้นจะมีน้ำหนักเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะลูกขุน[124]

ต่อมานักกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีแนวคิดมุ่งให้น้ำหนักต่อการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะการที่จะหามาตรการมายับยั้งการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ในปี ค.ศ. 1886 ในคดี Boyd v. United States ศาลได้ไม่ยอมรับฟังพยานเอกสารที่เกิดจากการบีบบังคับจำเลยให้เปิดเผยเอกสาร เพราะการกระทำของเจ้าพนักงานนั้นถือว่าฝ่าฝืนต่อบัญญัติของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ เอกสารดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังปรักปรำจำเลยได้ และต่อมาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐในคดี Week v. United States ซึ่งถือเป็นคำพิพากษาที่มีความสำคัญที่ศาลได้วางหลักลบล้างพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามหลัก Exclusionary Rule ไว้อย่างชัดเจนที่สุด โดยข้อเท็จจริงในคดีมีอยู่ว่า เจ้าพนักงานได้พยานหลักฐาน คือบรรดาจดหมายและเอกสารโต้ตอบต่างๆ ของจำเลยจากการค้นบ้านของจำเลยโดยไม่มีหมาย โดยศาลให้เหตุผลว่า หากมีการยอมรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ ที่บัญญัติห้ามการค้น การยึด โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นจะไร้ผล[125]

---

[124]จิรนิติ หะวานนท์, “หลักการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอเมริกันและกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพาห, ปีที่ 31, เล่ม 3, น. 36 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2527).

[125]ฐานิศร์ วรรณสุข, “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา : ศึกษากรณีสิ่งซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น. 39-40.

3.7.1.2 ตัวอย่างผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละกรณี

สำหรับผลของการค้นในที่รโหฐานที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ หรือตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น Title 18 Part 2 Criminal Procedure ของ United States Code นั้น อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) การค้นโดยไม่มีหมายค้น

ในกรณีนี้ศาลย่อมไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยไม่มีหมายและไม่มีเหตุให้ค้นได้โดยไม่มีหมาย ตามหลัก Exclusionary Rule ดังที่วินิจฉัยไว้ในคดี Week v. United States ข้างต้น

(2) การค้นโดยไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) ที่จะทำการค้นโดยไม่มีหมาย

เนื่องจากเหตุที่ทำให้เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายจากศาลนั้น เกือบทุกกรณีเจ้าพนักงานจะต้องมีเหตุอันเป็นไปได้ หรือ probable cause เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการใช้อำนาจ เว้นแต่การค้นสืบเนื่องจากการจับกุม (search incident to arrest) ที่ศาลได้วางแนวคำวินิจฉัยไว้ว่าเจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจค้นตัวบุคคลและบริเวณโดยรอบบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าพนักงานหรือป้องกันการหลบหนีได้ทันทีที่จับกุมโดยไม่ต้องมีเหตุอันเป็นไปได้ ดังนั้น ในการพิจารณาของศาล หากจำเลยได้ร้องขอให้พิจารณาเพื่อไม่รับฟังพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Motion to suppress) และศาลเห็นว่า เจ้าพนักงานไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ในการค้นจริง พยานหลักฐานที่ได้จากการค้นนั้นย่อมไม่อาจรับฟังตามหลัก Exclusionary Rule

(3) การค้นตามหมายค้นที่บกพร่อง (Defective Warrant) ซึ่งแยกพิจารณาได้หลายกรณี ดังนี้

1. หมายค้นที่ออกโดยไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ หมายค้นที่ออกโดยศาลโดยไม่มี probable cause นั้น ย่อมทำให้ไม่อาจรับฟังพยานหลักฐานได้ เช่นในคดี Stone v. Powell 428 U.S. 465 (1967) อย่างไรก็ตาม หากเจ้าพนักงานมีความเชื่อโดยสุจริต (good faith) ว่าหมายค้นนั้นชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่อยู่ในบังคับของหลักการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อเกี่ยวกับความสุจริตของเจ้าพนักงานต่อไป

2. หมายค้นที่ไม่ระบุสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการค้นโดยเฉพาะ เจาะจง ศาลในคดี Andresen v. Maryland[126] ได้อธิบายความหมายของหลักความเฉพาะเจาะจงของ

---

[126]427 U.S. 463 (1976),

หมายค้นในการพิจารณาว่าเจ้าพนักงานจะต้องค้นหาสิ่งใดนั้น หมายค้นจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน โดยที่เจ้าพนักงานผู้ทำการค้นไม่ต้องใช้ดุลยพินิจใดๆ อีก

คดี Groh v. Ramirez[127] เจ้าพนักงานได้ขอให้ศาลออกหมายค้นบ้านของนาย Jeff Groh เนื่องจากเชื่อได้ว่ามีอาวุธและสารที่ใช้ในการผลิตระเบิดในการครอบครองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งแม้ว่าหมายค้นจะได้ระบุสถานที่ที่ต้องการทำการค้นอย่างชัดเจน แต่ในส่วนของการระบุสิ่งของที่ต้องการยึดกลับระบุสถานที่ที่ทำการค้นซ้ำไว้ โดยไม่ได้กล่าวถึงอาวุธที่ต้องการยึดแต่อย่างใด ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าหมายค้นดังกล่าวย่อมเสียไปเนื่องจากขัดต่อหลักหมายค้นต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามรัฐธรรมนูญ

คดี Thomas v. State[128] วินิจฉัยว่า หมายค้นระบุบ้านเลขที่เพียงแห่งเดียว ในขณะที่คำขอในการออกหมายค้นของเจ้าพนักงานระบุถนนและเลขที่บ้านซึ่งต่างจากที่ระบุในหมาย โดยไม่ได้ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านนั้น ถือว่าหมายค้นมีความบกพร่องอย่างร้ายแรง และข้ออ้างของเจ้าพนักงานว่าเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยย่อมฟังไม่ขึ้น

คดี State v. Jones[129] ได้ให้แนวทางไว้ว่าหมายค้นที่ระบุที่อยู่ผิดพลาดจะไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานก็ต่อเมื่อมีการบรรยายถึงสถานที่ที่จะทำการค้นไว้เพียงพอที่จะไม่ทำให้เจ้าพนักงานทำการค้นบ้านผิดหลัง

(4) การค้นเกินขอบเขตที่หมายกำหนดหรือเกินขอบเขตที่จะค้นได้โดยไม่มีหมาย

ในกรณีที่หมายค้นจำกัดสิ่งที่เจ้าพนักงานมีอำนาจค้น หรือเจ้าพนักงานเข้าไปค้นในที่รโหฐานเพื่อหาสิ่งของที่เป็นเหตุให้เข้าไปได้โดยไม่มีหมาย เช่น ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยจึงเข้าไปค้นหาบุคคล หากเจ้าพนักงานค้นเกินไปกว่าขอบเขตที่กำหนดโดยหมายหรือโดยที่มาของอำนาจ อีกทั้งพยานหลักฐานนั้นไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้โดยประจักษ์แจ้งตามหลัก Plain View พยานหลักฐานนั้นย่อมไม่อาจรับฟังได้

(5) การค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจ

แม้ว่าหลักการห้ามเจ้าพนักงานทำการค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนเป็นหลักการที่บัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายของสหรัฐและรัฐต่างๆ โดยไม่ได้รับรองไว้ใน

---

[127]540 U.S. 551, 564-65 (2004)

[128] 287 Ga. App. 262, 651 S.E.2d 183 (2007)

[129]Lucas App. No. L-00-1231, 2003-Ohio-219

รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ในลักษณะเดียวกับหลักการค้นต้องมีหมายค้น หรือหลักหมายค้นต้องระบุเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่และสิ่งของที่จะทำการค้น อย่างไรก็ตาม ศาลในคดี Gooding v. United States[130] วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นและยึดในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจย่อมขัดกับหลักการที่กำหนดในกฎหมาย ดังนั้น พยานหลักฐานที่เป็นผลมาจากการค้นนั้นจึงมิอาจรับฟังได้ ซึ่งคำพิพากษาในเวลาต่อๆ มาก็ได้เดินตามแนวคำพิพากษาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น

คดี State v. Fields, 691 N.W.2d 233, 238 (N. D. 2005) ศาลวินิจฉัยว่า การค้นไม่มีเหตุสมควร เนื่องจากในกรณีนี้ไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ที่จะออกหมายค้นในเวลากลางคืน เป็นผลให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยไม่มีหมายค้นที่ระบุให้ค้นในเวลากลางคืนต้องห้ามรับฟัง

(6) การไม่แสดงตัวในการค้น

หลักการแสดงตัว (Knock and Announce Rule) เป็นขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติในการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ และเหตุที่เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นแก่ผู้อยู่ในที่รโหฐานก่อนใช้กำลังเข้าตรวจค้น โดยในคดี Hudson v. Michigan[131] ศาลได้พิพากษาในข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นบ้านของนาย Hudson โดยมีหมายค้น แต่ในการแสดงตนของเจ้าพนักงานนั้น เจ้าพนักงานไม่ได้ให้เวลาแก่นาย Hudson เพียงพอ แต่กลับใช้กำลังบังคับเข้าไปบ้านของเขาแทบจะทันทีทันใดหลังจากที่ประกาศให้คนในบ้านรู้ว่าจะเข้าค้น แต่ในการค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมาก และพบปืนที่ขึ้นนกแล้วอยู่ข้างๆ ตัวนาย Hudson ศาลจึงวินิจฉัยว่าหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (Exclusionary Rule) ไม่ใช้กับการฝ่าฝืนหลักการแสดงตน และให้เหตุผลว่ากรณีที่ศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นต้องเป็นกรณีที่ผลเสียที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคมอย่างมาก ประกอบกับการเข้าไปค้นโดยไม่ปฏิบัติตามหลักการแสดงตนนั้นก็เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ไม่ว่าจะมีการฝ่าฝืนระเบียบขั้นตอนหรือไม่ ก็เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหมายค้นที่ให้อำนาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วและการค้นพบหลักฐานก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

---

[130] 416 U.S. 430, 464 (1974)

[131] 465 Mich. 932, 639 N. E. 2d 255 (2001)

3.7.1.2 ความสุจริตของเจ้าพนักงานกับการยกเว้นหลักการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลัก Good Faith หรือหลักสุจริตซึ่งเป็นข้อยกเว้นของหลักการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ Exclusionary Rule มีที่มาจากความเห็นแย้งของผู้พิพากษา White ในคดี Stone v. Powell[132] ว่า หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ ควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก เพื่อมิให้มีการใช้หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานนี้แก่กรณีพยานหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต (Good Faith) ของเจ้าหน้าที่นั้นเองว่าตนได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการและความเชื่อว่าตนปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องนั้นก็เป็นความเชื่อที่มีเหตุผล การไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเพราะการกระทำของเจ้าหน้าที่ในกรณีเช่นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลในการยับยั้งมิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการโดยมิชอบแต่อย่างใด[133]

ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับในฐานะคำพิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐในคดี United States v. Lean ที่ผู้พิพากษา White เป็นผู้ตัดสินไว้เองว่า หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปราบปรามหรือยับยั้งการกระทำอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการค้นตามหมายที่ศาลเป็นผู้ออก เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้กระทำอะไรผิด จึงไม่มีเหตุที่จะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น หากไม่รับฟังพยานหลักฐานในกรณีเช่นนี้ ก็จะมีผลทำให้จำเลยผู้ซึ่งกระทำความผิดอย่างแท้จริงรอดพ้นจากการถูกลงโทษ หรือมิฉะนั้นก็อาจได้รับการลดโทษอันเป็นผลมาจากการต่อรอง อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษา White ก็ได้กล่าวว่า อาจมีกรณีที่จะต้องไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยมีหมายอยู่เหมือนกัน เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าหมายนั้นได้ออกมาโดยชอบ เช่น คำร้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขอให้ศาลออกหมายมีข้อความที่เจ้าหน้าที่ผู้ร้องรู้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเท็จ หรือหากไม่รู้ก็ถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการที่ไม่รู้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จ หรือกรณีที่หมายนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นหมายที่บกพร่อง เช่น ไม่ระบุให้แน่ชัดถึงสถานที่ที่จะถูกค้น หรือ

---

[132] 428 U.S. 465 (1967)

[133]มโน ซอศรีสาคร, “การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ค้น ยึดโดยมิชอบ : ศึกษาเฉพาะกรณีพยานวัตถุและพยานเอกสาร,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539), น. 39.

สิ่งของที่จะถูกยึด กรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถกล่าวอ้างได้อย่างมีเหตุผลว่าหมายนั้นมีความถูกต้อง อีกกรณีหนึ่งก็คือ หากคำร้องขอให้ศาลออกหมายนั้นเป็นคำร้องที่เห็นได้ชัดว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยในการออกหมายเลย ถึงขนาดที่ว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเชื่อว่ามีเหตุอันควรสงสัยที่จะทำการค้นได้แล้ว ความเชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง[134]

คำพิพากษาในคดี Leon ได้สร้างข้อยกเว้นของหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานตามหลักความสุจริต โดยพิจารณาถึงความเชื่อที่สมเหตุสมผลของเจ้าพนักงานที่มีต่อหมายศาล เรียกว่า The "Objectively Reasonable" Test โดยเป็นการตั้งคำถามว่า ในกรณีเช่นนั้น เจ้าพนักงานที่มีเหตุมีผลและได้รับการฝึกฝนในหน้าที่มาอย่างดี (a reasonably well-trained officer) จะรู้หรือไม่ว่าหมายค้นนั้นไม่ชอบแม้จะได้ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจก็ตาม ทั้งนี้ศาลได้เน้นย้ำว่า การพิจารณาความสุจริตของเจ้าหน้าที่ต้องดูจากมาตรฐานโดยเฉลี่ยในความเชื่อของเจ้าพนักงาน การรับฟังพยานหลักฐานจึงไม่อาจกระทำได้โดยอาศัยเพียงแค่การพิสูจน์ในทางอัตวิสัยว่าเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นในคดีนั้นเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าหมายค้นนั้นได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย[135]

หลักความสุจริตนี้เป็นข้อยกเว้นของการไม่รับฟังพยานหลักฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่อาศัยหมายจากศาลเท่านั้น ส่วนกรณีที่เจ้าพนักงานกระทำการค้นโดยไม่มีหมายนั้น หากเจ้าพนักงานมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีเหตุอันเป็นไปได้ที่จะทำการค้นโดยไม่มีหมายย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว[136] ยกตัวอย่างเช่น คดี State v. Johnson[137] ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนว่า การกล่าวอ้างหลักความสุจริตเพื่อยกเว้นหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น จำกัดเฉพาะการค้นตามหมายของศาล และไม่รวมถึงการค้นสืบเนื่องจากการจับกุม

---

[134] *เพิ่งอ้าง*, น. 40-41.

[135] Aminie Woolworth, “The Good Faith Exception: "What is It Good for?" The Michigan Supreme Court Overturns Twenty Years of Precedent Holding It was Worth "Absolutely Nothing," U. Det. Mercy L. Rev, 83, 441, p. 456 (summer 2006).

[136] H. Morley Swingle, Search and Seizure Law in Missouri, (Missouri : Missouri Association of Prosecuting Attorneys, 2009), p. 37.

[137] (1988) 48 Ohio App. 3d 256.

อย่างไรก็ดี ศาลในคดี Arizona v. Evans[138] ได้นำหลักความสุจริตไปใช้กับกรณีที่ในความเป็นจริงไม่มีหมายที่ออกโดยศาล แต่เจ้าหน้าที่ของศาลได้บันทึกข้อมูลโดยผิดพลาดว่ามีการออกหมายจับ เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมบุคคลที่เชื่อว่ากระทำความผิดนั้นโดยไม่มีหมาย ศาลวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานตำรวจมีความเชื่อโดยสุจริตในข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น ด้วยเหตุนี้ พยานหลักฐานที่ได้มาสืบเนื่องจากการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจึงรับฟังได้

เช่นเดียวกับคำพิพากษาในคดี Herring v. United States[139] ซึ่งศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายและไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) เนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมโดยเชื่อถือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางการที่ระบุผิดพลาดว่ามีการออกหมายจับ Herring

3.7.2 **ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายอังกฤษ**

ตามระบบกฎหมายอังกฤษมิได้มีความเคร่งครัดต่อหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเหมือนเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตามแนวคำพิพากษาส่วนใหญ่ของศาลอังกฤษวางหลักไว้ว่าพยานหลักฐานที่มีคุณค่าอยู่ในตัวและเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีย่อมรับฟังได้เสมอ แม้ว่าจะได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังเช่นคำพิพากษาในคดีที่เป็นที่กล่าวถึงกันมากคือ คดี R v. Leathum[140] ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า

“ไม่สำคัญว่าได้พยานหลักฐานมาอย่างไร แม้จะขโมยมา พยานหลักฐานนั้นก็ยังรับฟังได้”

เช่นเดียวกับคำพิพากษาในคดี Elias v. Pasmore[141] ที่ศาลได้กล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของรัฐ เราจำเป็นต้องยอมรับว่า การยึดเอกสารมาโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นสามารถที่

---

[138](1995) 514 U.S. 1.

[139](2009) 555 U.S. 135.

[140](1861) 8 Cox CC 498.

[141](1934) 2 KB 164.

จะกระทำได้หากปรากฏว่า เอกสารนั้นแสดงหลักฐานให้เห็นได้ว่า มีการกระทำความผิดอาญาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง[142]

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่วางแนวทางการใช้ดุลยพินิจของศาลในการรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายไว้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาของศาล ใน The Police and Criminal Evidence Act 1984 หรือ PACE ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 78[143] ว่า

(1) ในกระบวนการพิจารณาใดๆ ศาลอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานซึ่งโจทก์ประสงค์จะอ้างอิง หากปรากฏต่อศาลเมื่อได้คำนึงถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้งพฤติการณ์ที่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นว่า การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นธรรมของกระบวนการพิจารณาคดีถึงขนาดที่ว่า ศาลไม่ควรรับฟังพยานหลักฐานนั้น

(2) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย ซึ่งบังคับให้ศาลไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐาน

จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มาตรา 78 ได้ให้อำนาจแก่ศาลในการใช้ดุลยพินิจที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือ การคำนึงถึงพฤติการณ์ที่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นด้วย ดังนั้น พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ เช่น พยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ค้น หรือยึดโดยมิชอบ ศาลก็อาจที่จะใช้ดุลยพินิจที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้ เช่น ศาลอาจใช้ดุลยพินิจในการไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น หากศาลเห็นว่าการรับฟังพยานหลักฐานจะกระทบต่อความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี ดังเช่น คดี R v. Shannon ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นักข่าวปลอมตัวไปชักชวนให้จำเลยร่วมค้ายาเสพติดทั้งที่

---

[142]ฐานิศร์ วรรณสุข, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 125*, น. 60.

[143]78. Exclusion of unfair evidence.

(1) In any proceedings the court may refuse to allow evidence on which the prosecution proposes to rely to be given if it appears to the court that, having regard to all the circumstances, including the circumstances in which the evidence was obtained, the admission of the evidence would have such an adverse effect on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it.

(2) Nothing in this section shall prejudice any rule of law requiring a court to exclude evidence.

มิได้ปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่า จำเลยเคยค้ายาเสพติดมาก่อนหรือไม่ โดยศาลได้ใช้ดุลยพินิจตามมาตรา 78 ของ PACE วินิจฉัยว่าการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจนี้เป็นการใช้วิธีการที่ไม่ชอบธรรมเพื่อให้ได้พยานหลักฐานจากการล่อซื้อ จึงไม่อาจนำมารับฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้[144]

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานตามแนวคำพิพากษาของศาลอังกฤษและบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบของประเทศอังกฤษที่เขียนกรอบการใช้ดุลยพินิจของศาลไว้กว้างๆ ทำให้เห็นได้ว่า ในการรับฟังพยานหลักฐานนั้น สิ่งที่ประเทศอังกฤษได้มุ่งพิจารณาเป็นสำคัญคือ คุณค่าในความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานเป็นสำคัญ

นอกจากคุณค่าในความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทำความผิดแล้ว ศาลอังกฤษในบางคดียังได้คำนึงถึงสภาพความคิดของผู้กระทำความผิดในลักษณะเดียวกับหลักความสุจริต หรือหลัก Good Faith ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เป็นการคำนึงถึงเจตนาร้าย (bad faith) หรือเจตนาสุจริต (good faith) ของเจ้าพนักงานเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าจะรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น คดี R v Walsh [145] และคดี R v Keenan[146] วินิจฉัยว่า การกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจที่ขัดต่อบทบัญญัติของ PACE หรือระเบียบที่แนบท้าย (Code of Practice) อย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญ (significant or substantial) อาจทำให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำนั้น โดยในส่วนการพิจารณาถึงสภาพจิตใจหรือความเชื่อของเจ้าพนักงานนั้น ศาลได้วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานมีเจตนาร้ายอาจทำให้ศาลเห็นว่า เจ้าพนักงานกระทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น

คดี R v Mason[147] ที่เจ้าพนักงานหลอกนาย Mason และทนายของเขาว่าเจ้าพนักงานพบชิ้นส่วนของขวดแก้วใส่น้ำมันในบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุซึ่งมีลายนิ้วมือของนาย Mason ทำให้ต่อมานาย Mason รับสารภาพ และศาลนำคำรับสารภาพนั้นมาใช้ในการพิจารณาว่าจำเลยมีความผิด ซึ่งต่อมานาย Mason ได้อุทธรณ์การรับฟังพยานหลักฐานและศาลวินิจฉัยว่าการใช้อุบายที่ทำให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพเป็นสิ่งที่ต้องตำหนิ และยังทำให้จำเลยไม่ได้รับการ

---

[144] ฐานิศร์ วรรณสุข, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 125*, น. 57-58.

[145] (1990) 91 Cr. App. R. 161

[146] (1990) 2 QB 54.

[147] (1987) 3 All ER 481.

พิจารณาที่เป็นธรรม ดังนั้น เมื่อคำรับสารภาพเป็นพยานหลักฐานอย่างเดียวในคดี จึงพิพากษายกฟ้องจำเลย

คดี R v. M เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกล่าวหาว่าสร้างพยานหลักฐานที่นำเสนอเพื่อที่จะได้มาซึ่งหมายค้น ผู้พิพากษา Heath กล่าวว่า ศาลจะต้องไม่เห็นด้วยกับการสร้างพยานหลักฐานในการฟ้องคดีในลักษณะนี้ หากกระบวนการยุติธรรมให้อภัยแก่การสร้างพยานหลักฐานเพื่อให้รับฟังพยานหลักฐานแล้วจะทำให้สังคมเสื่อมศรัทธา[148]

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในทางตรงกันข้าม การกระทำโดยสุจริตของเจ้าพนักงานไม่เป็นการเยียวยาการกระทำที่ขัดกับกฎหมายอย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับคดี R v Veneroso[149] ที่ศาล Crown Court ไม่รับฟังพยานหลักฐานที่เป็นยาเสพติดซึ่งได้มาโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 ของ PACE เนื่องจากไม่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเจ้าพนักงานจำเป็นต้องเข้าไปในที่รโหฐานเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย หรือป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อทรัพย์ของบุคคลแม้ว่าเจ้าพนักงานจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

3.7.3 ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานตามกฎหมายไทย

ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาของไทย ผลของการค้นที่รโหฐานซึ่งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดอาจแบ่งได้เป็นสองกรณี ดังนี้

3.7.3.1 การค้นโดยมิชอบ หมายความว่า การค้นโดยไม่มีอำนาจค้น ซึ่งแยกได้ดังนี้[150]

(1) การค้นที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของ (ถ้อยคำตาม ป.วิ.อ. มาตรา 57) โดยไม่มีหมายค้น เว้นแต่กรณีดังนี้

(1.1) มีกฎหมายบัญญัติให้ค้นโดยไม่มีหมายค้น เช่น ป.วิ.อ. มาตรา 92

---

[148]ชลลดา จินตเสถียร, “ข้อยกเว้นการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบตามมาตรา 226/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, 2553), น. 130.

[149](2002) Crim LR 306.

[150]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25,* น. 459-461.

(1.2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่รโหฐานยินยอมโดยสมัครใจให้ทำการค้นได้ (บรรทัดฐานของฎีกาที่ 1164/2546)

(2) การค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืน โดยไม่มีเหตุตามที่ ป.วิ.อ. มาตรา 96 (1) (2) (3) บัญญัติไว้

(3) การค้นตัวบุคคลในที่สาธารณสถาน หรือในที่รโหฐาน โดยไม่มี “เหตุอันควรสงสัย” ตามที่ ป.วิ.อ. มาตรา 93 บัญญัติไว้

(4) การค้นตัวผู้ถูกจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา 89 วรรคหนึ่งโดยเจ้าพนักงานผู้จับไม่มีอำนาจจับ

สำหรับหลักการในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยนั้น เดิมปรากฏอยู่เพียงในมาตรา 226 ซึ่งบัญญัติเพียงว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน” ซึ่งในกรณีนี้ นักกฎหมายไทยมีความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 แนวทาง คือ[151]

แนวทางแรก มีความเห็นว่า ในเรื่องถ้อยคำ แม้ตัวบทจะใช้คำว่า “เกิดจาก” หรือที่เรียกโดยทั่วไป “เกิดขึ้น” ก็ตาม แต่ก็มีความหมายเป็นเช่นเดียวกับ “การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน” กล่าวคือ หากข้อเท็จจริงปรากกว่ามีการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ หรือการค้นโดยไม่ชอบ หรือการดักฟังทางโทรศัพท์โดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจหรือการใช้วิธีการที่มิชอบในกรณีอื่นใดก็ตาม พยานหลักฐานที่ได้มาก็ย่อมไม่สามารถที่จะรับฟังได้และถูกตัดออกไปจากการพิจารณาของศาล โดยผลของมาตรา 226

แนวทางที่สอง มีความเห็นว่า การ “เกิดขึ้น” กับ วิธีการ “ได้มา” ซึ่งพยานหลักฐานมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยหลักการตามแนวความคิดนี้ มีความเห็นว่าพยานหลักฐานทุกชนิดที่มีคุณค่าแห่งการพิสูจน์และเป็นประเด็นแห่งคดีแล้ว พยานหลักฐานนั้นก็ย่อมที่จะรับฟังได้เสมอ แม้วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม และพยานหลักฐานนั้นจะไม่ถูกตัดออกไปจากการพิจารณาของศาลตามมาตรา 226 แต่อย่างใด

---

[151] ชลลดา จินตเสถียร, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 148*, น. 45.

เพราะเจตนารมณ์ของมาตรา 226 นั้น มุ่งหมายที่จะห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานเฉพาะที่เกิดขึ้นโดยมิชอบเท่านั้น

โดยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมา เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 857/2482 ก็ไม่ได้วินิจฉัยโดยตรงว่าการค้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะเป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐาน หากแต่ได้วินิจฉัยว่า

"ในข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่า เจ้าพนักงานเข้าตรวจค้นโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย และมิได้ปฏิบัติในการจับกุมของกลางตามกฎหมาย เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92, 102

ในข้อที่ว่าจำเลยได้รับสารภาพนั้น ปรากฏว่ามิได้รับสารภาพในชั้นสอบสวน ดังคำพยานนายร้อยตำรวจตรีแก้ว กมลรัตน์เจ้าพนักงานสอบสวน จำเลยรับกับนายสิบตำรวจตรีแจ้งผู้จับเท่านั้น

ในข้อเท็จจริงว่าสุรารายนี้เป็นของจำเลยหรือไม่ ก็คงมีแต่คำพยานซึ่งมีข้อสงสัยดังศาลอุทธรณ์วินิจฉัย คดีจึงลงโทษจำเลยไม่ได้ ยืนตามจำเลยอุทธรณ์ ให้ยกฎีกาโจทก์เสีย"

ในทางตรงกันข้าม คำพิพากษาฎีกาที่ 5144/2548[152] กลับวินิจฉัยว่าการตรวจค้นอาจมิชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก หามีผลทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานที่ชอบเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยไม่

จากความไม่ชัดเจนในการตีความคำว่า "เกิดขึ้นโดยมิชอบ" ประกอบกับการที่บทบัญญัติมาตรา 226 ไม่เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐาน เป็นผลให้กฎหมายไทยในเรื่องนี้อยู่ในสภาพที่เคร่งครัด ซึ่งแตกต่างจากระบบที่ใช้อยู่เป็นสากลที่มีการสร้างข้อยกเว้นให้สามารถการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี้ จึงนำไปสู่การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 226/1 ดังที่ปรากฏในคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า "บทบัญญัติมาตรา 226 ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากได้รวมกฎหมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่อาจอ้างได้ในคดีอาญา และส่วนที่เกี่ยวกับข้อห้ามในการรับฟัง

---

[152] คำพิพากษาฎีกาที่ 5144/2548 ฎส. 10 น. 1862.

พยานหลักฐานไว้ในมาตราเดียวกัน นอกจากนี้บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับข้อห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบมีลักษณะค่อนข้างเด็ดขาด ไม่สอดคล้องกับแนววินิจฉัยของศาลที่ยอมรับฟังพยานดังกล่าวในบางกรณีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อความเป็นธรรม สมควรที่จะแยกบทบัญญัติในเรื่องการอ้างพยานหลักฐานและในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานตามมาตรานี้ออกจากกัน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น"[153] ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เป็นการยกเลิกมาตรา ๒๒๖ เดิม เพื่อกำหนดเรื่องการอ้างพยานหลักฐานว่า "พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยผิดหรือบริสุทธิ์หรือเกี่ยวกับประเด็นอื่นในคดี ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ โดยให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน" และเพิ่มมาตรา 226/1 เรื่องการรับฟังพยานหลักฐานในวรรคหนึ่งว่า "ถ้อยคำของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กำลังบังคับ หรือกระทำโดยมิชอบประการใดๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้" และวรรคสอง " พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญอันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้"[154] อย่างไรก็ดี ได้มีการชะลอการพิจารณาร่างมาตราดังกล่าว และต่อมาในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเสนอร่างของคณะรัฐมนตรีอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นการเสนอเพิ่มมาตรา 226/1 ที่มีเนื้อหาตามที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน[155]

ทั้งนี้ ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลของการค้นโดยมิชอบโดยกฎหมายนี้ ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ว่า การค้นโดยมิชอบดังกล่าวข้างต้น

---

[153] สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... น. 70.

[154] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 130/2544).

[155] สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 153, น. 47-48.

มีผลต่อการรับฟังพยานหลักฐานหรือผลในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ หากค้นแล้วพบพยานวัตถุ พยานเอกสาร จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ เพราะถือว่าได้มาโดยมิชอบประการอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 226 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีมาตรา 226/1 บัญญัติขึ้นมาใหม่ ก็คงต้องถือว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร” ที่ได้มาจากการค้นโดยมิชอบ เป็น “พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ” ตามความหมายของมาตรา 226/1 ซึ่งศาลอาจใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานดังกล่าวได้ โดยมาตรา 226/1 เป็นการยืนยันหลักในมาตรา 226 ที่ว่า พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบรับฟังไม่ได้ แต่เนื่องจากพยานหลักฐานนั้นๆ เป็น “พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ” ศาลอาจใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานวัตถุนั้นได้ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 226/1 และคำพิพากษาศาลฎีกาในฎีกาที่ 5144/2548 คงจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 226/1 กล่าวคือ โดยหลักจะต้องไม่รับฟัง หากจะใช้ดุลยพินิจรับฟัง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรา 226/1 เท่านั้น[156]

ปัญหาว่า ปัจจัยที่ศาลจะต้องคำนึงถึงในการใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามมาตรา 226/1[157] วรรคสอง (1) – (4) มีความหมายอย่างไรนั้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน ปัจจัยเรื่องนี้มีนักกฎหมายหลายท่านได้อธิบายความหมายไว้ ดังนี้

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อธิบายว่า คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น กล่าวคือถ้าเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือมาก สามารถบ่งข้อเท็จจริงอันสำคัญในคดีนั้นได้มาก โอกาสที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจยกเว้น

---

[156]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น. 460-462.

[157] มาตรา 226/1 ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน

ให้รับฟังได้ก็จะมากตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่สำคัญ ซ้ำยังมีน้ำหนักน้อยอีกด้วย ศาลก็น่าจะใช้ดุลยพินิจไปในทางตัดทิ้งไปตามหลักที่กฎหมายวางไว้[158]

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ อธิบายว่าถ้าเป็นพยานสำคัญ น่าเชื่อถือและใกล้ชิดกับประเด็นพิพาท คือมีคุณค่าในเชิงพิสูจน์ (probative value) สูง ก็ควรยกเว้นให้รับฟังได้[159]

ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย อธิบายว่า คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น หมายความว่าพยานหลักฐานนั้นมีคุณค่าต่อการพิสูจน์ความจริงเพียงใด เช่นเป็นพยานชั้นที่หนึ่ง หรือเป็นพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ประเด็นโดยตรงของการกระทำนั้น และเป็นพยานหลักฐานที่ยังมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เกิดขึ้นแต่เดิม[160]

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต อธิบายว่า หากการได้มาซึ่งพยานหลักฐานโดยมิชอบในบางกรณีก็ไม่มีผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน เช่น การค้นโดยไม่มีหมายค้นและพบสิ่งของผิดกฎหมาย[161]

ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดี โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น

(2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี

(3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ

(4) ผู้ที่กระทำการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด

[158]จรัญ ภักดีธนากุล, <u>คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน</u>, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553), น. 285.

[159]เข็มชัย ชุติวงศ์, <u>คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน</u>, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร ; สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2551), น. 282.

[160]คนึง ฦาไชย, <u>กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2</u>, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 279.

[161]อุดม รัฐอมฤต, <u>คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน</u>, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น. 227.

2. พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อธิบายว่า พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดีที่จำเลยถูกฟ้องมีความชั่วร้ายรุนแรงเพียงใด กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนมากหรือน้อยอย่างไร ถ้าความผิดในคดีนั้นไม่ร้ายแรง ความจำเป็นที่จะต้องลงโทษจำเลยอย่างจริงจังก็น้อยลง โอกาสที่ศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ หรือที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบนั้นก็จะมากขึ้น แจ่ถ้าความผิดในคดีนั้นร้ายแรงมาก ประโยชน์สาธารณะที่จะต้องพิสูจน์ความผิดและลงโทษจำเลยก็มาก โอกาสที่จะใช้ดุลยพินิจให้รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวตามข้อยกเว้นก็มีมากขึ้นด้วย[162]

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ อธิบายว่า ถ้าความผิดในคดีที่จะต้องใช้พยานหลักฐานนั้นพิสูจน์ เป็นความผิดอุทฉกรรจ์ หรือความผิดร้ายแรง ก็ควนยกเว้นให้รับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ เพราะการไม่รับฟังพยานหลักฐานจะทำให้คนร้ายในคดีร้ายแรงหลุดรอดไปได้[163]

3. ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล อธิบายว่า ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำมิชอบของเจ้าหน้าที่มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานอย่างผิดกฎหมายผิดศีลธรรม ทำให้เสื่อมเสียต่อการอำนวยความยุติธรรมของประเทศมากหรือทำให้เสียหายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ศาลก็น่าจะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นไปตามหลัก แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดเพียงเล็กน้อยเสียหายไม่มาก ศาลก็น่าจะใช้ดุลยพินิจให้รับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ตามข้อยกเว้น[164]

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ อธิบายว่า ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ หมายถึง ลักษณะการกระทำมิชอบของเจ้าพนักงาน และความเสียหายที่เกิดจากการกระทำมิชอบของเจ้าพนักงานถ้าร้ายแรง ก็ไม่ควรรับฟัง[165]

---

[162]จรัญ ภักดีธนากุล, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 158*, น. 285.

[163]เข็มชัย ชุติวงศ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 159*, น. 282.

[164]จรัญ ภักดีธนากุล, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 158*, น. 285.

[165]เข็มชัย ชุติวงศ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 159*, น. 282.

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต อธิบายว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังซ้อมผู้ต้องหา หรือบังคับขู่เข็ญให้รับสารภาพย่อมเกิดความเสียหายมาก เพราะกระทบสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิที่จะไม่ปรักปรำตนเอง[166]

นอกจากนี้ชลลดา จินตเสถียร ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ลักษณะและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยมิชอบ หมายถึง เมื่อพิจารณาการกระทำที่ไม่ชอบของเจ้าพนักงานว่ามีลักษณะอย่างไร ระดับความรุนแรงหรือความร้ายแรงของการกระทำของเจ้าพนักงานว่าเป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานอย่างร้ายแรงหรือไม่เทียบกับความบกพร่องที่เกิดขึ้น ถ้าร้ายแรงมากก็ไม่ควรรับฟัง ถ้าร้ายแรงน้อยก็ควรรับฟัง เช่น ตำรวจเข้าไปค้นบ้านหรือไปค้นบริษัทเขาโดยมีหมายค้นเข้าไปโดยชอบ เอาหมายค้นให้คนในนั้นดู ปรากฏว่าในบันทึกตรวจค้นจับกุมอาจจะลืมลงชื่อใครไปสักคน จะเห็นว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้ก่อความเสียหายอะไร และก็มีความร้ายแรงน้อยมาก ไม่ได้ทำให้เกิดความตกใจหวาดกลัวอะไรเลย เป็นการบกพร่องทางเทคนิค ซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นน้อยมากก็ควรรับฟังพยานหลักฐานชิ้นนั้น และควรพิจารณาถึงความสุจริตของเจ้าพนักงานด้วย คือ หากเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความสุจริตใจว่าตนทำถูกต้องตามกฎหมาย การไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเพราะการกระทำของเจ้าหน้าที่ในกรณีเช่นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลยับยั้งมิให้เจ้าพนักงานกระทำการโดยมิชอบแต่อย่างใด แต่หากเจ้าพนักงานมีการกระทำโดยทุจริตอย่างชัดแจ้งหรือมีการกระทำที่ชั่วร้ายมาก มีความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ไม่ให้รับฟังพยานหลักฐาน[167]

4. ผู้ที่กระทำการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ อธิบายว่า ผู้ที่กระทำการมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมาได้รับการลงโทษหรือไม่ ถ้าเจ้าพนักงานที่ล่วงละเมิดสิทธิอันทำให้ได้พยานหลักฐานมาถูกดำเนินคดีลงโทษไปแล้วก็ถือว่ามีการเยียวยาการกระทำไม่ชอบไปแล้ว ก็สามารถรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้เพราะการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบเป็นการลงโทษ (sanction) รัฐอย่างหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกลงโทษทางอื่นแล้ว ก็ไม่ต้องใช้มาตรการนี้อีก[168]

---

[166]อุดม รัฐอมฤต, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 161*, น. 227.

[167]ชลลดา จินตเสถียร, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 148*, น. 129.

[168]เข็มชัย ชุติวงศ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 159*, น. 282.,

ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย อธิบายว่า ผู้ที่ทำการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมาได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด หมายความว่า ผู้ที่ก่อให้เกิดการได้มาโดยมิชอบได้ถูกดำเนินคดีอาญาในส่วนที่กระทำโดยมิชอบเพียงใด ทั้งนี้ เพราะหลักการไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานโดยมิชอบนี้ เป็นมาตรการที่บังคับอีกทางหนึ่งที่ศาลในต่างประเทศนำมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ดังนั้น หากเจ้าพนักงานเหล่านั้นได้รับการลงโทษแล้ว ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบเพื่อยับยั้งอีก[169]

1.3.2 มีอำนาจค้น แต่กระทำการหรือไม่กระทำการบางประการ ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ จึงไม่ต้องปรับใช้มาตรา 226/1 เพื่อรับฟังพยานหลักฐาน โดยศาลฎีกาได้มีแนวคำพิพากษาให้รับฟังพยานหลักฐานในลักษณะนี้ได้อยู่แล้ว ดังต่อไปนี้[170]

1. การบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นละสิ่งของที่ค้นได้ตามมาตรา 102, 103

คำพิพากษาฎีกาที่ 837/2483 วินิจฉัยว่า ข้อปฏิบัติในบทมาตรา 102, 103 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นแต่กำหนดวิธีการอันหนึ่งที่เจ้าพนักงานจะต้องกระทำ ไม่ได้บังคับว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นแล้ว จะไม่ให้ฟังเสียเลยว่าได้ค้นของกลางได้ที่บ้านของจำเลย จริงอยู่การที่ไม่มีบันทึกให้จำเลยรับรู้ไว้แล้ว ศาลก็จำต้องระมัดระวังพะยานบุคคลที่โจทก์นำมาสืบในข้อได้ของกลางที่บ้านของจำเลย แต่เฉพาะคดีนี้ศาลเห็นว่า พะยานบุคคลของโจทก์ฟังได้โยปราศจากระแวงสงสัยว่าจับของกลางได้ที่บ้านจำเลยทั้งสิ้น ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

2. การค้นไม่ได้กระทำต่อหน้าบุคคลอย่างน้อยสองคนตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง

คำพิพากษาฎีกาที่ 392/2519 วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานตำรวจค้นบ้านผู้ต้องหาต่อหน้าคนในบ้านคนหนึ่งซึ่งตาบอดทั้งสองข้างและหูหนวก กับบุคคลอีกคนหนึ่งที่ได้เชิญมาเป็นพยานในการค้นด้วยนั้น เมื่อไม่ได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจสามารถทำการค้นต่อหน้าคนอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วได้ จึงอาจเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจกระทำเท่าที่สามารถจะกระทำได้และไม่อาจจะหาบุคคลอื่นใดมาเป็นพยานในการค้นมากไปกว่านั้น ถือได้ว่าเป็นการค้นที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 102 แล้ว

---

[169]คนึง ฦาไชย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 160*, น. 279.

[170]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25*, น. 468-470.

3. เจ้าพนักงานแก้ไขเลขที่บ้านตามหมายค้นให้ตรงกับบ้านที่ค้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 6475/2547[171] วินิจฉัยว่า ศาลออกหมายค้นบ้านของจำเลยตามหมายค้นเอกสารหมาย จ. 1 โดยระบุเลขที่บ้านเป็นเลขที่ 74 ตามที่เจ้าพนักงานตำรวจร้องขอ การที่ ร.ต.อ. ก. แก้เลขที่บ้านในหมายค้นเป็นเลขที่ 161 เพื่อให้ตรงกับความจริงโดยไม่มีอำนาจ อันอาจมีผลให้หมายค้นเสียไปและการค้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เมื่อปรากฏว่าคดีมีการสอบสวนกันโดยชอบ ทั้งในชั้นพิจารณาจำเลยก็นำสืบรับว่าเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลางฝังอยู่ในดินห่างจากบ้านของจำเลยประมาณ 3 เมตร พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาย่อมรับฟังลงโทษจำเลยได้

4. หมายค้นระบุเลขที่บ้านที่จะค้นผิดไป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1328/2544[172] วินิจฉัยว่า นายดาบตำรวจ ว. ค้นบ้านของจำเลยโดยมีหมายค้นส่วนที่หมายค้นระบุเลขที่บ้านผิดไปหามีผลทำให้หมายค้นเสียไปไม่ การค้นบ้านจำเลยจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 35

คำพิพากษาฎีกาที่ 3479/2548[173] จำเลยทั้งสี่นำสืบยอมรับว่าถูกจับกุมในห้องเช่าที่เกิดเหตุและเจ้าพนักงานตำรวจได้เมทแอมเฟตามีนเป็นของกลางจริง แม้จะปรากฏว่าห้องเช่าดังกล่าวเลขที่ 82/16 ไม่ใช่เลขที่ 105 ตามที่ระบุในหมายค้น แต่ตามหมายค้นดังกล่าวได้ระบุเหตุที่ขอออกหมายค้นว่า การสืบสวนทราบว่าที่บ้านจำเลยที่ 1 เลขที่ 105 ห้องเช่า มียาเสพติดให้โทษซุกซ่อนอยู่ในบ้านหรือบริเวณบ้านจึงขอให้ศาลออกหมายค้น โดยระบุชื่อและนามสกุลจำเลยที่ 1 ไว้ถูกต้อง และร้อยตำรวจโท บ. ผู้จับกุมซึ่งเป็นผู้ขอออกหมายค้นดังกล่าวก็เบิกความระบุสาเหตุที่ระบุเลขที่บ้านในหมายค้นว่าบ้านเลขที่ 105 เพราะสายลับระบุเช่นนั้น เมื่อเข้าจับกุมจึงปรากฏว่าเป็นบ้านเลขที่ 82/16 จึงเป็นการขอออกหมายค้นเพื่อตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 1 การระบุเลขที่บ้านผิดไม่ทำให้การตรวจค้นจำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ การตรวจค้นโดยมีหมายค้นกรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

---

[171] คำพิพากษาฎีกาที่ 6475/2547 ฎส. 7 น. 194.

[172] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1328/2544 ฎส. 3 น. 107.

[173] คำพิพากษาฎีกาที่ 3479/2548.

3.7.4 ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต่อความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงาน

การใช้อำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการค้นที่รโหฐานของเจ้าพนักงานในบางกรณีเป็นการใช้อำนาจโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายหรือกระทำการโดยประมาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นนอกจากผลในทางวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว กฎหมายในประเทศต่างๆ จึงได้ใช้มาตรการในทางอาญาควบคู่ไปกับมาตรการในทางแพ่งเพื่อลงโทษการกระทำในลักษณะดังกล่าวของเจ้าพนักงาน ซึ่งสามารถศึกษาการกำหนดความรับผิดในทางอาญาของเจ้าพนักงานในการค้นสถานที่ของบุคคลได้ ดังต่อไปนี้

3.7.4.1 ความรับผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

ตาม Title 18 ของ U.S. Code ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นและยึดในที่รโหฐานไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ ความผิดดังต่อไปนี้

1. ความผิดฐานใช้อำนาจเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหมายค้น

มาตรา 2234[174] บัญญัติว่า ผู้ใด ในการใช้อำนาจตามหมายค้น โดยรู้ว่าการใช้อำนาจของตนเกินไปกว่าที่หมายให้อำนาจ หรือใช้อำนาจตามหมายค้นเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับตามกฎหมายนี้ หรือโทษจำคุกไม่เกินนี้ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

2. ความผิดฐานทำให้ได้มาซึ่งหมายค้นโดยเจตนาทุจริต

มาตรา 2235[175] บัญญัติว่าผู้ใดโดยเจตนาทุจริตและโดยไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ทำให้มีการออกหมายค้นและใช้อำนาจตามหมายค้นนั้น ต้องระวางโทษปรับตามกฎหมายนี้ หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

---

[174] § 2234. Authority exceeded in executing warrant.

Whoever, in executing a search warrant, willfully exceeds his authority or exercises it with unnecessary severity, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

[175] § 2235. Search warrant procured maliciously.

3. ความผิดฐานค้นโดยไม่มีหมายค้น

มาตรา 2236[176] ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานหรือองค์การของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ทำการค้นที่รโหฐานที่ใช้ในการอยู่อาศัยของบุคคลโดยไม่มีหมายที่ให้อำนาจค้นได้โดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยเจตนาทุจริตและไม่มีเหตุผลสมควร ทำการค้นสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินของบุคคลโดยไม่มีหมาย ต้องระวางโทษปรับตามกฎหมายนี้ในความผิดครั้งแรก และหากยังกระทำผิดอีกให้ระวางโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้

(1) บุคคลที่ค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมบุคคลตามหมาย

(2) บุคคลที่จับกุมหรือพยายามจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า บุคคลที่ได้กระทำความผิด หรือต้องสงสัยบนพื้นฐานความมีเหตุผลว่าได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง หรือ

(3) บุคคลผู้กระทำการค้นตามคำร้องขอหรือความยินยอมของผู้ครอบครองที่รโหฐานนั้น

ส่วนการกระทำที่ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดที่เป็นบทเฉพาะข้างต้นก็อาจเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิของบุคคลตามมาตรา 242 ของ Title 18 ซึ่งมีที่มาเดียวกันกับความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ตาม Title 42 มาตรา 1982 ซึ่งเป็นการรับรองหลักการตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่ ดังนี้

Whoever maliciously and without probable cause procures a search warrant to be issued and executed, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

[176]§ 2236. Searches without warrant.

Whoever, being an officer, agent, or employee of the United States or any department or agency thereof, engaged in the enforcement of any law of the United States, searches any private dwelling used and occupied as such dwelling without a warrant directing such search, or maliciously and without reasonable cause searches

มาตรา 242[177] ผู้ใดเจตนากระทำต่อบุคคลอื่น อันเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ เอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันหรือความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการลงโทษบุคคลในรัฐอื่น หรือบุคคลที่มีความแตกต่างทางสีผิว เชื้อชาติ ให้แตกต่างไปจากที่กระทำต่อบุคคลในรัฐ ให้ระวางโทษปรับตามกฎหมายนี้ หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

---

any other building or property without a search warrant, shall be fined under this title for a first offense; and, for a subsequent offense, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

This section shall not apply to any person—

(a) serving a warrant of arrest; or

(b) arresting or attempting to arrest a person committing or attempting to commit an offense in his presence, or who has committed or is suspected on reasonable grounds of having committed a felony; or

(c) making a search at the request or invitation or with the consent of the occupant of the premises.

[177]Sec. 242. Deprivation of rights under color of law.

Whoever, under color of any law, statute, ordinance, regulation, or custom, willfully subjects any person in any State, Territory, Commonwealth, Possession, or District to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured or protected by the Constitution or laws of the United States, or to different punishments, pains, or penalties, on account of such person being an alien, or by reason of his color, or race, than are prescribed for the punishment of citizens, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both; and if bodily injury results from the acts committed in violation of this section or if such acts include the use, attempted use, or threatened use of a dangerous weapon, explosives, or fire, shall be fined under this title or imprisoned

หากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของบุคคลเนื่องมาจากผลของการใช้ พยายามจะใช้ หรือข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธร้ายแรง ระเบิด หรือไฟ ให้ระวางโทษปรับตามกฎหมายนี้ หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากความตายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว หรือการกระทำดังกล่าวมีการลักพาตัว พยายามลักพาตัว การข่มขืนกระทำชำเรา พยายามข่มขืนกระทำชำเรา หรือพยายามฆ่ารวมอยู่ด้วย ให้ระวางโทษปรับตามกฎหมายนี้ หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือประหารชีวิต

องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานนี้คือ

1. การกระทำของผู้กระทำความผิดเป็นการขัดขวางหรือทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิหรือเอกสิทธิ์ของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ

2. กระทำความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

3. การกระทำความผิดเกิดขึ้นโดยเจตนา

ศาลสูงสุดของสหรัฐในคดี Screws v. United States[178] ได้วินิจฉัยว่า willfully เป็นเจตนาร้ายที่กฎหมายประสงค์ตำหนิ อย่างไรก็ตาม ต้องประกอบด้วยการพิสูจน์เจตนาพิเศษเพื่อทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายรับรอง การที่โจทก์แสดงให้ศาลเห็นว่าจำเลยละเลยไม่เอาใจใส่หลักประกันตามรัฐธรรมนูญย่อมเพียงพอที่ศาลจะลงโทษการกระทำความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ เจตนาที่จะทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิของบุคคลอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเจตนาชัดแจ้ง แต่ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ดังที่ศาลในคดี United States v. Hayes วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานจับกุมผู้ตายตามหมายที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้พาไปยังที่รกร้างและทำร้ายด้วยการตีด้วยลำกล้องปืนเป็นเหตุให้ปืนลั่นโดนผู้ถูกจับกุมถึงแก่ความตายนั้น การกระทำของจำเลยเป็นการทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิในชีวิตและเสรีภาพของผู้ตาย จึงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต

---

more than ten years, or both; and if death results from the acts committed in violation of this section or if such acts include kidnapping or an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse, or an attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill, shall be fined under this title, or imprisoned for any term of years or for life, or both, or may be sentenced to death.

[178] 325 U.S. 91 (1945)

และหากเจ้าพนักงานตั้งแต่สองคนขึ้นไปสมคบกันกระทำการโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิหรือเอกสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจเป็นความผิดตามมาตรา 241 ของ Title 18 ด้วย ทั้งนี้ การฟ้องคดีอาญาตามมาตรา 241 และมาตรา 242 เป็นอำนาจของรัฐที่ต้องกระทำโดยกระทรวงยุติธรรมหรืออัยการสหรัฐเท่านั้น

การใช้อำนาจค้นของเจ้าพนักงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น นอกจากจะมีความรับผิดอาญาตามกฎหมายในระดับสหรัฐ หรือ Federal law แล้ว ยังอาจมีความรับผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของแต่ละรัฐ (State Penal Code) ในความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เช่น ความผิดฐานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจข่มขู่บังคับ (Official oppression) และความผิดฐานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (Official misconduct) รวมถึงความผิดฐานบุกรุก (Trespass) ด้วย

ตัวอย่างความผิดฐานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และความผิดฐานบุกรุก เช่น

มาตรา 195[179] แห่งประมวลกฎหมายอาญาของรัฐนิวยอร์ก บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีเจตนาให้ผู้อื่นเสียสิทธิประโยชน์ที่เขาควรได้รับ

มาตรา 140.10 มาตรา 140.15 และมาตรา 140.17 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของรัฐนิวยอร์ก กำหนดให้ความผิดฐานบุกรุกเป็นการกระทำความผิดเมื่อบุคคลมีเจตนาเข้าไปหรืออยู่ในทรัพย์สิน (enter or remain) ของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยแบ่งความผิดออกเป็นสามระดับ คือ

---

[179]Sec. 195. Official misconduct.

A public servant is guilty of official misconduct when, with intent to obtain a benefit or deprive another person of a benefit:

1. He commits an act relating to his office but constituting an unauthorized exercise of his official functions, knowing that such act is unauthorized; or

2. He knowingly refrains from performing a duty which is imposed upon him by law or is clearly inherent in the nature of his office.

Official misconduct is a class A misdemeanor.

มาตรา 140.10 การเข้าไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในสิ่งปลูกสร้างหรืออสังหาริมทรัยพ์ของบุคคลอื่น (Criminal trespass in the third degree)

มาตรา 140.15 การเข้าไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่น (Criminal trespass in the second degree) และ

มาตรา 140.17 การเข้าไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นโดยมีอาวุธร้ายแรง (Criminal trespass in the first degree)

3.7.4.2 ความรับผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้นที่รโหฐานตามกฎหมายอังกฤษ

การเข้าค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีอำนาจ ทำให้เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ค้นในที่รโหฐานต้องมีความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายอังกฤษในความผิดฐานบุกรุกหรือมีความรับผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนี้

1. ความรับผิดอาญาฐานบุกรุก (Criminal Trespass)

การบุกรุกเข้าไปในทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (trespass on land) อาจทำให้เกิดทั้งความรับผิดในทางแพ่งและอาญา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงการกระทำที่เป็นการบุกรุกแล้ว จะเป็นเรื่องที่นักกฎหมายอังกฤษเห็นว่าหมายถึงความรับผิดในทางแพ่ง หรือ Tort เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความผิดอาญาฐานบุกรุกในระบบกฎหมายอังกฤษก็ยังมีเหลืออยู่ ดังที่ปรากฏในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติกฎหมายอาญา หรือ Criminal Law Act 1977 ในส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเข้าไปและอยู่ในสถานที่ (Part II Offences Relating to Entering and Remaining on Property) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ผู้ใดเข้าไปในเคหสถานในลักษณะของการบุกรุก ให้มีความผิดเมื่อบุคคลดังกล่าวไม่ยอมออกจากสถานที่นั้นเมื่อได้มีการร้องขอให้ออก โดยผู้ครอบครองสถานที่นั้นแทนเจ้าของ หรือผู้ที่ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินระดับ 5 ของตารางหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยคำว่า “สถานที่” หรือ “premises”[180] ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงสิ่งก่อสร้าง ส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างที่มีผู้ครอบครองแยกต่างหากจากกัน พื้นดินบริเวณที่ปลูกสิ่งก่อสร้าง และบริเวณที่ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างกับที่ดินนั้น

---

[180] “premises” means any building, any part of a building under separate occupation, any land ancillary to a building, the site comprising any building or buildings together with any land ancillary thereto, and (for the purposes only of sections 10 and 11 above) any other place; and [...]

2. ความรับผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (Misconduct/ Misfeasance in public office) ความผิดฐานนี้เป็นความผิดตามกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งมีองค์ประกอบของความผิดคือ

(1) เจ้าพนักงานมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

(2) โดยเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

(3) การกระทำโดยมิชอบนั้นมีความร้ายแรงถึงขนาดที่กระทบต่อความเชื่อถือของประชาชน

(4) เจ้าพนักงานนั้นไม่อาจอ้างความยุติธรรมหรือข้อยกเว้นที่สมเหตุสมผล

จากองค์ประกอบข้างต้นจะเห็นได้ว่าการกระทำที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีขอบเขตที่กว้างมาก และเนื่องจากการกระทำความผิดฐานนี้มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต การพิจารณาถึงองค์ประกอบตาม (3) จึงมีความสำคัญต่อการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดในฐานนี้อย่างยิ่ง ดังนั้น การกระทำที่จะถือว่ามีความร้ายแรงถึงขนาดที่กระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนจึงหมายความว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นควรจะมีผลเป็นการทำลายประโยชน์สาธารณะ[181]

3.7.4.3 ความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงานตามกฎหมายไทย

การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีอำนาจค้น ซึ่งได้แก่ การค้นโดยไม่มีหมายค้น การค้นโดยไม่มีเหตุให้ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นตามมาตรา 92 และการค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีเหตุตามมาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อาจทำให้เจ้าพนักงานมีความรับผิดตามกฎหมายอาญา ในมาตรา ดังต่อไปนี้

---

[181]The Crown Prosecution Service, “Misconduct In Public Office, ” <http://www.cps.gov.uk/legal/l_to_o/misconduct_in_public_office/>.

(1) ความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364[182] หรือความผิดตามมาตรา 329[183] ของกฎหมายลักษณะอาญา มีตัวอย่างคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ฎีกา 754/2498[184] คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของโจท์กล่าวคำใส่ความและด่าโจทก์ ใช้ปืนพยายามยิงโจทก์จะฆ่าให้ตาย และกล่าวคำอาฆาตมาดร้ายต่อโจทก์ ขอให้ลงโทษตามมาตรา 327, 328, 29, 39 (2),429, 60, 30, 70, 71 ศาลอุทธรณ์เห็นว่าตามข้อเท็จจริงไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคนร้ายเข้าไปในบ้านโจทก์ กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (2) หรือมาตรา 96 (2) จำเลยต้องรับผิดฐานบุกรุก จึงพิพากษาแก้ว่าจำเลยมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 329 วรรคท้าย จำเลยฎีกาว่า กรณีมีเหตุที่จำเลยควรสงสัยว่าคนร้ายเข้าไปอยู่ในบ้านโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้แต่ตามคำของจำเลยเองก็ไม่ปรากฏว่าคนที่จำเลยเห็นมาเดินอยู่ข้างบ้านนายเพิ่มนั้นได้กระทำความผิดแต่อย่างใด และการที่จำเลยไปถามนายร่วมและถามโจทก์ ก็แสดงอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าคนนั้นไปทางไหน จึงไม่มีเหตุจะควรสงสัยว่าคนร้ายได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในบ้านของโจทก์ ฉะนั้นที่จำเลยฎีกาว่ามีเหตุที่จำเลยควรสงสัยว่าคนร้ายเข้าไปอยู่ในบ้านโจทก์จึงฟังไม่ได้ กรณีมิต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 หรือ 96 จำเลยหาพ้นผิดไม่

ฎีกา 246/2515[185] จำเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับแจ้งจาก บ. ให้ติดตามสืบถามขอคืนไม้ที่หายจากโจทก์ว่า เห็นโจทก์เอาไม้ไป จำเลยกับพวกก็เข้าค้นเรือนโจทก์รื้อข้าวของกระจัดกระจาย ทั้งนี้ โดยไม่มีหมายค้น บิดาโจทก์ห้ามก็ไม่ฟัง ทั้งไม่ได้ความแน่ชัดด้วยว่า ไม้นั้นอยู่ในเรือนโจทก์ ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกเรือนโจทก์แล้ว ไม่เข้า

---

[182]มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคาร เก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[183]มาตรา 329 ผู้ใดมิได้มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แลมันบังอาจเหข้าไปในเคหะสถานของผู้อื่น หรือในรั้วเขตร์ของเคหะสถานผู้อื่น หรือเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในที่นั้นๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควรที่จะเข้าไปก็ดี หรือว่าเมื่อผู้มีความชอบธรรมที่จะห้ามได้ ได้ขับไล่ให้มันออกไปมันยังขืนอยู่ในที่นั้นๆ ก็ดี ท่าว่ามันผู้กระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่ามานี้ ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

[184]คำพิพากษาฎีกาที่ 754/2498 (เนติ 1), น. 690.

[185]คำพิพากษาฎีกาที่ 246/2515 (เนติ 1), น. 180.

ข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4)(5) แต่การกระทำของจำเลยเป็นการเข้าไปในเคหสถานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยมีเจตนารบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุขด้วย จึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 และ 365 ให้ลงโทษตามมาตรา 365

(2) ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 157[186] ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแบ่งออกเป็นสองความผิด คือ

1. ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของความผิด คือ เจ้าพนักงานผู้กระทำผิดมีหน้าที่นั้นๆ โดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย เจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือทำให้รัฐเสียหาย

การกระทำที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 ในส่วนแรกนี้ได้แก่[187]

การประวิงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ล่าช้า ทั้งที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานโดยเร็ว

เจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การไม่ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพื่อให้ทางราชการเสียหาย หรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเดือดร้อน

การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามอำเภอใจโดยปราศจากเหตุผล

การปฏิบัติหน้าที่โดยมีเจตนากลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย

การจัดทำรายงานหรือเอกสารใดในหน้าที่ของตนเป็นความเท็จหรือไม่ตรงต่อความจริง

---

[186]มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[187]ภาสกร ฌาณสุธี, คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน, (สำนักพิมพ์นิติบรรณการ : กรุงเทพมหานคร , 2552), น. 72-73.

การปฏิบัติงานใดๆ ในหน้าที่ของตนในลักษณะเดียวกัน แต่ปฏิบัติงานให้มีความยุ่งยากต่างกันมาก เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติตามอำเภอใจโดยปราศจากเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอาจแบ่งออกได้เป็นสองกรณีคือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการและการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบซึ่งหมายถึงวิญญูชนไม่สามารถยอมรับได้ว่ามีเหตุผล

2. ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต มีองค์ประกอบความผิดคือ บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงาน เจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือโดยมิชอบก็ได้ และมีเจตนาพิเศษโดยทุจริต กล่าวคือกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการค้นที่รโหฐาน ได้แก่กรณีที่เจ้าพนักงานทำการค้นโดยเจตนาเอาทรัพย์ไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

(3) ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358[188]

ทั้งนี้ มีตัวอย่างคำพิพากษาของศาลที่ระบุว่าการค้นโดยไม่มีอำนาจทำให้เจ้าพนักงานมีความผิดฐานบุกรุก ฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และฐานทำให้เสียทรัพย์ ดังนี้

คำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ. 464/2549 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1-4 ว่าเป็นพนักงานสอบสวน ได้ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ บุกรุก และทำให้เสียทรัพย์ โดยจำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับสถานบริการและอบายมุข ได้สั่งการให้จำเลยที่ 2-4 บุกรุกเข้าไปตรวจค้นที่พักของโจทก์ในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจเข้าตรวจค้นได้ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 2-4 ร่วมกันบุกรุกปีนรั้วประตูบ้านจนขาด แตกหักเสียหายใช้ไม่ได้ ทำให้เสียทรัพย์ ทั้งที่คนดูแลบ้านของโจทก์ได้ห้ามปรามไม่ให้ปีนรั้วเข้าบริเวณบ้าน แต่จำเลยที่ 2-4 อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมแสดงบัตร

---

[188]มาตรา 358 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และไม่แสดงหมายค้นให้ดู การกระทำของจำเลยทั้ง 4 เป็นการการบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง ขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 157, 358, 364, และ 365 (2)

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยที่ 2-4 ร่วมกันกระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ 2-4 กระทำผิดหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2-4 แต่จะสรุปว่าเป็นคนสั่งให้จำเลยที่ 2-4 ไปตรวจค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายค้นนั้นคงไม่ได้ โดยโจทก์ได้เข้าไปต่อว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 น่าจะสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีหมายค้นหรือไม่ แต่ไม่ได้สอบถาม จึงเป็นผู้สนับสนุนที่จะต้องรับผิดทางอาญานั้น ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าจำเลยที่ 1 ร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2-4 จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 1 พิพากษาว่า จำเลยที่ 2-4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นบทลงโทษหนักสุด ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2-4 คนละ 3 ปี ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

3.7.4.4 การคุ้มครองเจ้าพนักงานจากความรับผิดอาญาที่เกิดจากการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(1) การคุ้มครองตามหลักกฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

การยกความสุจริตของเจ้าพนักงานเป็นข้อไม่ให้ต้องรับผิดในทางอาญานั้น มักเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานอ้างว่าตนเองมิได้มีเจตนาในการกระทำความผิดเนื่องจากพวกเขาเพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หลักการดังกล่าวเรียกว่าความสำคัญผิดในเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจทำได้ ซึ่งเป็นความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง หรือ Ignorance and mistake of fact โดยเงื่อนไขที่จะนำมาพิจารณามีดังนี้ [189]

1. มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น

2. ผู้กระทำเข้าใจพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอีกพฤติการณ์หนึ่ง ซึ่งเกิดจากจิตสำนึกที่ผิดไป

---

[189]ณรงค์ ใจหาญ, “ความสำคัญผิดในเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจทำได้,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526), น. 23-24.

3. พฤติการณ์ที่ผู้กระทำเข้าใจมีผลเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้กระทำมีอำนาจทำได้

4. ผู้กระทำได้กระทำผิดโดยเข้าใจว่ามีอำนาจกระทำได้

ในการพิจารณาว่าผู้กระทำสำคัญผิดจริงหรือไม่ ต้องพิจารณาจากบุคคลนั้นเอง (Subjective test) เพราะเป็นการพิจารณาภายในจิตใจผู้นั้นว่า เข้าใจตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ดี ถ้าความสำคัญผิดเกิดขึ้นจากความเชื่ออย่างงมงาย ไม่ถือว่าผู้กระทำสำคัญผิด

ทั้งในกฎหมายอังกฤษและสหรัฐอเมริกามีหลักว่า ความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงยกขึ้นแก้ตัวได้ (ignorantia facti excusat) แต่ต้องเป็นความสำคัญผิดที่สุจริตและมีเหตุสมควร (honest and reasonable) เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงทำให้ผู้กระทำไม่มี men rea ความสำคัญผิดในเหตุที่มีอำนาจทำได้เป็นความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่มี men rea เว้นแต่ความสำคัญผิดนั้นเกิดจากความประมาทของผู้กระทำ ผู้กระทำต้องมีความรับผิดฐานประมาทเพราะถือว่าได้กระทำโดยมี men rea

ดังนั้น หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ถือว่าความสำคัญผิดในเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจทำได้ทำให้ผู้กระทำไม่มีเจตนากระทำความผิด (criminal mind) [190]

ในประเทศสหรัฐอเมริกามี Model Penal Code ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่เป็นแบบให้รัฐต่างๆ นำไปใช้บัญญัติในรัฐของตน ได้มีบทบัญญัติเรื่องความสำคัญผิดในมาตรา 2.04[191] โดย (1) (a) มีเงื่อนไขว่า ความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายจะเป็นเหตุยกเว้นโทษ ต้องเป็นความสำคัญผิดที่ทำให้ผู้กระทำไม่มีความประสงค์ต่อผล ส่วนรู้ความเชื่อ

---

[190] *เพิ่งอ้าง*, น. 28-29.

[191] 2.04 Ignorance or Mistake.

(1) Ignorance or mistake as to a matter of fact or law is a defense if:

(a) the ignorance or mistake negatives the purpose, knowledge, belief, recklessness or negligence required to establish a material element of the offense; or

(b) the law provides that the state of mind established by such ignorance or mistake constitutes a defense.

(2) Although ignorance or mistake would otherwise afford a defense to the offense charged, the defense is not available if the defendant would be guilty of another offense had the situation been as he supposed. In such case, however, the ignorance or

(belief) ประมาทโดยรู้ตัว(recklessness) หรือประมาท (negligent) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่กฎหมายต้องการและต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดความผิดอีกอย่างหนึ่งตามที่เข้าใจ[192]

นอกจากนี้ใน (3) (b) ของมาตราดังกล่าวยังได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ความเชื่อว่าการกระทำของตนเป็นไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในทางกฎหมายจะเป็นเหตุให้ผู้กระทำไม่มีความรับผิดต่อเมื่อ บุคคลผู้นั้นกระทำการโดยความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล (reasonable reliance) ต่อเอกสารที่มีผลในทางกฎหมายซึ่งภายหลังถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบกพร่อง โดยเอกสารเหล่านั้นได้แก่ (i) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (ii) ความเห็น คำวินิจฉัย หรือคำพิพากษาของศาล (iii) คำสั่งทางปกครอง (iv) การตีความโดยองค์กรที่มีอำนาจตีความตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจำเลยมีความสุจริต (honest) หรือไม่ หมายความว่าจำเลยจะต้องเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงที่ทำให้มีอำนาจกระทำการจริงๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากตัวจำเลยเอง

---

mistake of the defendant shall reduce the grade and degree of the offense of which he may be convicted to those of the offense of which he would be guilty had the situation been as he supposed.

(3) A belief that conduct does not legally constitute an offense is a defense to a prosecution for that offense based upon such conduct when:

(a) the statute or other enactment defining the offense is not known to the actor and has not been published or otherwise reasonably made available prior to the conduct alleged; or

(b) he acts in reasonable reliance upon an official statement of the law, afterward determined to be invalid or erroneous, contained in (i) a statute or other enactment; (ii) a judicial decision, opinion or judgment; (iii) an administrative order or grant of permission; or (iv) an official interpretation of the public officer or body charged by law with responsibility for t he interpretation, administration or enforcement of the law defining the offense.

(4) The defendant must prove a defense arising under Subsection (3) of this Section by a preponderance of evidence.

[192]ณรงค์ ใจหาญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 189, น. 29.

หรือ Subjective test ส่วนการพิจารณาว่ามีเหตุสมควร (reasonable mistake) หรือไม่ต้องพิจารณาจากมาตรฐานโดยทั่วไปของบุคคล

ดังนั้น ตามหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา หากเจ้าพนักงานสำคัญผิดโดยสุจริตและมีเหตุผลสมควรว่าหมายค้นที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานชอบด้วยกฎหมาย หรือสำคัญผิดโดยสุจริตและมีเหตุผลสมควรว่ามีเหตุที่ให้อำนาจค้นโดยไม่มีหมายค้นเกิดขึ้น เช่น สำคัญผิดว่ามีการกระทำความผิดในที่รโหฐานที่ทำให้มี Exigent Circumstance หรือสำคัญผิดโดยสุจริตและมีเหตุผลสมควรว่ามีเหตุให้ทำการค้นในเวลากลางคืนแล้ว การค้นที่รโหฐานของเจ้าพนักงานนั้นย่อมไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม Title 18 ของ U.S Code หรือความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (Official Misconduct/ Misconduct in Public Office) รวมถึงไม่มีความรับผิดฐานบุกรุก (Trespass of Land)

ทั้งนี้ พบว่าในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานก็ไม่ได้ถูกฟ้องเป็นคดีอาญามากนัก โดยผู้เสียหายจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานซึ่งรวมถึงการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนรายละเอียดที่กฎหมายกำหนดมักเลือกใช้วิธีการฟ้องให้เจ้าพนักงานมีความรับผิดในทางแพ่งมากกว่าการฟ้องให้รับผิดในทางอาญา ด้วยเหตุผลที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

1. หากผู้เสียหายเป็นฝ่ายชนะคดีจะทำให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งในขณะที่การฟ้องในทางอาญานั้น แม้จะมีค่าปรับซึ่งเป็นการลงโทษทางการเงินแก่ผู้กระทำความผิด แต่ผู้เสียหายไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมาตรการดังกล่าว

2. ในการฟ้องคดีแพ่ง ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องให้จำเลยซึ่งแพ้คดีจ่ายค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายให้แก่ตนได้ ซึ่งบางครั้งค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องนี้สูงยิ่งกว่าค่าเสียหายที่โจทก์จะได้รับเสียอีก

3. หลักการพิสูจน์ให้ได้น้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทำให้มีโอกาสชนะคดีสูงกว่าหลักการพิสูจน์จนสิ้นสงสัยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้ว่าเจ้าพนักงานจะสามารถนำหลักเรื่องความสุจริต (Good faith) มาใช้ในการยกเว้นความรับผิดทางแพ่งได้เช่นกันก็ตาม

(2) การคุ้มครองตามหลักกฎหมายไทย

สำหรับกฎหมายไทยนั้น มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับความสุจริตหรือการไม่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงที่ทำให้มีความรับผิดทางอาญาแบ่งเป็นสองกรณีคือ การไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม[193] ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดขาดเจตนาในการกระทำความผิด และการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62[194] ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะนำมาใช้เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดก็เฉพาะในกรณีที่ผู้กระทำมีเจตนากระทำความผิดมาแล้วเท่านั้น กล่าวคือผู้กระทำ (1) รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด (2) ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล ซึ่งเป็นเจตนาตามความเป็นจริงตามมาตรา 59 วรรคสามและวรรคสอง เมื่อผู้กระทำมีเจตนาแล้ว ก็ต้องดูว่าผู้กระทำสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 วรรคแรกหรือไม่[195] โดยในกรณีที่เจ้าพนักงานสำคัญผิดว่าตนมีอำนาจค้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายนี้ เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานมีเจตนากระทำการที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาแล้ว แต่เจ้าพนักงานเชื่อว่าการกระทำของตนไม่เป็นความผิด ซึ่งเป็นกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับการพิจารณาว่าผู้กระทำสามารถอ้างความสำคัญผิดได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาด้วยว่าเจ้าพนักงานที่ทำการค้นสุจริตหรือความสำคัญผิดไม่ได้เกิดจากความผิดของเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ โดยถือเอามาตรฐานของบุคคลที่อยู่ในฐานะเดียวกับผู้กระทำมาเปรียบเทียบ[196]

---

[193]มาตรา 59 วรรคสาม ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้

[194]มาตรา 62 ข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด หรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง แต่ผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลงแล้วแต่กรณี

ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสามแห่งมาตรา 59 หรือความสำคัญผิดว่ามีอยู่จริงตามความในวรรคแรก ได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระทำความผิด ให้ผู้กระทำรับผิดฐานกระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า การกระทำนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษแม้กระทำโดยประมาท

[195]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551), น. 231.

[196]ณรงค์ ใจหาญ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 189*, น. 89.

กล่าวคือจะต้องพิจารณาว่าหากเป็นเจ้าพนักงานคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผู้กระทำความผิดแล้ว เจ้าพนักงานคนอื่นนั้นก็อาจสำคัญผิดเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นการพิจารณาถึงความสำคัญผิดในเหตุที่ทำให้มีอำนาจของเจ้าพนักงาน

คำพิพากษาฎีกาที่ 3865/2542[197] จำเลยเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ท้องที่เกิดเหตุ โดยหน้าที่ราชการจะต้องมีความละเอียด รอบคอบในการพิจารณาคำขอและตรวจสอบที่ดินของผู้ยื่นคำขอเสียก่อน สภาพที่ดินเป็นทุ่งนาไม่มีต้นไม้ ส่วนตอไม้ที่พบนั้นอยู่ในที่ดินที่มีหลักฐานเป็นใบจอง เจ้าของที่ดินก็ไม่เคยยื่นคำขอนำไม้ ถ้าจำเลยตรวจสอบและเรียกเจ้าของที่ดินที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ยื่นคำขอนำไม้มาสอบถามก็จะทราบความจริงว่าคำขอนั้นเป็นเท็จ และจำเลยก็ไม่เคยสอบถามคณะกรรมการการตรวจสอบไม้ว่า ผู้ยื่นคำขอมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยแท้จริงหรือไม่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าพนักงานป่าไม้ทางราชการกรมป่าไม้ กรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย ได้ตรากระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้แล้วนำมาสวมรอยอ้างว่าเป็นไม้ที่เจ้าพนักงานได้ตรวจและอนุญาตให้ตัด การที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้กระทำหรือยอมให้น้องชายจำเลยนำดวงตรา ประทับไม้ประจำตัวจำเลยไปกระทำการตีรอยตราดังกล่าว เป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่จำเลยย่อมเล็งเห็นผลเสียหายของการกระทำนั้น ได้ และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว จำเลยจะอ้างว่ากระทำไปโดยสุจริตหรือกระทำไปโดยความสำคัญผิดหาได้ไม่

[197] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3865/2542 (เนติ 1), น. 2204.

บทที่ 4

วิเคราะห์เปรียบเทียบการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

เมื่อได้ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างหลักกฎหมายในเรื่องการค้นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายอังกฤษแล้ว ในบทนี้จะเป็นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์หลักกฎหมายในแต่ละประเทศกับแนวคิดทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการใช้อำนาจค้นโดยรัฐ โดยเฉพาะการพิจารณาหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่สังคมได้รับจากกระบวนการค้นในที่รโหฐานกับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการค้นที่เหมาะสมและทราบแนวทางในการใช้ดุลยพินิจขององค์กรผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐานตามหลักกฎหมายของทั้งสามประเทศ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ และกฎหมายไทย

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
1. เหตุในการออกหมายค้น	1. เพื่อพบบุคคลที่ต้องการจับหรือถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง		1. เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง หรือเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ (มาตรา 69 (3) และ (4))
	2. เพื่อพบสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐาน /ที่มีไว้เป็นความผิด/ ที่ได้มาจากการกระทำความผิด/ ที่ทำไว้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด	เพื่อพบและยึดสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด Either-way offences และ Indictable only offences ตามมาตรา 8 ของ PACE/ สิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิด/ สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆ	2. เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยาน หลักฐาน/ สิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด/ ได้มาโดยผิดกฎหมาย/ มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด (มาตรา 69 (1) และ (2))

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
2. การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น	1. การค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายต่อบุคคล	1. การค้นสถานที่เพื่อช่วยชีวิต ป้องกันอันตรายต่อกาย หรือป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของบุคคล (มาตรา 17 (e))	1. การค้นเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น (มาตรา 92 (1)) และการค้นเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน (มาตรา 92 (2))
	2. การค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันการหลบหนี 2.1 หลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด (Search in hot pursuit) เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้า/ผู้ต้องหาตามหมายจับ/ ผู้ต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงกับคำให้การของผู้เสียหาย ซึ่งกำลังหลบหนี	2. การค้นสถานที่เพื่อจับกุมบุคคลที่เจ้าพนักงานกำลังไล่ติดตามและได้หลบหนีเข้าไปในสถานที่นั้น (มาตรา 17 (d))	2. เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น (มาตรา 92 (3))

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
	2.2 หลักการไล่ติดตามโดยต่อเนื่อง (Search in fresh pursuit) เจ้าพนักงานได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าผู้ต้องหากำลังจะหลบหนีไปจากสถานที่นั้น 3. การค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานซึ่งเจ้าพนักงานจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนที่จะได้รับหมายค้น	3.การค้นสถานที่ภายหลังการจับกุมในคดีความผิดอาญา indictable offence หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดก่อนที่จะนำตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจหรือก่อนที่จะได้รับการประกันตัว (มาตรา 18)	3. การค้นเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่รโหฐานนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูก

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
			โยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน (มาตรา 92 (4))
		4. การค้นเพื่อจับกุมบุคคลตามมาตรา 17	4. เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 (มาตรา 92 (5))
	4. การค้นในขณะจับกุม (Search incident to arrest) ซึ่งจะกระทำได้เพียงบริเวณที่อยู่ในความควบคุมของผู้ถูกจับกุม กล่าวคือ บริเวณที่ผู้ต้องหาสามารถเอื้อมไปถึงหรืออาจไปถึงได้ในขณะที่จะถูกจับกุม	5. การตรวจค้นสถานที่เพื่อหาพยานหลักฐานในขณะจับกุมในความผิดอาญาร้ายแรงในสถานที่ที่บุคคลนั้นอยู่ในขณะถูกจับกุม หรือเพิ่งเข้าไปในทันทีทันใดก่อนถูกจับกุม (มาตรา 32)	มาตรา 85 กำหนดเพียงการค้น “ตัวบุคคล” ภายหลังการจับกุม

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
3. มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการออกหมายค้นและการค้นโดยไม่มีหมาย	หลักเหตุที่เป็นไปได้ หรือ probable cause ยกเว้นการค้นในขณะจับกุม (Search incident to arrest) ซึ่งค้นได้เสมอโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุอันเป็นไปได้	1. หลักเหตุอันควรเชื่อ หรือ reasonable grounds for believing สำหรับการออกหมายค้น และการค้นโดยไม่มีหมายเพื่อจับกุมบุคคลตามมาตรา 17, มาตรา 32 2. หลักเหตุอันควรสงสัย หรือ reasonable grounds for suspect สำหรับการค้นสถานที่ภายหลังการจับกุมตามมาตรา 18	1. มีพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้น 2. มี “เหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัย” ว่าบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น ตามมาตรา 92 (3) 3. มี “พยานหลักฐานตามสมควร” ว่ามีสิ่งของอยู่ในสถานที่นั้น ประกอบกับมี “เหตุอันควรเชื่อ” ว่าสิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน ตามมาตรา 92 (4)
4. ช่วงเวลาที่ทำการค้น	หลัก : การค้นต้องกระทำในเวลากลางวัน หรือ Day time กล่าวคือ ช่วงเวลาตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 22:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (Rule 41)	หลัก : การค้นต้องกระทำในช่วงเวลาอันเหมาะสม หรือ reasonable hour (มาตรา 16 (4))	หลัก : การค้นต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก (มาตรา 96)

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
	ข้อยกเว้น : การค้นสามารถกระทำในเวลาอื่นได้ เมื่อค้นต่อเนื่องจากตอนกลางวัน /เพื่อป้องกันการหลบหนี/ ป้องกันการโยกย้ายพยานหลักฐาน / ป้องกันอันตรายแก่เจ้าพนักงานผู้ทำการค้นหรือผู้อื่น	ข้อยกเว้น : การค้นสามารถกระทำในเวลาที่ไม่ใช่ reasonable hour ได้ หากการไม่ลงมือค้นในทันทีจะทำให้การค้นนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการค้น	ข้อยกเว้น : 1. เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 2. ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง 3. การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญซึ่งต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาล (มาตรา 96 (1)-(3))
5. การแสดงตนในการค้น	หลัก “Knock and Announce Rule” เจ้าพนักงานอาจใช้กำลังบังคับเข้าไปในเคหสถานเพื่อทำการค้นได้ เมื่อได้แจ้งถึงอำนาจทำการค้นและวัตถุประสงค์ของการค้นแล้ว ไม่ได้รับความยินยอมให้เข้าไปในเคหสถานนั้น	ก่อนที่จะเริ่มทำการค้น เจ้าหน้าที่จะต้องแสดงชื่อและสถานีตำรวจที่ประจำอยู่ วัตถุที่ต้องการค้นหา และเหตุผลในการตรวจค้นแก่ผู้ที่จะถูกตรวจค้น (มาตรา 2)	ให้พนักงานแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่ง (มาตรา 94) เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามีคำขอร้องให้ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดู (มาตรา 62)

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
	ข้อยกเว้น : 1. การแสดงตนจะก่อให้เกิดอันตราย 2. การแสดงตนไม่มีความจำเป็น เนื่องจากผู้ครอบครองสถานที่นั้นทราบอยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานมาด้วยเหตุใด 3. การแสดงตนจะทำให้มีการทำลายพยาน หลักฐานหรือมีการหลบหนี		ถ้าบุคคลดั่งกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไป ในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้ (มาตรา 94 วรรคสอง)
6. ขอบเขตในการค้นที่รโหฐาน	หลัก : การค้นต้องจำกัดเฉพาะเพื่อหาบุคคลหรือสิ่งของตามหมายค้น หรือบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นเหตุค้นโดยไม่มีหมายค้น การขยายอำนาจค้นและยึด ทำได้ตามหลักพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง หรือ Plain view doctrine ซึ่งมีเงื่อนไข	หลัก : การค้นต้องจำกัดเฉพาะเพื่อหาบุคคลหรือสิ่งของตามหมายค้น หรือบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นเหตุค้นโดยไม่มีหมายค้น หากเจ้าพนักงานเข้าไปในที่รโหฐานโดยชอบด้วยกฎหมายและพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	หลัก : การค้นในที่รโหฐานจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้น (มาตรา 98) ข้อยกเว้น : 1. ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้คนมีอำนาจ

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
	ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานอยู่ในตำแหน่งที่สามารถพบสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful discovery) 2. เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นของที่ถูกขโมย หรือเป็นพยาน หลักฐานในการกระทำความผิดนั้นหรือความผิดอื่น 3. เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful access)	โดยบังเอิญ เจ้าพนักงานสามารถยึดสิ่งนั้นได้โดยอาศัยมาตรา 19 เมื่อ 1. เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของดังกล่าวได้มาโดยผลของการกระทำความผิด/ เป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 2. จำเป็นเพื่อป้องกันสิ่งของนั้นจากการสูญหาย ถูกปกปิด ทำให้เสียหาย ถูกโยกย้าย หรือถูกทำลาย	ยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย (มาตรา 98 (1)) 2. เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า (มาตรา 98 (2))

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
7. ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 7.1 ผลต่อการรับฟังพยานหลักฐาน	หลัก : การค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานตามหลัก Exclusionary Rule ได้แก่ การค้นโดยไม่มีหมายค้น/ การค้นโดยไม่มีเหตุอันเป็นไปได้/ การค้นตามหมายค้นที่บกพร่อง/ การค้นเกินขอบเขตที่หมายกำหนดหรือเกินขอบเขตที่จะค้นได้โดยไม่มีหมาย/ การค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจ ข้อยกเว้น : หลักความสุจริต (Good faith) ทำให้พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถรับฟังได้ หากเจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริตในผล	หลัก : พยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายรับฟังได้ หากพยานหลักฐานนั้นมีคุณค่าในการพิสูจน์ความผิด ข้อยกเว้น : หากคำนึงถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้งพฤติการณ์ที่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นแล้ว การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะก่อให้เกิดผล	หลัก : การค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยาน หลักฐาน (พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบ ตามมาตรา 226/1 วรรคหนึ่ง) ได้แก่ การค้นโดยไม่มีหมายค้นหรือไม่มีเหตุให้ค้นโดยไม่มีหมาย/ การค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจ ข้อยกเว้น : ศาลใช้ดุลยพินิจรับฟังได้เมื่อคำนึงถึง 1. คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำคัญและความน่าเชื่อถือของพยาน

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
	ของหมายค้นที่มีความบกพร่องซึ่งออกโดยศาล	เสียหายต่อความเป็นธรรมของกระบวนการพิจารณาคดี ศาลอาจใช้ดุลยพินิจไม่รับฟังพยานหลักฐานได้ ซึ่งได้แก่ การที่เจ้าพนักงานใช้วิธีการขู่เข็ญ หลอกลวง ทำให้พยาน หลักฐานเกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ศาลจึงคำนึงถึงว่าเจ้าพนักงานมีความทุจริตหรือไม่เป็นสำคัญ	หลักฐานนั้น/ 2. พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี/ 3. ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ/ 4. ผู้ที่กระทำการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ กรณีที่เจ้าพนักงานมีความสุจริตในการใช้อำนาจค้นถือเป็นกรณีตาม 3.(มาตรา 226/1 วรรคสอง (1)-(4))
7.2 ผลต่อความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงาน	เจ้าพนักงานอาจมีความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฐานบุกรุก ฐานทำให้เสียทรัพย์ หรือความผิดเฉพาะเกี่ยวกับการใช้อำนาจค้น แต่สามารถอ้างความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ทำให้ขาดเจตนาในการ	เจ้าพนักงานอาจมีความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (Misconduct) ฐานบุกรุก ฐานทำให้เสียทรัพย์	เจ้าพนักงานอาจมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364 ฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 157 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358

หลักเกณฑ์ในการค้นที่รโหฐาน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศไทย
	กระทำความผิด		แต่อาจอ้างความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 ได้

4.1 วิเคราะห์รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดกระบวนการใช้อำนาจรัฐในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแก่ประชาชนแล้ว จะเห็นได้ว่า แม้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะได้สร้างหลักเกณฑ์ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการใช้อำนาจค้นที่รโหฐานไว้เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ กล่าวคือ

1. มีบทบัญญัติที่เป็นการกำหนดให้กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานต้องมีองค์กรศาลที่มีความเป็นกลางในการออกหมายค้นและหมายจับ

2. การใช้ดุลยพินิจในการจับและค้นโดยไม่มีหมายจากศาลต้องกระทำภายในขอบเขตที่จำกัดตามมาตรา 78 (1)-(4) และมาตรา 92 (1) – (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3. พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ จะรับฟังมิได้ เว้นแต่ศาลเห็นว่า มีข้อเท็จจริงที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 226/1 จะใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ได้สร้างหลักเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น มีกระบวนการต่างๆ ที่ผ่อนคลายเพื่อให้ศาลและเจ้าพนักงานสามารถจับกุมบุคคลหรือแสวงหาพยานหลักฐานได้รวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการกระทำซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถึงขนาดทำให้การกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติงานโดยไม่มีอำนาจแล้ว จำเลยสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้เสมอ ข้อแตกต่างดังที่กล่าวนี้อาจเห็นได้จากมาตรา 98 ที่บัญญัติว่า “การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้ (1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้คนมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย...” ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษนั้นมีหลักการสำคัญว่าหมายค้นจะต้องระบุเจาะจงสถานที่ที่จะทำการค้น และสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการจะค้นโดยเคร่งครัด จึงไม่อาจระบุแต่เพียงว่าให้มีอำนาจค้นหาสิ่งของและพยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นๆ ได้

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็พบด้วยว่า ในทางพิจารณาของศาลไทยนั้น ศาลมักจะคำนึงถึงผลในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษยิ่งกว่าการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 6391/2547[1] วินิจฉัยว่า สำหรับข้อที่จำเลยที่ 1 อ้างต่อไปว่าเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 1 โดยไม่มีหมายค้น จึงไม่น่ารับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้น เห็นว่า ในปัญหานี้ จำเลยที่ 1 รับอยู่แล้วว่าของกลางถูกยึดจากบ้านจำเลยที่ 1 ตามบันทึกการตรวจค้นเอกสารหมาย จ. 7 ก็ปรากฏมีลายมือชื่อผู้ครอบครองบ้านลงรับรองไว้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยมิได้มีการบังคับขู่เข็ญ ร้อยตำรวจเอกยุทธยา พิชัยพยานโจทก์ก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยที่ 1 แล้วว่า เหตุที่ไปตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ซักทอดว่าลักเอาทรัพย์ไปขายให้แก่จำเลยที่ 1 การไปตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่การกลั่นแกล้ง ส่วนการตรวจค้นจะมิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่ง

คำพิพากษาฎีกาที่ 5144/2548[2] วินิจฉัยว่า การตรวจค้นอาจมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก หามีผลทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจที่ชอบเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยไม่

ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้มาตรา 226 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะบัญญัติไว้ว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน” บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่าหากพยานหลักฐานได้มาจากการกระทำโดยมิชอบของเจ้าพนักงานแล้ว โดยหลักห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานนั้น แต่ศาลก็ได้วินิจฉัยให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยไม่มีหมายได้ เนื่องจากพยานหลักฐานนั้นสามารถใช้พิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ และไม่ได้เป็นกรณีที่ได้มาจากการข่มขู่ซึ่งเป็นหลักการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายอังกฤษ ที่บัญญัติให้

---

[1]คำพิพากษาฎีกาที่ 6391/2547 (ฎส. 9), น. 70.

[2]คำพิพากษาฎีกาที่ 5144/2548 (ฎส. 10), น. 129.

ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้เสมอ เว้นแต่กรณีที่ถือว่าเป็นการทำให้จำเลยไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างมากในการพิจารณาคดี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 78 ของ PACE

นอกจากนี้ ในกระบวนการออกหมายค้นหรือหมายจับโดยศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59/1[3] ได้ให้อำนาจศาลพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายจับตามมาตรา 66 หมายค้นตามมาตรา 69 หรือหมายขังตามมาตรา 71 โดยให้หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไม่ได้กำหนดกระบวนการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้านการออกหมายค้นในกรณีที่มีความไม่สมบูรณ์ปรากฏอย่างชัดแจ้ง หรือกรณีที่ข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขในการออกหมายไม่เพียงพอ ซึ่งตามหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษเป็นสิทธิของผู้ที่จะถูกค้นที่รโหฐานหรือจำเลยที่จะกระทำได้ โดยตามกฎหมายไทยนั้น จำเลยจะต้องยกเป็นข้อต่อสู้เมื่อมีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ดังคำพิพากษาฎีกาที่ 270/2543[4] ที่วินิจฉัยว่า การร้องขอให้ไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายค้นเพื่อทราบสาเหตุและหลักฐานอันเป็นที่มาในการขอออกหมายค้นของศาลภายหลังจากที่ได้มีการออกหมายค้นไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่การป้องกันการตรวจค้นโดยปราศจากเหตุผลสมควรตามกฎหมายเพราะการตรวจค้นยุติไปแล้ว ทั้งนี้ จำเลยจะต้องยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับความชอบของหมายค้นได้เมื่อมีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลแล้วเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏคำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยเกี่ยวกับผลของการค้นในกรณีดังกล่าวไว้

ดังนั้น จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและแนวปฏิบัติของศาลไทย ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีแนวโน้มไปในทางทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model) มากกว่าทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due Process Model) ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดียิ่งขึ้นโดยการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

---

[3]มาตรา 59/1 ก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายตามมาตรา 66 หมายค้นตามมาตรา 69 หรือหมายขังตามมาตรา 71

คำสั่งศาลให้ออกหมายหรือยกคำร้อง จะต้องระบุเหตุผลของคำสั่งนั้นด้วย

หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ การพิจารณา รวมทั้งการออกคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

[4]คำพิพากษาฎีกาที่ 270/2543 (ฎส. 1), น. 103.

ความอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินกระบวนพิจารณาความอาญาที่เป็นสากล เช่น พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขให้องค์กรศาลเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจออกหมายจับและหมายค้น แทนการกำหนดให้เจ้าพนักงานหรือศาลเป็นผู้มีอำนาจออกหมายจับ หมายค้นหรือหมายขัง และยกเลิกการกำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ค้นที่รโหฐานด้วยตนเองไม่ต้องมีหมายค้น ซึ่งทำให้เจ้าพนักงานมักหลีกเลี่ยงการออกหมายค้นที่ต้องระบุรายละเอียดยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าการนำแนวทางเกี่ยวกับการค้นที่รโหฐานในต่างประเทศในบางกรณีมาปรับใช้กับการค้นที่รโหฐานของไทยจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยที่ไม่เป็นภาระแก่เจ้าพนักงานหรือทำให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจนเกินควร ดังที่จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อๆ ไป

4.2 ความหมายและขอบเขตของคำว่า “การค้นในที่รโหฐาน”

จากการศึกษาหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการค้นเริ่มต้นจากการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีอยู่เหนือเคหสถานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และความคุ้มครองนี้ยังขยายไปถึงพื้นที่อื่นๆ ที่บุคคลมีเจตนาหวงกันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น โกดังเก็บสินค้า สิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า สถานที่ที่บุคคลมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว และในประเทศอังกฤษ ปรากฏในมาตรา 8 ของ The Police and Criminal Evidence Act 1984 หรือ PACE ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการออกหมายค้นเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานในการเข้าไป และค้นสถานที่ของบุคคล (Power of the justice of peace to authorize entry and search of “premises”)

อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่บุคคลมีเจตนาหวงกันนั้นอาจรวมถึงยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วย แต่เนื่องจากการใช้ประโยชน์ยานพาหนะเหล่านั้นเป็นไปเพื่อการขนส่งสิ่งของและการสัญจรไปมาเป็นสำคัญ ลักษณะการใช้งานยานพาหนะจึงเป็นการใช้งานในที่สาธารณะซึ่งต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจราจรอยู่แล้ว นักกฎหมายในต่างประเทศจึงมีความเห็นว่าความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่มีอยู่เหนือยานพาหนะมีลักษณะที่มีข้อจำกัดแตกต่างจากความเป็นส่วนตัวเหนือสถานที่โดยทั่วไป ประกอบกับความสามารถของยานพาหนะในการที่จะพาเอาสิ่งของผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานหนีไปได้โดยง่าย ดังนั้นทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษจึงได้สร้างหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อยกเว้นสำหรับการตรวจ

ค้นยานพาหนะในที่สาธารณสถานให้มีความยืดหยุ่น โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจค้นยานพาหนะเหล่านั้นได้โดยไม่มีหมายค้นภายใต้ข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ การเรียกให้รถหยุดเพื่อตรวจค้นตามคำพิพากษาในคดี Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) การค้นยานพาหนะตามคำพิพากษาในคดี Carroll v. United States, (1925) 267 U.S. 132 และการค้นยานพาหนะตามมาตรา 1 ของ PACE ซึ่งเจ้าพนักงานจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในยานพาหนะนั้น

ทั้งนี้ หากยานพาหนะที่จะทำการค้นไม่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้ว การค้นก็จะต้องกระทำโดยมีหมายค้นที่ออกโดยศาล ดังที่กำหนดในมาตรา 8 ของ PACE อันเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการเข้าไปและการค้นสถานที่โดยอาศัยอำนาจของหมายค้น (Power of justice of the peace to authorise entry and search of premises) ซึ่งคำว่า premise นี้ ตามบทนิยามในมาตรา 23 หมายถึงสถานที่ใดๆ (places) และรวมถึงยานพาหนะต่างๆ (any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft) ด้วย

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การบัญญัติความว่า “ที่รโหฐาน” ของมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มีความใกล้เคียงกับมาตรา 8 ของ PACE ที่บัญญัติถึงการค้นสถานที่ (premise) ไว้กว้างๆ โดยรวมถึงยานพาหนะด้วย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความหมายของ “ที่รโหฐาน” ตามมาตรา 92 จะต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 93 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่นเดียวกับที่จะต้องพิจารณามาตรา 1 ของ PACE ก่อนการพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ในการค้นสถานที่ตามมาตรา 8 กล่าวคือ หากเป็นการค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่ใช้ในการสัญจรไปมาในที่สาธารณะแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นที่ “รโหฐาน” ตามมาตรา 92 และสามารถทำการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 93 กล่าวคือ เมื่อ “มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด” แต่หากไม่เข้าเหตุที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 93 เช่น รถยนต์นั้นจอดอยู่ในที่รโหฐาน เช่น จอดในบ้าน จอดในโกดัง ในที่ดินที่มีรั้วรอบขอบชิดแสดงถึงเจตนาหวงกัน หรือเป็นกรณีที่รถยนต์วิ่งหรือจอดอยู่ในที่สาธารณะ แต่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพยานหลักฐานในการกระทำความผิดในรถคันดังกล่าว ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขตามมาตรา 93 ข้างต้นแล้ว เจ้าพนักงานก็จะต้องมีหมายค้นในการตรวจค้นหรือมีเหตุที่ทำให้ค้นได้โดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า แม้ข้อเท็จจริงจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทำให้มีอำนาจค้นยานพาหนะตามมาตรา 93 แต่โดยลักษณะของยานพาหนะที่สามารถพาพยานหลักฐานหนีไปได้โดยง่ายนั้น เจ้าพนักงานจึงอาจอาศัยเหตุ

ตามมาตรา 92 (4) ว่า “มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น” และ “มีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้าย" เพื่อค้นยานพาหนะโดยไม่มีหมายค้นได้

4.3 เหตุในการออกหมายค้นที่รโหฐาน

เหตุในการออกหมายค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทยบัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปอยู่ในมาตรา 69 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจำแนกเหตุที่จะออกหมายค้นได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ (1) เพื่อพบและยึดสิ่งของ และ (2) เพื่อพบบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับเหตุในการออกหมายค้นของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ โดยการค้นเพื่อยึดสิ่งของนั้น มาตรา 69 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ให้อำนาจยึดสิ่งของได้กว้างขวางโดยแบ่งออกเป็น

ก. สิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา

ข. สิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด

ค. สิ่งของที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย

ง. สิ่งของที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด

ซึ่งประเภทของสิ่งของที่เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นและยึดตาม ก.- ง. นี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนความผิดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาฐานต่างๆ นอกจากนี้การค้นสิ่งของตาม ค. ย่อมเป็นประโยชน์ในการเยียวยาผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์ที่แท้จริง ในขณะที่การค้นสิ่งของตาม ง. เป็นการป้องกันการกระทำความผิดที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับเหตุในการออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษ

สำหรับการออกหมายค้นเพื่อพบบุคคลนั้น กฎหมายไทยกำหนดเหตุในการออกหมายค้นในกรณีดังกล่าวไว้ 2 เหตุ คือ เพื่อพบบุคคลที่มีหมายให้จับและเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับที่กำหนดใน Rule 41 (c) (4) ของ Title 18 Criminal Procedure อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตาม PACE ของประเทศอังกฤษจะไม่ได้ระบุกรณีที่ให้อำนาจศาลในการออกหมายค้นเพื่อจับกุมบุคคลไว้ แต่เนื่องจาก ในระบบกฎหมายอังกฤษมองว่ากระบวนการค้นเพื่อจับกุมบุคคลเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากความจำเป็นที่

จะต้องมีการจับกุมบุคคลมาลงโทษ ดังนั้น หากเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานมีอำนาจจับกุมได้แล้ว มาตรา 17 ของ PACE จึงระบุให้การค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นสามารถกระทำได้เพื่อ

(1) บังคับให้เป็นไปตามหมายจับ หรือ

(2) เพื่อจับกุมบุคคลที่กระทำความผิด indictable offence หรือความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นที่บัญญัติให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ ตามที่ระบุในมาตรา 24 กรณีอำนาจจับโดยไม่มีหมายของเจ้าพนักงานและมาตรา 24 A กรณีอำนาจจับโดยไม่มีหมายของราษฎร

อย่างไรก็ตาม กรณีที่แตกต่างกับประเทศไทยก็คือ การหลีกเลี่ยงการค้นเพื่อหาพยานหลักฐานและจับกุมบุคคลในความผิดเล็กน้อยซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐกระทบสิทธิของบุคคลโดยไม่จำเป็น ซึ่งทำให้ประเทศอังกฤษกำหนดห้ามไว้โดยชัดเจนในมาตรา 8 ของ PACE และมาตรา 1 ของ Magistrates' Courts Act 1980 ว่าศาลจะออกหมายค้นหรือหมายจับเพื่อการแสวงหาพยานหลักฐานหรือเพื่อจับกุมบุคคลในคดีที่ไม่ใช่การกระทำความผิดอาญาร้ายแรงประเภท indictable offence ที่หมายความถึงความผิด Indictable only offence และ Either way offence ไม่ได้ ซึ่งหากเจ้าพนักงานประสงค์ที่จะค้นหาพยานหลักฐานหรือนำตัวผู้กระทำความผิดอาญาในความผิดเล็กน้อย (Summary offence) มาเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดแล้ว จะต้องมีคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีหมายเรียกที่เรียกว่า summons เท่านั้น จะออกหมายค้นเพื่อหาสิ่งของหรือเพื่อจับกุมบุคคลนั้นมิได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกจึงจะสามารถออกหมายค้นและหมายจับต่อไป โดยหมายเรียกดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับหมายเรียกตามมาตรา 52[5] ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และศาลออกหมายเรียกผู้ต้องหา พยาน หรือบุคคลใดมาให้การหรือส่งมอบพยานหลักฐานซึ่งผู้ขัดขืนหมายเรียกย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

อย่างไรก็ตาม โดยที่การกำหนดให้ศาลหรือเจ้าพนักงานมีหมายเรียกตามมาตรา 52

---

[5]มาตรา 52 การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาล แล้วแต่กรณี

แต่ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปทำการสอบสวนด้วยตนเอง ย่อมมีอำนาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก

ไม่ได้เป็นบทบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้บังคับมาตรการดังกล่าวก่อน ในขณะที่การมีหมายเรียกเป็นการที่รัฐเลือกใช้มาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานหรือผู้กระทำความผิดโดยวิธีการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้อยกว่าตามหลักความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ หรือ Principle of Necessity ซึ่งจะเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลจากการใช้อำนาจรัฐบังคับเข้าค้นที่รโหฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในเคหสถาน และสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลในทันทีโดยบุคคลดังกล่าวไม่มีโอกาสโต้แย้งหรือมีเวลาเตรียมตัว ตลอดจนการมีหมายเรียกย่อมเป็นการให้โอกาสแก่ผู้บริสุทธิ์ที่จะไปให้การด้วยความสมัครใจ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอว่าอาจกำหนดเป็นแนวทางให้ศาลและเจ้าพนักงานยึดถือว่า การออกหมายค้นเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดที่มิใช่ความผิดร้ายแรงจะกระทำมิได้ เพื่อให้ต้องมีการออกหมายเรียกในคดีความผิดเล็กน้อยก่อนเสมอเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ

4.4 เหตุในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

อำนาจค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นนอกเหนือจากการค้นโดยความยินยอมแล้ว ตามมาตรา 92 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดเหตุซึ่งเป็นที่มาของอำนาจไว้ 5 ประการ ได้แก่

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นทำได้โดยชอบ

ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับเหตุในการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาตามหลักการค้นฉุกเฉิน (Exigent circumstance search) ที่ประกอบด้วย

(1) การค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลในที่รโหฐาน

(2) การค้นฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวน ได้แก่

(2.1) ค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐาน

(2.2) ค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันผู้กระทำความผิดหลบหนี ซึ่งแบ่งออกเป็น หลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด (Search in hot pursuit) และหลักการไล่ติดตามโดยต่อเนื่อง (Search in fresh pursuit)

ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะพื้นฐานของเหตุที่ให้อำนาจค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นในประเทศไทย อนุมาตรา 1 ถึง อนุมาตรา 4 ของมาตรา 92 มีความใกล้เคียงกับหลักการค้นฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา (Exigent circumstance search) อย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การค้นที่รโหฐานในประเทศอังกฤษหลายกรณีก็มีความใกล้เคียงกับการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทยและมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่น่าสนใจ โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) อนุมาตรา 1

การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น เป็นการค้นที่รโหฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือมิให้บุคคลได้รับภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของเขา และเมื่อการช่วยเหลือบุคคลผู้นั้นเป็นการช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากเหตุร้ายซึ่งเป็นการกระทำโดยละเมิดต่อกฎหมาย การค้นที่รโหฐานนั้นจึงวัตถุประสงค์ในทางอ้อมเป็นการจับกุมบุคคลซึ่งเป็นที่มาของเหตุร้ายนั้นด้วย เช่นเดียวกับการค้นฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายต่อบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และการค้นที่รโหฐานเพื่อช่วยชีวิต ป้องกันอันตรายต่อกาย หรือป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของบุคคลตามหลักกฎหมายอังกฤษซึ่งได้รับการบัญญัติรองรับไว้ในมาตรา 17 ของ PACE

(2) อนุมาตรา 2

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (2) ได้บัญญัติให้การค้นที่รโหฐานกระทำได้เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐานนั้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษไม่พบว่ามีกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานเป็นข้อยกเว้นหลักการค้นที่รโหฐานต้องมีหมาย หากแต่เป็นข้อยกเว้นของหลักการจับต้องเป็นไปตามหมายจับ (in the presence of)ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า เนื่องจากการกระทำความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานอยู่ในความหมายของหลักการค้นโดย

ฉุกเฉินเพื่อป้องกันภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกาและการค้นเพื่อช่วยชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษและตามมาตรา 17 ของ PACE ซึ่งเป็นเรื่องที่การกระทำความผิดกำลังเกิดขึ้นในที่รโหฐานเช่นเดียวกับหลักความผิดซึ่งหน้าเกิดในที่รโหฐานตามอนุมาตรา 2 จึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปในเคหสถานเพื่อ (1) ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เป็นผู้เสียหายในการกระทำความผิดซึ่งหน้า และ (2) จับกุมบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านั้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อแตกต่างในกรณีที่เจ้าพนักงานพบเห็นสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายจากภายนอกที่รโหฐาน ซึ่งตามคำพิพากษาศาลสหรัฐวางหลักว่าแม้จะเห็นสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ต้นกัญชา อยู่ภายในบริเวณบ้าน หากเจ้าพนักงานไม่มีอำนาจค้นฉุกเฉินที่จะอ้างได้ย่อมไม่มีอำนาจเข้าไปเพื่อยึดสิ่งนั้น และเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมีสิ่งของในครอบครองเป็นความผิดนี้ไม่มีผู้เสียหายที่จะทำให้มีเหตุฉุกเฉินในการค้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลอื่น การเข้าไปค้นที่รโหฐานในกรณีดังกล่าวจึงต้องปรากฏว่าเจ้าพนักงานมีเหตุอันเป็นไปได้ว่าจะมีการทำลายพยานหลักฐานนั้น แต่ตามคำพิพากษาของศาลไทยในฎีกาที่ 1164/2546[6] ระบุว่า “ก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะดำเนินการค้นนั้นได้เห็นจำเลยซึ่งอยู่ในห้องนอน โยนสิ่งของออกไปนอกหน้าต่าง เมื่อไปตรวจสอบดูก็พบเมทแอมเฟตามีนอันเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจพบจำเลยกำลังกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดซึ่งหน้า และได้กระทำลงในที่รโหฐานเจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78(1) และมาตรา 92 (2)” ซึ่งจะเห็นได้ว่าศาลไทยวินิจฉัยเพียงว่ามีความผิดซึ่งหน้าซึ่งเป็นเหตุให้มีอำนาจค้นโดยไม่มีหมายตามอนุมาตรา 2 เกิดขึ้นหรือไม่เท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาถึงเหตุฉุกเฉินที่พยานหลักฐานกำลังจะถูกทำลาย หรือความฉุกเฉินที่ผู้กระทำความผิดซึ่งหน้ากำลังจะหลบหนี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าแม้มาตรา 92 (2) จะไม่ได้บัญญัติถึงเรื่องความฉุกเฉินไว้ แต่ศาลก็ควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในลักษณะเดียวกับแนวคำพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

(3) อนุมาตรา 3

หลักการค้นตามมาตรา 92 (3) มีความใกล้เคียงกับหลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด (Search in hot pursuit) ที่อำนาจในการค้นสถานที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานพยายามที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัยในที่สาธารณะแต่ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยนั้นได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านของตนหรือ

---

[6]คำพิพากษาฎีกาที่ 1164/2546 (เน. 10), น. 1862.

สถานที่ของบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม การค้นตามหลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิดนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้าที่กำลังหลบหนีเช่นที่กำหนดไว้ในมาตรา 92 (3) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไล่ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับตลอดจนการไล่ติดตามผู้ต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงกับคำให้การของผู้เสียหายด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ตามหลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิดมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากกว่า เนื่องจากทั้งผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและผู้ถูกออกหมายจับต่างเป็นบุคคลที่เจ้าพนักงานเข้าใจได้ประจักษ์แจ้งว่าเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญาที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่จับกุม อีกทั้งการกำหนดให้เจ้าพนักงานไล่จับผู้กระทำความผิดได้เฉพาะในกรณีผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าเท่ากับเป็นการชี้ช่องให้ผู้ถูกออกหมายจับเลือกที่จะหลบหนีโดยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ของบุคคลอื่น เนื่องจากอนุมาตรา 5 ของมาตรา 92 ระบุว่า การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเพื่อจับกุมบุคคลตามหมายกระทำได้ต่อเมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน

ทั้งนี้ การให้อำนาจไล่ติดตามบุคคลเข้าไปในที่รโหฐานนี้ยังสอดคล้องกับมาตรา 17 ของ PACE ที่กำหนดให้เจ้าพนักงานสามารถค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมบุคคลที่กระทำความผิดอาญาซึ่งเจ้าพนักงานกำลังไล่ติดตามและได้หลบหนีเข้าไปในสถานที่นั้นได้โดยไม่จำกัดว่าบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า สมควรกำหนดให้เจ้าพนักงานสามารถไล่ติดตามจับกุมบุคคลจากที่สาธารณะเข้าไปในที่รโหฐานได้ทั้งในกรณีที่บุคคลที่ถูกไล่จับเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและเป็นผู้ถูกออกหมายจับ

(4) อนุมาตรา 4

อนุมาตรานี้เป็นการกำหนดให้อำนาจค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ กล่าวคือ

ก. มีพยานหลักฐานตามสมควรว่า สิ่งของ (ได้แก่ สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิด) ได้ซ่อนหรืออยู่ในมี่รโหฐานนั้น

ข. มีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

จะเห็นได้ว่ามีเพียงอนุมาตรา 4 นี้เท่านั้น ที่มีการใช้ถ้อยคำว่า “มีพยานหลักฐานตามสมควร” และคำว่า “มีเหตุอันควรเชื่อ” เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการค้นในกรณีนี้เป็นการป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นในที่รโหฐานโดยไม่มีพฤติการณ์ที่

ชัดเจนซึ่งทำให้เจ้าพนักงานรู้ว่าเหตุที่ทำให้มีอำนาจค้นได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ จึงแตกต่างจากกรณีตามอนุมาตรา 1 ที่มักจะมีเสียงให้ได้ยิน เช่น เสียงร้องให้ช่วยหรือเสียงปืน หรือกรณีการตามจับบุคคลตามอนุมาตรา 3 ที่เจ้าพนักงานเห็นอยู่ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า การใช้อำนาจตามอนุมาตรา 4 นี้ จึงมีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ซึ่งเพียงแต่การกำหนดให้ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” ย่อมไม่เพียงพอที่จะเป็นการปกป้องคุ้มครองบุคคลจากการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตาม The Police and Criminal Evidence Act 1984 หรือ PACE อันเป็นกฎหมายหลักว่าด้วยการแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานในประเทศอังกฤษก็ไม่ปรากฏบทบัญญัติที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานทำการค้นโดยไม่มีหมายค้นในสถานที่ของบุคคลภายนอกเพียงเพราะเหตุว่าเจ้าพนักงานเชื่อว่ากำลังจะมีการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานก่อนที่จะขอหมายค้นจากศาลได้

ดังนั้น ด้วยสภาพของการใช้อำนาจค้นเพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานที่เป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจได้กว้างขวางนี้เอง ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้สร้างแนวคำพิพากษาเพื่อกำหนดกรอบในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานให้มีความเคร่งครัด ดังนี้

1. การใช้อำนาจค้นสถานที่ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานในความผิดที่ร้ายแรงซึ่งได้สัดส่วนกับการใช้มาตรการค้นโดยไม่มีหมาย กล่าวคือ การค้นฉุกเฉินในความผิดเล็กน้อย โดยเฉพาะความผิดที่ไม่มีโทษจำคุก จะกระทำมิได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวทางในการจำกัดดุลยพินิจของเจ้าพนักงานในกรณีนี้มีที่มาจากหลักความได้สัดส่วนในการใช้อำนาจรัฐนั่นเอง

2. เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนที่จะได้รับหมายค้น ทั้งนี้ เหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการทำลายพยานหลักฐานจะยังไม่เกิดขึ้นหากบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นมิได้ล่วงรู้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจพบการกระทำความผิดของเขาแล้ว

3. ความฉุกเฉินเนื่องจากกำลังจะมีการโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานนี้จะต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานเอง

(5) อนุมาตรา 5

ตามอนุมาตรา 5 ของมาตรา 92 ระบุว่า “การค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดโดยไม่มีหมายค้นได้เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78” จึงต่างจากการเข้าค้นสถานที่เพื่อจับกุมบุคคลในประเทศอังกฤษตามมาตรา 17 ของ PACE ซึ่งไม่จำกัดว่าที่รโหฐานที่จะค้นเพื่อจับกุมนั้น ผู้ถูกจับจะเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ โดยผู้เขียนเห็นว่าการให้อำนาจเจ้าพนักงานทำการค้นที่รโหฐานของบุคคลภายนอกเพื่อจับกุมบุคคลนี้มีเหตุผลในทำนองเดียวกับการค้นที่รโหฐานที่ผู้ต้องหาเพิ่งเข้าไปในทันทีทันใดก่อนถูกจับกุมตามแนวคำพิพากษาในคดี Ghani v. Jones ที่แม้ว่าการค้นที่รโหฐานจะกระทบต่อสิทธิในเคหสถานของบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ที่จะถูกจับในความผิดนั้นๆ แต่เมื่อมีเหตุที่ทำให้เชื่อว่ามีการกระทำความผิดถึงขั้นที่เจ้าพนักงานหรือราษฎรมีอำนาจจับกุมแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปราบปรามการกระทำความผิดนั้น ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีคำพิพากษาในคดี Steagald v. United States[7] วินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานมีหมายจับ Lyons ไม่เพียงพอที่จะทำให้เจ้าพนักงานสามารถค้นบ้านของ Steagald เพื่อจับกุม Lyons โดยไม่มีหมายค้น โดยให้เหตุผลว่า

1. ในคดีนี้มีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแตกต่างกันเป็นสองประการ คือ สิทธิของ Lyons ที่จะไม่ถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร และสิทธิของ Steagald ที่จะไม่ถูกค้นเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อหมายจับเป็นเพียงหลักประกันว่าการจับกุม Lyons ไม่ใช่การจับกุมโดยไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น การที่เจ้าพนักงานเข้าค้นบ้านของ Steagald จึงไม่ต่างกับการค้นที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในคดีอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานไม่มีทั้งหมายค้นและหมายจับ

2. เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งเป็นที่มาของหลักการค้นต้องมีความเฉพาะเจาะจงตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่แล้ว หากยอมให้เจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานได้โดยอาศัยเพียงหมายจับ จะทำให้การค้นนั้นระบุเฉพาะเจาะจงเพียงบุคคลที่ต้องการพบโดยไม่ระบุเจาะจงสถานที่ที่จะทำการค้น อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจค้นบ้านของบุคคลใดก็ได้ และมีผลเป็นการขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญไม่ต่างกับ การค้นตาม writ

---

[7] 451 U.S. 204 (1981).

of assistance[8] ซึ่งเป็นหมายค้นที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจง หรือที่เรียกว่า general warrant

3. หลักการค้นตามหมายค้นในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจนเกินควร เนื่องจากในกรณีที่เจ้าพนักงานสามารถเข้าค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยโดยอาศัยหมายจับเพียงอย่างเดียวได้ นอกจากนี้ยังสามารถอ้างหลักการค้นในกรณีฉุกเฉินหรือ Exigent-circumstances ได้อยู่แล้ว ดังนั้น เจ้าพนักงานจึงไม่อาจอ้างเพียงความไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเหตุในการใช้อำนาจที่อาจกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และสิทธิที่จะไม่ถูกค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีเหตุอันควรของบุคคลภายนอกได้

ด้วยเหตุนี้ หลักการค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 92 (5) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยจึงสอดคล้องกับหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในที่รโหฐานมากกว่ามุ่งการปราบปรามการกระทำความผิดเช่นกฎหมายอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้เจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดโดยไม่มีหมายค้นได้เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านก็อาจเป็นการเปิดช่องให้แก่บุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกจับกุมให้ซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานของตนและช่วยให้หลบหนีไปเสียก่อนที่เจ้าพนักงานจะได้หมายค้นจากศาล โดยในสหรัฐอเมริกานั้นแม้คำพิพากษาบรรทัดฐานจะห้ามการค้นที่รโหฐานของบุคคลภายนอกโดยอาศัยเพียงหมายจับ แต่ก็มีข้อยกเว้นเรื่องการค้นฉุกเฉินเพื่อจับกุมบุคคลตามหมายจับที่เจ้าพนักงานเห็นว่าได้หลบหนีเข้าไปในที่รโหฐานของบุคคลอื่นตามหลัก Hot pursuit หรือเพื่อจับกุมบุคคลที่เจ้าพนักงานได้ตามสืบจนทราบว่ากำลังจะหลบหนีไปจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามหลัก Fresh pursuit ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่ากฎหมายไทย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำในมาตรา 92 (5) จะเห็นได้ว่าการค้นที่รโหฐานในกรณีนี้เป็นการค้นหาเฉพาะตัวผู้ถูกออกหมายจับโดยไม่ครอบคลุมถึงการค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา 85[9] ซึ่งเป็นเรื่องการค้น

---

[8]ดูคำอธิบายในหัวข้อ 3.2.2 รายการที่ต้องระบุในหมายค้นและการบังคับตามหมาย น. 45.

[9] มาตรา 85 เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

สืบเนื่องจากการจับกุมโดยตรงแล้ว ได้ใช้ถ้อยคำว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจค้น “ตัวบุคคล” ผู้ถูกจับกุม จึงไม่อาจตีความว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจค้นบริเวณที่มีการจับกุมซึ่งแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษที่ต่างกำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานกระทำการค้นที่รโหฐานสืบเนื่องจากการจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ทั้งนี้ ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ

ก. กฎหมายอังกฤษ กำหนดอำนาจในการแสวงหาพยานหลักฐานสืบเนื่องจากการจับกุมไว้ในมาตรา 18 และมาตรา 32 ของ PACE ดังนี้

1. อำนาจค้นหาพยานหลักฐานมาตรา 32 (b) ของ PACE ซึ่งให้อำนาจเจ้าพนักงานในการตรวจค้นสถานที่ของบุคคลใดก็ตามที่บุคคลผู้ถูกจับกุมในความผิดประเภท indictable offence อยู่ในขณะถูกจับกุม หรือบุคคลผู้ถูกจับกุมเพิ่งเข้าไปในทันทีทันใดก่อนถูกจับกุม เพื่อหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น

2. อำนาจค้นหาพยานหลักฐานตามมาตรา 18 ของ PACE ซึ่งเป็นกรณีที่ได้มีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดในความผิดประเภท indictable offence ไว้แล้วในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่ที่รโหฐานตามมาตรา 32 แต่เพื่อประโยชน์การสอบสวน เช่น เพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานจึงให้เจ้าพนักงานเข้าไปค้นสถานที่ที่ผู้ถูกจับเป็นผู้ครอบครองดูแลได้หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น หรือมีพยานหลักฐานในคดีอาญาร้ายแรงอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกับการกระทำความผิดนั้น

ข. ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ให้อำนาจเจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิดในที่รโหฐานนั้นโดยการค้นต้องกระทำในขณะเดียวกับการจับกุมเท่านั้นตามหลัก search incidence to arrest

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการค้นสถานที่ที่ผู้ถูกจับอยู่ในขณะจับกุมตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษไม่จำกัดว่าเป็นการค้นสถานที่ของผู้ถูกจับกุมเองหรือของบุคคลภายนอก หากแต่การค้นตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจำกัดเฉพาะบริเวณที่ผู้ถูกจับอาจเอื้อมไปถึง ในขณะที่การจับกุมตามมาตรา 32 ของอังกฤษกระทำได้โดยไม่จำกัดบริเวณในการค้น จึงอาจค้นบ้านได้ทั้งหลัง แต่จะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นการจับกุมในความผิดประเภท indictable offence ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงเท่านั้น

นอกจากนี้ ตามกฎหมายอังกฤษคือมาตรา 18 ของ PACE ยังได้ขยายขอบเขตในการค้นสืบเนื่องจากการจับกุมไปถึงการค้นสถานที่ของผู้ถูกจับกุมโดยไม่มีหมายค้นจากศาลได้ หากแต่กำหนดกระบวนการในการควบคุมโดยให้การใช้ดุลยพินิจในการค้นของเจ้าพนักงานต้องได้รับการอนุญาตหรือการรับรองจากเจ้าพนักงานในระดับ inspector ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนั้นด้วย ส่วนในกรณีที่ไม่มีการรับรองก็กระทำได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเช่นเดียวกับการค้นโดยไม่มีหมายตามหลักการค้นฉุกเฉิน หรือ exigent circumstance ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากแนวทางการค้นที่รโหฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานสืบเนื่องจากการจับกุมของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นดังนี้

1. ในการค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดนั้น นอกจากการให้อำนาจเจ้าพนักงานค้น “ตัวบุคคล” ที่ถูกจับกุมแล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 85 ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจค้น “บริเวณ” เพื่อยึดพยานหลักฐานในความผิดในที่รโหฐานนั้นขณะทำการจับกุมได้ภายในบริเวณที่จำกัด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อตัวเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่น รวมถึงการทำลายพยานหลักฐานในลักษณะเดียวกับหลักการค้นในขณะจับกุม หรือ search incidence to arrest โดยไม่จำกัดว่าการจับกุมนั้นจะเกิดขึ้นในที่รโหฐานของผู้ถูกจับกุมหรือของบุคคลอื่นก็ตาม

2. การขยายขอบเขตการค้นในขณะจับกุมให้คลอบคลุมบ้านหรือที่รโหฐานทั้งหลังหรือการค้นที่รโหฐานของผู้ถูกจับสืบเนื่องจากการจับกุมผู้กระทำความผิดในสถานที่อื่นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินในการค้น หรือ exigent circumstance ในลักษณะเดียวกับการค้นโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 (4) อีกต่างหาก เช่น เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยจากการเห็นหรือได้ทราบว่ามีบุคคลอื่นอยู่ในที่รโหฐานนั้นซึ่งอาจทำให้พยานหลักฐานในการกระทำความผิดอาจถูกโยกย้ายหรือทำลายโดยความช่วยเหลือของบุคคลอื่นในที่รโหฐานนั้นเสียก่อนที่เจ้าพนักงานจะขอหมายค้นมาอีกครั้ง

4.5 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการออกหมายค้นและการค้นโดยไม่มีหมาย

เมื่อพิจารณาหลักการออกหมายค้นตามกฎหมายไทย มาตรา 59/1 ที่ระบุว่าก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นประกอบกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 15 ที่กำหนดว่าผู้ร้องขอต้องเสนอพยานหลักฐานที่ “น่าเชื่อ” ว่า

(1) บุคคลหรือสิ่งของที่ค้นหาน่าจะอยู่ในสถานที่ที่จะค้น และ

(2) สิ่งของหรือบุคคลนั้นเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลที่เป็นเหตุในการออกหมายค้น

ดังนั้น เหตุในการออกหมายค้นตามกฎหมายไทยจึงสอดคล้องกับหลักเหตุที่เป็นไปได้ (probable cause) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และหลักเหตุอันควรเชื่อ (reasonable grounds for believe) ตามกฎหมายอังกฤษ

อย่างไรก็ดี ในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 92 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ปรากฏถ้อยคำว่า “มีเหตุอันควรเชื่อ” อยู่เฉพาะในอนุมาตรา 4 เท่านั้น ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าการบัญญัติถ้อยคำดังกล่าวไว้เฉพาะในอนุมาตรา 4 มีที่มาสืบเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการใช้ดุลยพินิจในการค้นที่รโหฐานแต่ละกรณีแล้ว การค้นตามอนุมาตรา 4 ซึ่งระบุว่า “เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน” เป็นกรณีที่ให้ดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ไว้กว้างขวางที่สุด แม้ว่าโดยหลักการแล้วการค้นที่รโหฐานทุกกรณีล้วนเป็นเรื่องของดุลยพินิจซึ่งเป็นเหตุให้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกายึดถือหลักเหตุที่เป็นไปได้และกฎหมายอังกฤษยึดถือหลักเหตุอันควรเชื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาว่ามีเหตุในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือไม่ (เว้นแต่การค้นสถานที่ภายหลังการจับกุมตามมาตรา 18 ของ PACE ซึ่งมีเพียงเหตุอันควรสงสัย หรือ “reasonable grounds for suspect” ก็สามารถค้นโดยไม่มีหมายได้)

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการค้นที่รโหฐานต้องคำนึงถึงว่าก่อนจะทำการค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า มีสิ่งของหรือบุคคลในที่รโหฐานนั้นซึ่งเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่เป็นเหตุในการออกหมายค้นหรือเป็นเหตุในการค้นโดยไม่มีหมายค้นเสมอ และหากเหตุอันควรเชื่อดังกล่าวหมดไปย่อมเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานหมดอำนาจในการค้นที่รโหฐานแม้ว่าจะไม่พ้นกำหนดระยะเวลาตามหมายค้นก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษยังมีแนวคิดว่าการจะตัดสินว่ากรณีใดที่มีเหตุอันเป็นไปได้หรือไม่ ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่สังคมจะได้รับประโยชน์จากความสำเร็จในการค้นเกินกว่าผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย ยกตัวอย่างเช่น การที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยว่าการค้นบ้านของบุคคลที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ไม่จำเป็นต้องมีเหตุที่เป็นไปได้ เพียงแต่มีความสงสัยตามสมควรก็เพียงพอ เนื่องจากเมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของรัฐที่เกิดจากการใช้มาตรการที่ต่ำกว่าและผลเสียต่อ

ประโยชน์ของเอกชนแล้ว การค้นดังกล่าวยังมีความสมเหตุสมผล หรือกรณีมาตรา 18 ของ PACE ที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานค้นสถานที่ที่ผู้ถูกจับในคดีความผิดอาญาร้ายแรงเป็นผู้ครอบครองดูแล แม้มีเพียง “เหตุอันควรสงสัย” ว่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น หรือมีพยานหลักฐานในคดีอาญาร้ายแรงอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่พยานพบเห็นการกระทำความผิดของบุคคลเพียงคนเดียวแต่คำให้การเกี่ยวกับรูปลักษณะของผู้กระทำความผิดตรงกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นฝ่าแฝดสองคน จึงมีปัญหาว่าศาลจะออกหมายค้นบ้านของบุคคลทั้งสองได้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาตามแนวทางดังกล่าวแล้วจะตอบปัญหาได้ว่า ถ้าการกระทำความผิดนั้นเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยแล้ว ประโยชน์ที่สังคมได้รับย่อมไม่ได้สัดส่วนกับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของแฝดอีกคนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอน

4.6 **หลักการค้นต้องกระทำในเวลากลางวัน**

หลักการค้นที่รโหฐานในทุกประเทศต่างยอมรับว่าการค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของปุถุชนคนธรรมดาเป็นการละเมิดสิทธิในเคหสถานและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลเกินสมควร ประกอบกับการค้นในเวลากลางคืนย่อมมีแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้เสี่ยงต่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคล การค้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นการค้นที่ไม่สมควรแก่เหตุและทำให้การค้นนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการค้นโดยไม่มีอำนาจ

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษพบว่าการกำหนดช่วงเวลากลางวันซึ่งทำให้การค้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมีความแตกต่างในรายละเอียดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 96 ที่ระบุว่า “การค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก” กล่าวคือ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐส่วนใหญ่ได้กำหนดให้เวลากลางวัน (day time) คือ ช่วงเวลาระหว่าง 6:00 นาฬิกา ถึง 22:00 นาฬิกา เนื่องจากในแต่ละฤดูกาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกแตกต่างกันมาก จึงได้กำหนดช่วงเวลากลางวันให้ยาวนานสอดคล้องกับเวลาในประเทศ ในขณะที่ประเทศอังกฤษกำหนดแต่เพียงว่าการค้นต้องกระทำในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติหมายถึงการค้นในเวลากลางวันที่ผู้ครอบครองสถานที่มักจะปรากฏตัวและไม่ได้เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนนอนหลับของเขา เว้นแต่เมื่อพิจารณาถึงบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ที่จะทำการค้นนั้น การค้นในช่วงเวลากลางคืนเป็นการค้นที่ไม่ได้กระทบต่อสิทธิ

ในความเป็นส่วนตัวหรือการพักผ่อนนอนหลับของบุคคลในสถานที่ดังกล่าว เช่น การค้นสถานที่ที่เปิดให้บริการในตอนกลางคืนในบริเวณที่ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายตลอดจนมีการประกอบกิจการต่างๆ ในเวลากลางคืน

อย่างไรก็ตาม แม้โดยทั่วไปการค้นที่รโหฐานจะต้องกระทำในเวลากลางวัน แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการกระทำความผิดบางอย่างและสถานที่ที่ต้องการค้น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษจึงกำหนดข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานสามารถทำการค้นในเวลากลางคืนได้ไม่ว่าจะเป็นการค้นโดยมีหมายหรือไม่มีหมายค้นก็ตาม ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าว ได้แก่

(1) เมื่อมีการค้นในเวลากลางวันต่อเนื่องไปจนถึงเวลากลางคืน เนื่องจากพยานหลักฐานในการกระทำความผิดบางอย่างมีจำนวนมากและยากต่อการค้นหาในช่วงเวลาอันจำกัด เช่น เอกสาร หรือข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการค้นในเวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยตามมาตรา 96 (1) ที่ระบุว่า เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้

(2) เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องทำการค้นที่รโหฐานโดยไม่อาจรอจนถึงเวลากลางวันได้ เนื่องจากมีเหตุที่เป็นไปได้ว่าจะมีการทำลายพยานหลักฐานในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่จะเข้าค้นมีลักษณะเป็นที่อาศัยชั่วคราวซึ่งบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการพบจะถูกเก็บหรือซ่อนอยู่ไม่เกินข้ามคืน รวมถึงกรณีที่มีรายงานการกระทำความผิดอาญาในที่รโหฐาน และผู้กระทำความผิดยังคงอยู่ในที่รโหฐานนั้น ตลอดจนการเข้าจับกุมการกระทำความผิดบางอย่างที่มักเกิดขึ้นในที่รโหฐานเฉพาะในเวลากลางคืน เช่น การซื้อขายยาเสพติดครั้งสำคัญ ซึ่งหากไม่มีการเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืนอาจทำให้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดพยานหลักฐานในคดีได้ ทั้งนี้ความหมายของความฉุกเฉินที่เป็นเหตุให้ค้นในเวลากลางคืนเป็นไปตามหลัก Exigent circumstance ซึ่งเป็นข้อยกเว้นหลักการค้นต้องมีหมายค้นด้วย โดยหลักการค้นในเวลากลางคืนในประเทศสหรัฐอเมริกามีความใกล้เคียงกับหลักการค้นตามมาตรา 96 (2) “กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง” อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยพบว่า ในทางปฏิบัติศาลมักจะวินิจฉัยว่ากรณีมี “เหตุฉุกเฉินอย่างยิ่ง” เมื่อพฤติการณ์ในคดีมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าในเวลากลางคืน ดังนั้น การปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 96 (2) ของศาลไทยจึงค่อนข้างจำกัดกว่าหลักความฉุกเฉินตามหลักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าอาจนำแนวทางในการค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนตามหลักกฎหมายสหรัฐอเมริกามาประกอบการพิจารณาของศาลไทยได้

สำหรับการค้นในเวลากลางคืนตามมาตรา 96 (3) ที่บัญญัติว่า “การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา” นั้น เป็นกรณีที่ผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญอยู่ในที่รโหฐานโดยไม่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าใดๆ[10] แต่มีความจำเป็นเนื่องจากผู้ดุร้ายและผู้ร้ายสำคัญมีสภาพจิตใจ หรือมีลักษณะที่จะทำอันตรายแก่เจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นได้มากกว่าผู้กระทำความผิดโดยทั่วไป และการจับกุมโดยวิธีปกติหรือการจับกุมในเวลากลางวันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการจับกุมในเวลากลางคืนซึ่งเจ้าพนักงานสามารถอาศัยความมืดในการอำพรางตัวและเป็นช่วงเวลาที่ผู้กระทำความผิดมักจะขาดความระมัดระวัง กฎหมายจึงให้เจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานเพื่อจับกุมบุคคลดังกล่าวในเวลากลางคืนได้ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ในกฎหมายของรัฐมินิโซตา หรือ Minnesota Statues มาตรา 626.14 ก็ได้บัญญัติให้ศาลสามารถออกหมายค้นเพื่อให้เจ้าพนักงานทำการค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนได้หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่เจ้าพนักงานหรือประชาชน และในกฎหมายอังกฤษ The police and Criminal evidence Act 1984 มาตรา 16 ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานต้องทำการค้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม(reasonable hour) ซึ่งโดยทั่วไปคือการค้นในเวลากลางวัน แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของผู้กระทำความผิดที่มีความเป็นอันตรายมากแล้ว ย่อมถือได้ว่าการค้นในเวลากลางคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมตามนัยของมาตรา 16

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าข้อ 36 ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ได้ระบุว่า ในการร้องขอให้ออกหมายค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญในเวลากลางคืน ผู้ร้องต้องเสนอพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ดุร้ายหรือเป็นผู้ร้ายสำคัญ และมี “เหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำในเวลากลางคืน มิฉะนั้นผู้นั้นจะหลบหนีหรือก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรง” จึงทำให้การค้นตามมาตรา 96 (3) กลายเป็นการค้นโดยเหตุฉุกเฉินในลักษณะเดียวกับการค้นตามมาตรา 96 (2) ซึ่งเจ้าพนักงานสามารถค้นในเวลากลางคืนได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามมาตรา 96 (3) แต่อย่างใด

---

[10]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2553), น. 449-450.

4.7 การยึดสิ่งของที่ได้จากการค้นในที่รโหฐาน

เมื่อเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะเข้าไปทำการค้นในที่รโหฐานแล้วไม่ว่าโดยอาศัยอำนาจของหมาย หรือเหตุที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าพนักงานค้นได้โดยไม่มีหมายก็ตาม การค้นเพื่อหาบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องเป็นไปตามกรอบหรือขอบเขตที่มาของอำนาจซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองกรณี คือ

1. ขอบเขตของการค้นในกรณีที่มีหมาย ซึ่งถือหลักว่า เมื่อหมายค้นมีขึ้นเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้าไปในที่รโหฐานอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและใช้ในการจำกัดอำนาจของเจ้าพนักงานผู้ทำการค้น ว่าจะค้นที่ไหน และค้นหาอะไรแล้ว ขอบเขตของการค้นก็ต้องจำกัดตามที่หมายค้นระบุ

2. ขอบเขตของการค้นในกรณีที่ไม่มีหมาย ย่อมเป็นการค้นเพียงเท่าที่จะทำให้พบสิ่งของหรือบุคคลที่เป็นเหตุให้มีอำนาจค้นโดยไม่มีหมาย

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานแม้จะได้ทำการค้นสถานที่โดยยึดถือตามหลักดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติย่อมมีกรณีที่เจ้าพนักงานพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า หรือพบสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด สิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดอื่น หรือแม้แต่พยานหลักฐานในคดีอื่นโดยความบังเอิญ จึงเกิดคำถามว่าในกรณีเช่นนี้ เจ้าพนักงานไม่ได้มีอำนาจเข้าไปเพื่อค้นหาบุคคลหรือพยานหลักฐานดังกล่าว แล้วเจ้าพนักงานจะมีอำนาจยึดสิ่งของหรือจับกุมบุคคลที่พบโดยบังเอิญซึ่งมีผลเป็นการขยายขอบเขตของการค้นต้องจำกัดสิ่งที่ค้นได้หรือไม่ เพียงใด

ในประเทศอังกฤษการขยายขอบเขตการค้นและยึดเป็นไปตามมาตรา 19 ของ PACE ซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของดังกล่าวได้มาโดยผลของการกระทำความผิด และมีความจำเป็นต้องยึดเพื่อป้องกันการปกปิด สูญหาย ทำให้เสียหาย โยกย้าย หรือถูกทำลาย

(2) เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เขากำลังสอบสวนหรือความผิดอื่นเพื่อป้องกันการปกปิด การสูญหาย การโยกย้าย หรือการทำลาย โดยการยึดพยานหลักฐานตาม (2) นี้ ต้องไม่ใช่สิ่งของที่มีเอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกยึด (subject to legal privilege)

ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักในการขยายขอบเขตในการค้นที่เรียกว่า หลักพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง หรือ Plain view doctrine โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) เจ้าหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถพบสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Discovery)

(2) เจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าในทันทีว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นของที่ถูกขโมย หรือเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดนั้นหรือพยานหลักฐานในความผิดอื่น

(3) เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (Lawful access)

สำหรับการขยายขอบเขตของการค้นที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยนั้น มาตรา 98 วรรคหนึ่ง ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุว่า การค้นในที่รโหฐานจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น เว้นแต่

(1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย

(2) เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า

มาตรา 98 (1) และ (2) นี้มีลักษณะเป็นการขยายอำนาจในการจับบุคคล หรือยึดสิ่งของนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมายค้น หรือนอกเหนือจากสิ่งที่ต้องการค้นหาในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมาย แยกพิจารณาได้ดังนี้

1. การค้นสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งตามอนุมาตรา 1 ได้มีนักกฎหมายอธิบายไว้ว่า กรณีนี้เป็นเรื่องของการค้นตามหมายค้นที่ระบุให้ค้นได้โดยไม่จำกัดสิ่ง ซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Unspecified article”[11] เนื่องจากในทางปฏิบัติวิธีค้นมีทั้งสิ่งของที่จำกัดและไม่จำกัด ถ้าออกหมายตามวรรคแรกของมาตรา 98 จะไม่ได้ผลนัก แต่เมื่อออกหมายตาม (1) คือไม่จำกัดสิ่งแล้วก็จะได้ผลในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ในหมายระบุ

---

[11] หยุด แสงอุทัย, “รายงานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ 336-15/2511,” วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2511, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, น. 2.

ว่า ค้นหาของหาย[12] ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ หากศาลออกหมายค้นเพื่อหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง หรือออกหมายค้นเพื่อจับกุมบุคคลซึ่งโดยปกติย่อมระบุให้ค้นหาพยานหลักฐานได้ด้วย การที่เจ้าพนักงานเข้าไปค้นตามหมายดังกล่าวแล้วแล้วเจอพยานหลักฐานใดๆ ที่เจ้าพนักงานเห็นว่าน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้ว เจ้าพนักงานก็สามารถยึดไว้ได้โดยอาศัยมาตรา 98 (1)

2. การจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้าตามอนุมาตรา 2 เป็นกรณีที่เมื่อเจ้าพนักงานเข้าไปในที่รโหฐานเพื่อพบบุคคลหรือสิ่งของแล้ว

พบบุคคลอื่นที่ถูกออกหมายจับหรือพบบุคคลอื่นกระทำความผิดซึ่งหน้าก็จับบุคคลนั้นได้

พบการกระทำความผิดซึ่งหน้า เช่น สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด พยานหลักฐานในการกระทำความผิดซึ่งหน้านั้น ก็ยึดไว้ได้

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทยหากเข้าไปโดยอาศัยหมายค้นโดยไม่จำกัดสิ่งแล้ว ย่อมขยายขอบเขตการค้นเพื่อยึดสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้ เช่นเดียวกับหลักพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้งและมาตรา 19 ของ PACE อย่างไรก็ดี เนื่องจากการออกหมายค้นโดยไม่จำกัดสิ่งมาจากคำว่า “Unspecified article” ซึ่งหมายความว่าในการค้นหาพยานหลักฐานในบางความผิด เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์นั้น ในที่รโหฐานที่ถูกค้นนั้นเจ้าพนักงานยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะพบอะไรบ้าง แต่ก็เชื่อได้ว่าของส่วนใหญ่ที่พบจะมาจากการขโมย ดังนั้น จึงต้องบัญญัติให้ค้นบริเวณที่รโหฐานนั้นได้ทั้งหมดและเมื่อพบอะไรก็ยึดได้ ผู้เขียนเห็นว่า ถ้อยคำที่ว่า “มีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็พยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย” นั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะครอบคลุมถึงการยึดสิ่งของที่น่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานยันผู้ต้องหาหรือจำเลยคนเดียวกันกับที่ออกหมายในคดีอื่น หรือพยานหลักฐานที่ใช้ยันผู้ต้องหาหรือจำเลยคนอื่นๆ ด้วยหรือไม่ เช่นเดียวกับการเข้าไปค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง

---

[12]พลตำรวจโท บันลือ เรืองตระกูล, “รายงานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ 335-14/2511,” วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2511, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, น. 2, 4.

เป็นการเข้าไปเพื่อพบบุคคลหรือสิ่งของที่มีความเจาะจง กล่าวคือ ผู้ก่อเหตุร้ายและผู้เสียหายตามอนุมาตรา 1 ผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและพยานหลักฐานในความผิดซึ่งหน้าตามอนุมาตรา 2 และอนุมาตรา 3 และสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ที่เชื่อว่ากำลังจะถูกโยกย้ายหรือทำลายตามอนุมาตรา 4 หากในการค้นนั้นทำให้พบสิ่งของนอกเหนือจากที่เป็นเหตุให้อำนาจเข้าไปค้นจะอาศัยอำนาจมาตราใดในการยึดสิ่งของนั้น

ผู้เขียนเห็นว่า แม้จะไม่มีบทบัญญัติโดยตรงที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานยึดสิ่งของดังกล่าวได้ แต่เมื่อเทียบเคียงเหตุผลตามมาตรา 92 (4) ซึ่งเป็นกรณีที่แม้ไม่มีหมายค้น แต่เจ้าพนักงานเชื่อว่ามีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกำลังจะถูกโยกย้ายทำลายแล้วก็ยังให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้าไปค้นและยึดได้ ดังนั้น เมื่อในกรณีประกอบด้วยข้อเท็จจริงว่า

(1) การเข้าไปในที่รโหฐานนั้นเป็นการเข้าไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) ระหว่างการยึดทรัพย์สินของบุคคลในที่รโหฐานตามปกติกับการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดอื่นซึ่งพบโดยบังเอิญนั้น ไม่มีการค้นทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาที่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานนั้นแตกต่างกัน

(3) การยึดทรัพย์สินนั้นมีความจำเป็นในลักษณะเดียวกับการค้นฉุกเฉินตามมาตรา 92 (4) เนื่องจากหากไม่ยึดกลับไปในทันที สิ่งของนั้นย่อมเสี่ยงต่อการถูกโยกย้ายหรือทำลาย เนื่องจากเมื่อเจ้าพนักงานเข้าไปในที่รโหฐานและพบเห็นสิ่งของดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้กระทำความผิดจะซ่อนเร้น โยกย้าย หรือทำลายทรัพย์นั้นเสีย

เจ้าพนักงานจึงสมควรมีอำนาจในการยึดสิ่งของที่พบโดยบังเอิญนั้นได้ อย่างไรก็ดี สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาว่าการยึดจะมีขอบเขตเพียงใดที่จะทำไม่ทำให้เจ้าพนักงานทำการค้นอะไรก็ได้โดยไม่จำกัด ผู้เขียนเห็นควรนำหลักการในเรื่องพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้งของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ กล่าวคือ เจ้าพนักงานต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถพบสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าในทันทีว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นของที่ถูกขโมย หรือเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดนั้นหรือพยานหลักฐานในความผิดอื่น

อนึ่ง ในส่วนของมาตรา 98 (1) นั้น แม้จะมีผลเป็นการขยายขอบเขตการค้นเพื่อทำการยึดสิ่งของนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหมายซึ่งกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษยอมรับว่ากระทำได้ แต่ผู้เขียนก็มีความเห็นสอดคล้องกับกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (นายหยุด แสงอุทัย) ว่าในการค้นจะต้องระบุว่าจะค้นอะไรบ้าง แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าไปพบสิ่งใดที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วก็ให้ยึดได้ด้วย ไม่ใช่ให้ค้นได้ทั้งหมดทีเดียว เช่น ต้องระบุว่าจะค้นปืนของกลางในความผิดฐานฆ่าคนตาย แต่ถ้าในการค้นไปพบเสื้อเปื้อนเลือดอันจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ก็เป็นเรื่องที่เข้าข้อยกเว้นไป[13] ดังนั้น โดยหลักแล้วหมายค้นจึงต้องระบุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งสถานที่ที่จะทำการค้น และบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการค้น ส่วนการที่ศาลจะออกหมายค้นโดยไม่จำกัดสิ่งที่ค้นตามมาตรา 98 (1) สมควรพิจารณาว่าในกรณีนั้นมีความจำเป็นอย่างแท้จริงเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะพบสิ่งของหลายอย่างที่ยากต่อการระบุโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 60 (4) (ค) ที่บัญญัติว่าในกรณีออกหมายค้น ให้ระบุสถานที่ที่จะค้น และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล หรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น กำหนดวันเวลาที่จะทำการค้น และชื่อกับตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้นนั้น

4.8 ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่กฎหมายกำหนด

ในประเด็นปัญหาว่า หากเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องการค้นในที่รโหฐานแล้ว จะส่งผลอย่างไรต่อการรับฟังพยานหลักฐานและความรับผิดทางอาญาของเจ้าพนักงานนั้น ผู้เขียนได้แยกพิจารณาดังนี้

4.8.1 ผลของการค้นที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การค้นที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากการค้นที่รโหฐานโดยเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ

(1) การค้นโดยไม่มีอำนาจ

(2) การค้นโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดขั้นตอนปลีกย่อย

การจำแนกว่ากรณีใดที่ถือว่าเป็นการค้นโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งจะมีผลในการตัดพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นนั้นออกจากการรับฟังของศาลนั้น พบว่าในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษมีหลักการที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ โดยหลักแล้วการค้นโดยไม่มี

---

[13]หยุด แสงอุทัย, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11*, น. 2-4.

อำนาจหมายถึงการค้นโดยไม่มีหมายค้นที่ออกโดยศาล และการค้นโดยไม่มีเหตุให้ค้นได้โดยไม่มีหมาย ซึ่งได้แก่ การค้นโดยไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่และกฎหมายของสหรัฐและรัฐต่างๆ การค้นโดยไม่มีเหตุอันควรเชื่อ (reasonable grounds for believing) ว่ามีพยานหลักฐานอยู่ในที่รโหฐานนั้น ตาม The Police and Criminal Evidences Act 1984 (PACE) และการค้นโดยไม่มีเหตุตามมาตรา 92 (1) – (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย นอกจากนี้ การค้นโดยไม่มีอำนาจยังรวมถึงการค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจที่จะทำการค้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย การค้นโดยมิชอบหรือค้นโดยไม่มีอำนาจนี้เป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นนั้นตามหลัก Exclusionary Rule ของสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 226/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ส่วนการค้นโดยไม่มีอำนาจตามประเทศอังกฤษนั้น กฎหมายคอมมอนลอว์และมาตรา 78 ของ PACE ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการใช้ดุลยพินิจไม่รับฟังพยานหลักฐานของประเทศอังกฤษไม่ได้กล่าวถึงผลของการค้นโดยไม่มีอำนาจไว้โดยตรง แต่มุ่งพิจารณาว่าการค้นโดยไม่มีอำนาจนั้นทำให้จำเลยไม่ได้รับการดำเนินคดีที่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งหมายความว่า ผลร้ายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเกินกว่าประโยชน์ในการสอบสวนโดยแนวคำพิพากษาส่วนใหญ่วินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าว ได้แก่ การข่มขู่หลอกลวงให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานแม้ว่าจะมีการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือไม่มีเหตุให้ค้นโดยไม่มีหมาย

นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษยังได้ให้ความสำคัญกับการค้นโดยไม่มีอำนาจอันสืบเนื่องมาจากความบกพร่องของหมายค้น หรือ Defective Warrant ที่หากร้ายแรงถึงขนาดทำให้หมายค้นเสียไปแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นการค้นโดยไม่มีหมายค้นซึ่งทำให้ไม่มีฐานที่มาของอำนาจที่จะทำการค้น หมายค้นที่บกพร่องนี้ได้แก่ หมายค้นที่ไม่มีเหตุในการออกหมายค้น และหมายค้นที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหมายถึงหมายค้นที่มีลักษณะดังนี้

(1) หมายค้นที่ไม่ระบุเจาะจงสถานที่ที่จะทำการค้น เช่น คดี State v. Jones[14] ได้ให้แนวทางไว้ว่าหมายค้นที่ระบุที่อยู่ผิดพลาดจะไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานก็ต่อเมื่อมีการบรรยายถึงสถานที่ที่จะทำการค้นไว้เพียงพอที่จะทำให้เจ้าพนักงานไม่ทำการค้นบ้านผิดหลัง

(2) หมายค้นที่ไม่ระบุเจาะจงสิ่งของที่ต้องการค้นหา ได้แก่ หมายค้นที่อนุญาตให้ค้นหาสิ่งของได้ไม่จำกัดสิ่ง (Overbroad) และหมายค้นที่ให้เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจพิจารณา

---

[14]Lucas App. No. L-00-1231, 2003-Ohio-219.

ความหมายของสิ่งของที่จะค้นได้เอง เช่น คดี Lo-ji Sales, Inc. v. New York[15] ศาลได้วินิจฉัยว่า หมายค้นที่ระบุเพียงว่า “เพื่อค้นและยึดวัตถุลามกใดๆ” ไม่เป็นไปตามหลักหมายค้นต้องเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าวัตถุใดเป็นวัตถุลามกเองเสียเองในขณะที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาล อีกทั้งไม่มีการกำหนดกรอบหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ในหมายค้น

ในกรณีนี้ไม่มีแนวคำวินิจฉัยว่าหมายค้นที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา 60 (ค) ที่ได้บัญญัติว่า “ในกรณีออกหมายค้น ให้ระบุสถานที่ที่จะค้น และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล หรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น กำหนดวันเวลาที่จะทำการค้น และชื่อกับตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้นนั้น” และมาตรา 98 ที่บัญญัติไว้ว่า “การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น” จะมีผลให้หมายค้นนั้นเสียไปและการค้นตามหมายนั้นกลายเป็นการค้นโดยไม่มีอำนาจด้วยหรือไม่

ผู้เขียนเห็นว่า จากการพิจารณาบทบัญญัติในส่วนข้อยกเว้นในมาตรา 98 (1) ที่ระบุว่าเว้นแต่ให้ค้นโดยไม่จำกัดสิ่ง ประกอบกับคำพิพากษาฎีกาที่ 6475/2547[16] วินิจฉัยว่า การแก้เลขที่บ้านในหมายค้น เพื่อให้ตรงกับความจริงโดยไม่มีอำนาจอาจมีผลให้หมายค้นเสียไปและการค้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหาก เมื่อปรากฏว่าคดีมีการสอบสวนกันโดยชอบ ทั้งในชั้นพิจารณาจำเลยก็นำสืบรับว่าเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลางฝังอยู่ในดินห่างจากบ้านของจำเลยประมาณ 3 เมตร พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาย่อมรับฟังลงโทษจำเลยได้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1328/2544[17], 3479/2548[18] วินิจฉัยว่า หมายค้นระบุเลขที่บ้านผิดไปหามีผลทำให้หมายค้นเสียไป โดยศาลไม่ได้พิจารณาว่ามีการระบุรายละเอียดอย่างอื่นของบ้าน เช่น สี รูปทรง จุดสังเกตอย่างอื่นที่ทำให้การค้นมีความเฉพาะเจาะจง จึงน่าจะต้องถือระบบกฎหมายไทยไม่ยึดถือหลักการค้นโดยไม่จำกัดสิ่งมาเป็นเหตุให้การค้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

---

[15] 442 U.S. 319, 325 (1979).

[16] คำพิพากษาฎีกาที่ 6475/2547 (ฎส. 7), น. 194.

[17] คำพิพากษาฎีกาที่ 1328/2544 (ฎส. 3X), น. 107.

[18] คำพิพากษาฎีกาที่ 3479/2548, http://deka2007.supremecourt.or.th/ deka/web/searchlist.jsp.

4.8.2 ผลของการค้นโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดในกรณีที่เจ้าพนักงานมีความสุจริต

(1) ความสุจริตของเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นกับการรับฟังพยานหลักฐาน

การรับฟังพยานหลักฐานหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของศาลคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการนำปัจจัยเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเจ้าพนักงานมาประกอบการใช้ดุลยพินิจของศาลได้ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาในบทที่ผ่านมาว่าทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ต่างก็มีบทบัญญัติหรือแนวคำพิพากษาที่นำหลักเรื่องความสุจริต (Good Faith) หรือเจตนาทุจริต (Bad Faith) มาใช้ประกอบการรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งในกฎหมายไทยเองก็ได้บัญญัติถึงหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 226/1 วรรคสอง (3) ในส่วนของการคำนึงถึงลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบ

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าการนำสภาพจิตใจของเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นมาใช้ในการพิจารณามีขอบเขตเช่นไร โดยเฉพาะกรณีเจตนาสุจริตนั้นจะใช้ในขอบเขตใด ในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักการที่คำนึงถึงความสุจริตของเจ้าพนักงานคือ หลักความสุจริต หรือ Good Faith อย่างไรก็ตาม หลักดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อยกเว้นให้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่หมายค้นมีความบกพร่องอันเนื่องมาจากความผิดของศาลและเจ้าพนักงานไม่รู้ถึงความบกพร่องของหมายนั้น ขอบเขตของหลักความสุจริตนี้จึงจำกัดว่าเป็นการคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานที่อยู่บนพื้นฐานการอ้างหมายที่ศาลเป็นผู้ออกเท่านั้น โดยไม่รวมไปถึงความเชื่อว่ามีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) ที่ทำให้เจ้าพนักงานค้นได้โดยไม่มีหมายค้นในกรณีต่างๆ ซึ่งการที่เจ้าพนักงานเชื่อว่ามีเหตุอันเป็นไปได้นี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าพนักงานไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ทำให้ไม่มีอำนาจ แต่ในทางตรงกันข้าม การเชื่อว่ามีเหตุที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

หลักความสุจริตหรือ Good Faith นี้ทำให้ศาลที่จะพิจารณาคดีต้องมองข้ามความไม่ชอบด้วยกฎหมายของหมายนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุที่หมายนั้นไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ในการออกหมายค้น หรือไม่ระบุโดยเฉพาะเจาะจงถึงสถานที่ที่จะทำการค้นหรือสิ่งของที่ต้องการค้นก็ตาม โดยถือว่าการลงโทษเจ้าพนักงานโดยการไม่รับฟังพยานหลักฐานไม่มีผลต่อการยับยั้งการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเพราะเจ้าพนักงานไม่ทราบว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนั่นเอง

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานมีความสุจริตต่อเมื่อพิจารณาเหตุผลในทางภาวะวิสัยแล้ว (Objective Reasonable) เจ้าพนักงานอื่นๆ ที่มีเหตุผล มีความรู้ และได้รับการฝึกฝนอย่างดี จะต้องเชื่อโดยสุจริตใจในผลของหมายค้นเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานผู้ทำการค้นนั้น

สำหรับการพิจารณาถึงความสุจริตของเจ้าพนักงานตามกฎหมายอังกฤษแล้ว ศาลอังกฤษจะพิจารณาปัจจัยดังกล่าวน้อยเสียยิ่งกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าประเทศอังกฤษคำนึงถึงผลเสียของการรับฟังพยานหลักฐานโดยอาศัยเพียงความสุจริตใจ หากแต่เนื่องจากตามหลักกฎหมายอังกฤษศาลจะคำนึงถึงการถ่วงดุลย์ระหว่างคุณค่าของพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดกับประเด็นว่าการค้นโดยมิชอบนั้นถึงกับทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม ซึ่งหมายความว่ามีการกระทำของเจ้าพนักงานที่ขัดหรือละเมิดต่อกฎหมาย “อย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญ” (significant and substantial) อันอาจทำให้ศาลใช้ดุลยพินิจไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นตามมาตรา 78 ของ PACE ซึ่งตามแนวคำพิพากษาส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานมีเจตนาทุจริต เช่น ให้วิธีการหลอกลวง บังคับ ข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ต้องการค้นหรือเพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่ใช้ในการขอหมายค้น ดังที่ศาลในคดี R v. Walsh[19] ได้กล่าวถึงการความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำที่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายกับการคำนึงถึงเจตนาสุจริตหรือเจตนาทุจริตของเจ้าพนักงานไว้ว่า การกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดมาตรฐานความยุติธรรมในการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้สร้างขึ้นได้ถูกละเมิดเสียแล้ว ซึ่งการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญไม่อาจถูกลบล้างได้โดยความเชื่อโดยสุจริตของเจ้าพนักงาน ในทางตรงกันข้ามการกระทำโดยทุจริตของเจ้าพนักงานสามารถทำให้การกระทำที่ไม่ถือว่าละเมิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญกลายเป็นละเมิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและในสาระสำคัญได้ โดยยิ่งเจตนาทุจริตมีมากเพียงเพียงใด โอกาสที่ศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐานก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาถึงความทุจริตของเจ้าพนักงานแล้วในประเทศอังกฤษจะได้ผลอย่างเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถึงแม้ศาลได้ออกหมายค้นแต่หากความบกพร่องเกิดขึ้นจากความผิดของเจ้าพนักงาน ก็ไม่อาจอ้างพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นตามหมายนั้น ในทางตรงกันข้ามหากหมายค้นมีความบกพร่องอย่างมากเช่นออกโดยไม่มีเหตุในการออกหมายค้นเลย แต่เจ้าพนักงานสุจริต ศาลในประเทศอังกฤษอาจไม่รับฟังพยานหลักฐาน

---

[19] 91 Cr.App.R. 161

นั้นก็ได้หากเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้มาไม่มีคุณค่าในการพิสูจน์ความผิดของจำเลยมากนัก ในขณะที่ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะรับฟังพยานหลักฐานนั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าศาลไทยอาจนำหลักความสุจริตของเจ้าพนักงานมาใช้ในกรณีที่เจ้าพนักงานได้ทำการค้นตามหมายค้นที่บกพร่องซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดของเจ้าพนักงาน แต่การนำความสุจริตมาใช้จะต้องมีความเคร่งครัด โดยไม่รวมถึงกรณีที่แท้จริงแล้วไม่มีหมายของศาลแต่เป็นเรื่องที่ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการออกหมายผิดพลาดดังเช่นคดี Herring v. United States, 555 U.S. 135 (2009) ซึ่งโดยหลักเจ้าพนักงานจะต้องอ้างอิงตัวหมายในการใช้อำนาจค้นเสมอ เพราะหมายจะระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นกรอบการใช้อำนาจ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานเพียงแต่ค้นฐานข้อมูลพบชื่อ Herring แล้วทำการจับและค้นทันที ย่อมแสดงถึงว่าเจ้าพนักงานประมาทหรือมีเจตนาทุจริต ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรนำหลักความสุจริตมาเป็นข้อยกเว้นการไม่รับฟังพยานหลักฐานในกรณีดังกล่าว

(2) ความสุจริตของเจ้าพนักงานกับความรับผิดในทางอาญา

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการค้นโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะการค้นโดยไม่มีอำนาจทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย ทำให้เจ้าพนักงานมีความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล (ความผิดฐานบุกรุก) และความผิดว่าด้วยความบริสุทธิ์สะอาดของการใช้อำนาจรัฐ (ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ)

อย่างไรก็ตาม โดยที่ความผิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นความผิดที่ต้องการเจตนา ซึ่งสามารถนำหลักความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งหมายถึงการที่เจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริตใจและมีเหตุผลสมควรว่าตนมีอำนาจกระทำการค้น มาเป็นข้ออ้างที่ทำให้เจ้าพนักงานไม่ต้องมีความรับผิดในทางอาญาได้ โดยในการที่ศาลจะลงโทษจำเลย โจทก์จะต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยด้วยว่าไม่มีความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เจ้าพนักงานที่กระทำการโดยสุจริตอย่างแท้จริงจะได้รับการคุ้มครองจากความรับผิดในทางอาญาอย่างเต็มที่ ในขณะที่ แม้เจ้าพนักงานมีเจตนาทุจริตก็อาจไม่ได้รับการลงโทษเพราะได้รับการยกประโยชน์แห่งความสงสัย

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากการศึกษาหลักกฎหมายในเรื่องการค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย และหลักการค้นในที่รโหฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษแล้ว พบว่าในแต่ละประเทศต่างให้สำคัญกับการค้นในที่รโหฐาน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการค้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ (1) การค้นต้องกระทำโดยมีหมายค้นที่ออกโดยศาลเป็นหลัก ส่วนการค้นโดยไม่มีหมายเป็นเพียงข้อยกเว้น (2) การค้นต้องมีเหตุอันเป็นไปได้หรือเหตุอันควรเชื่อว่ามีบุคคลหรือพยานหลักฐานในที่รโหฐานนั้น (3) การค้นต้องเป็นไปเพื่อหาบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการค้น สำหรับเหตุในการออกหมายค้น เหตุในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมาย วิธีการในการค้น และขอบเขตของการค้นตามหลักกฎหมายในแต่ละประเทศมีความใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในแต่ละประเทศ ซึ่งการศึกษาถึงข้อแตกต่างเพื่อนำแนวทางเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลเป็นการส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่เป็นภาระหรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมจนเกินควร ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์ในเรื่องการค้นในที่รโหฐานต่อไป ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษได้ให้ความสำคัญกับหลักความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ และสัดส่วนระหว่างความเสียหายที่คาดหมายได้จากการใช้มาตรการดังกล่าวกับประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกระบวนการที่ทำให้การค้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

5.1.1 มาตรการที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

5.1.1.1 การจำกัดดุลยพินิจของเจ้าพนักงานในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐาน

การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 92 (4) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย เป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจอย่างมาก เนื่องจากพฤติการณ์ที่จะทำให้

เชื่อว่ามีพยานหลักฐานหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกำลังจะถูกโยกย้ายทำลาย ไม่ได้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแจ้งเช่นอนุมาตราอื่น ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนั้น ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้จำกัดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานซึ่งอาจนำมาปรับใช้เป็นกรอบในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานได้ ดังนี้

1. การใช้อำนาจค้นสถานที่ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานในความผิดที่ร้ายแรงซึ่งได้สัดส่วนกับการใช้มาตรการค้นโดยไม่มีหมาย

2. หากบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นไม่มีเหตุที่จะล่วงรู้ได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจพบการกระทำความผิดของตน ย่อมไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการทำลายพยานหลักฐาน

3. การโยกย้ายหรือทำลายพยานหลักฐานซึ่งเป็นเหตุให้ต้องทำการค้นโดยฉุกเฉินต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงาน

5.1.1.2 มาตรฐานเกี่ยวกับ “เหตุในการค้นที่รโหฐาน”

หลักการค้นที่รโหฐานตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอังกฤษต้องคำนึงถึงว่ามีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) หรือมีเหตุควรเชื่อ (reasonable grounds for believing) ว่ามีสิ่งของหรือบุคคลในที่รโหฐานนั้นซึ่งเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่เป็นเหตุในการออกหมายค้นหรือเป็นเหตุในการค้นโดยไม่มีหมายค้นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำการค้น เมื่อใดที่เหตุอันควรเชื่อหมดไปย่อมเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานหมดอำนาจในการค้นที่รโหฐานทันที นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วน หรือความเป็นไปได้ที่สังคมจะได้รับประโยชน์จากความสำเร็จในการค้นเกินกว่าผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้บริสุทธิ์นั้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยในการพิจารณา “เหตุที่เป็นไปได้” ในการค้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

5.1.1.3 ผลของหมายค้นที่บกพร่องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การค้นโดยไม่มีอำนาจซึ่งอาจนำไปสู่การที่ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มานั้น ได้แก่ การค้นโดยไม่มีหมาย การค้นโดยไม่มีเหตุที่จะค้นโดยไม่มีหมายค้น และการค้นในเวลากลางคืนโดยไม่มีอำนาจ อย่างไรก็ดี ในประเทศสหรัฐอเมริกายังได้พิจารณาถึงความบกพร่องของหมายค้น หรือ Defective Warrant ที่หากร้ายแรงถึงขนาดทำให้หมายค้นเสียไปแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นการค้นโดยไม่มีหมายค้น ซึ่งได้แก่ หมายค้นที่ออกโดยไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) และหมายค้นที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบ่งออกเป็น หมายค้นที่ไม่ระบุเจาะจงสถานที่ที่จะทำการค้น และหมายค้นที่ไม่ระบุเจาะจงสิ่งของที่ต้องการค้นหา สำหรับประเทศไทยไม่มีแนวคำวินิจฉัยว่าหมายค้นที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาของไทย มาตรา 60 (ค) ที่ได้บัญญัติว่า “ในกรณีออกหมายค้น ให้ระบุสถานที่ที่จะค้น และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล หรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น กำหนดวันเวลาที่จะทำการค้น และชื่อกับตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้นนั้น” และมาตรา 98 ที่บัญญัติไว้ว่า “การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น” จะมีผลให้หมายค้นนั้นเสียไป และการค้นตามหมายนั้นกลายเป็นการค้นโดยไม่มีอำนาจด้วยหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 98 (1) ที่ให้อำนาจศาลออกหมายค้นโดยไม่จำกัดสิ่ง ประกอบกับแนวคำพิพากษาฎีกาที่ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นตามหมายที่ระบุเลขที่บ้านผิดพลาด น่าจะต้องถือว่าระบบกฎหมายไทยไม่ได้ยึดถือหลักการค้นโดยไม่จำกัดสิ่งมาเป็นเหตุให้การค้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า การออกหมายค้นควรมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้บุคคลได้รับความคุ้มครองจากการค้นผิดสถานที่ หรือค้นเกินขอบเขตความจำเป็น ในขณะที่หากมีการโต้แย้งว่าหมายค้นไม่มีความเฉพาะเจาะจงก็ไม่ได้เป็นการขัดขวางกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐาน เพราะหากเจ้าพนักงานมีความสุจริตในการขอออกหมายค้นแล้ว ศาลก็สามารถรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้

5.1.2 **มาตรการที่ทำให้การค้นที่รโหฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ**

5.1.2.1 การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นกระทำได้โดยอาศัยเหตุเกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำความผิด

ตามกฎหมายต่างประเทศมีข้อยกเว้นเพื่อให้เจ้าพนักงานค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเพื่อจับกุมหรือเพื่อหาพยานหลักฐานเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในหลายกรณี ได้แก่ หลักการไล่ติดตามโดยกระชั้นชิด (Search in hot pursuit) ของสหรัฐอเมริกา ที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานค้นโดยไม่มีหมายได้เมื่อเป็นการไล่ติดตามบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ผู้ต้องหาตามหมายจับ หรือผู้ต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงกับคำให้การของผู้เสียหายที่เจ้าพนักงานย่อมเห็นประจักษ์แจ้งว่าเป็นบุคคลที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่จับกุมเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษต่างกำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานกระทำการค้นที่รโหฐานโดยไม่ต้องมีหมายค้นสืบเนื่องจากการจับกุมได้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ตัวเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น ตลอดจนป้องกันการทำลายพยานหลักฐานที่มักเกิดขึ้นทันทีที่บุคคลดังกล่าวรู้ตัวว่าจะถูกจับกุม หากแต่มีขอบเขตของพื้นที่ในการค้นที่รโหฐานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การค้นสถานที่ที่ผู้ถูกจับอยู่ในขณะจับกุมตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะจำกัดเฉพาะบริเวณรอบๆ ตัวผู้ถูกจับกุม ในขณะที่การค้นของประเทศอังกฤษกระทำได้โดยไม่จำกัดบริเวณในการค้น

5.1.2.2 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการค้นที่รโหฐาน

หลักสากลยึดถือว่าการค้นต้องกระทำในเวลากลางวัน เพื่อมิให้เป็นการรบกวนสิทธิในเคหสถานของบุคคลที่จะพักผ่อนนอนหลับโดยปกติสุข แต่ประเทศอังกฤษกำหนดช่วงเวลาให้มีความยืดหยุ่นโดยให้กระทำได้ในช่วงเวลา “ที่เหมาะสม” ซึ่งแม้ว่าโดยหลักจะหมายถึงการค้นในเวลากลางวัน แต่การค้นก็ยังสามารถทำได้ในเวลาที่สถานที่นั้นเปิดให้บริการแก่คนทั่วไป แม้จะเป็นเวลากลางคืน ซึ่งหมายถึงเวลาที่เหมาะสมกับสถานที่หรือบุคคลที่ต้องการทำการค้น

5.1.2.3 การยกเว้นหลักการแจ้งให้ทราบถึงการค้น

การใช้อำนาจค้นของเจ้าพนักงานต้องมีการแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในที่รโหฐานนั้นทราบเสมอ โดยการแจ้งให้ทราบต้องกระทำโดยทันทีที่ได้มีการค้น เพื่อให้ผู้ถูกตรวจค้นสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบรายการพยานหลักฐานที่ถูกพบในที่รโหฐานซึ่งจะใช้ในการพิสูจน์ความผิดของตนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกายินยอมให้ศาลออกหมายค้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของหมายทราบในทันทีได้ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความเร่งด่วนที่จะต้องทำการค้นกับความจำเป็นที่จะต้องให้การสอบสวนยังเป็นความลับ เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดร้ายแรงต่างๆ

5.1.2.4 การขยายขอบเขตในการค้น

การค้นที่รโหฐานตามกฎหมายไทยหากเข้าไปโดยอาศัยหมายค้นโดยไม่จำกัดสิ่งตามมาตรา 98 (2) แล้ว ย่อมขยายขอบเขตการค้นเพื่อยึดสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้เช่นเดียวกับหลักพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้งของประเทศสหรัฐอเมริกาและมาตรา 19 ของ PACE ตามกฎหมายอังกฤษ อย่างไรก็ดี เนื่องจากถ้อยคำว่า “มีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย” นั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะครอบคลุมถึงการยึดสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีอื่นๆ หรือการเข้าไปค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายตามมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยหรือไม่ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงเหตุผลตามมาตรา 92 (4) ซึ่งเป็นกรณีที่แม้ไม่มีหมายค้น แต่เจ้าพนักงานเชื่อว่ามีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกำลังจะถูกโยกย้ายทำลายแล้ว ก็ยังให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้าไปค้นและยึดได้ ดังนั้น เมื่อการขยายขอบเขตการยึดสิ่งของนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเข้าไปในที่รโหฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีการค้นทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาที่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไปกว่ากรอบการค้นเดิม และการยึดทรัพย์สินนั้นมีความจำเป็นในลักษณะเดียวกับมาตรา 92 (4) เนื่องจากหากไม่ยึดกลับไปในทันที สิ่งของนั้นย่อมเสี่ยงต่อการถูกโยกย้ายหรือทำลาย เจ้าพนักงานจึงสมควรมีอำนาจในการยึดสิ่งของที่พบโดยบังเอิญนั้นได้เช่นเดียวกับหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

5.1.2.5 ความสุจริตของเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ และเป็นเหตุให้ไม่ต้องมีความรับผิดในทางอาญา

ความสุจริตของเจ้าพนักงานหรือความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ซึ่งหมายถึงการที่เจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริตใจและมีเหตุผลสมควรว่าตนมีอำนาจกระทำการค้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำมาใช้ในการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการยกเว้นความรับผิดในทางอาญาที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักความสุจริต หรือ Good Faith ถูกมาใช้ยกเว้นเพื่อให้ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่หมายมีความบกพร่องซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของเจ้าพนักงาน และเจ้าพนักงานไม่รู้ถึงความบกพร่องของหมายนั้น ขอบเขตของหลักความสุจริตนี้จึงจำกัดว่าเป็นการคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานที่อยู่บนพื้นฐานการอ้างหมายที่ศาลเป็นผู้ออกเท่านั้น โดยไม่รวมไปถึงความเชื่อว่ามีเหตุอันเป็นไปได้ (probable cause) ที่ทำให้เจ้าพนักงานค้นได้โดยไม่มีหมายค้นในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานมีความสุจริตต่อเมื่อพิจารณาเหตุผลในทางภาวะวิสัยแล้ว (Objective Reasonable) เจ้าพนักงานอื่นๆ ที่มีเหตุผล มีความรู้ และได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะต้องเชื่อโดยสุจริตใจในผลของหมายค้นเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานผู้ทำการค้น ดังนั้น ในการรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบตามมาตรา 226/1 (3) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยที่ให้ศาลคำนึงถึง ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยมิชอบนั้น สมควรที่ศาลจะได้คำนึงถึงการที่เจ้าพนักงานมีความเชื่อโดยสุจริตใจในผลของหมายค้นที่มีความบกพร่องโดยมิใช่ความผิดของเจ้าพนักงานเช่นเดียวกัน

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลของการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน ดังต่อไปนี้

(1) โดยที่การใช้อำนาจค้นที่รโหฐานมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียวบังคับเหนือประชาชนในลักษณะเดียวกับการใช้อำนาจทางปกครอง แต่การใช้อำนาจในทางอาญามีผลกระทบต่อเนื้อตัวร่างกายของประชาชนโดยตรง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาในการออกหมายค้นหรือเจ้าพนักงานตำรวจในการใช้อำนาจเข้าตรวจค้นจึงต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในการควบคุมตรวจสอบโดยเคร่งครัดไม่น้อยไปกว่าการใช้อำนาจทางปกครอง โดยจะต้องเป็นไปตามหลัก

ความได้สัดส่วน หรือ Principle of Proportionality ซึ่งประกอบด้วย การเลือกใช้มาตรการที่สามารถทำให้วัตถุประสงค์ของการค้นสัมฤทธิ์ผลตามหลักความสัมฤทธิ์ผล (Principle of Suitability) โดยไม่มีมาตรการที่ผ่อนผันหรือร้ายแรงน้อยกว่าตามหลักความจำเป็น (Principle of Necessity) อีกทั้งมาตรการที่ใช้บังคับกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือรัฐมากกว่าโทษที่จะเกิดต่อบุคคลนั้นตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense)

(2) การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นเพื่อป้องกันการโยกย้ายทำลายพยานหลักฐานตามมาตรา 92 (4) เป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางจึงเสี่ยงต่อการที่เจ้าพนักงานจะใช้ดุลยพินิจโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการขอหมายค้นจากศาล จึงสมควรนำแนวทางการจำกัดดุลยพินิจตามคำพิพากษาศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวไว้ในบทสรุปมาประกอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน หรือการพิจารณาของศาลว่าการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานเป็นการค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นอกจากนี้ ในการค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายเพื่อจับกุมบุคคลนั้น นอกจากการกำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นตัวบุคคลตามมาตรา 85 แล้ว สมควรกำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจค้นบริเวณรอบๆ ตัวผู้ถูกจับกุมโดยไม่จำกัดว่าการจับกุมนั้นจะเกิดขึ้นในที่รโหฐานของผู้ถูกจับกุมหรือของบุคคลอื่นก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อตัวเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่น รวมถึงการทำลายพยานหลักฐาน และหากในการค้นนั้นพบพยานหลักฐานในการกระทำความผิดหรือสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดก็ให้เจ้าพนักงานสามารถยึดไว้ได้ ส่วนการค้นในบริเวณอื่นของสถานที่นั้นซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณที่มีการจับกุม เช่น การค้นห้องอื่นๆ หรือการค้นบ้านทั้งหลัง ตลอดจนการค้นที่รโหฐานที่ผู้ถูกจับกุมครอบครองภายหลังที่จับกุมผู้กระทำความผิดได้จากสถานที่อื่น ย่อมกระทำได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินในการค้นตามมาตรา 92 (4) อีกต่างหาก

(3) การขยายขอบเขตการค้นเพื่อยึดสิ่งของที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอำนาจค้นเดิมนั้น เห็นควรนำหลักการในเรื่องพยานหลักฐานที่ประจักษ์แจ้งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่าเจ้าพนักงานต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถพบสิ่งของนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อในทันทีว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นของที่ถูกขโมย หรือเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดนั้นหรือพยานหลักฐานในความผิดอื่นมาปรับใช้กับการขยายขอบเขตของการค้นตามมาตรา 98 ในกรณีที่เข้าไปค้นหาบุคคลหรือสิ่งของแล้วพบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างอื่นโดยบังเอิญ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า โดยหลักแล้วหมายค้นต้องระบุโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งสถานที่ที่จะทำการค้น และบุคคลหรือสิ่งของที่ต้องการค้น ส่วนการที่ศาลจะออกหมายค้นโดยไม่จำกัดสิ่งที่ค้นตามมาตรา 98 (1) สมควรพิจารณาว่าในกรณีนั้นมี

ความจำเป็นอย่างแท้จริงเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะพบสิ่งของหลายอย่างที่ยากต่อการระบุโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 60 (4) (ค) ที่บัญญัติว่าในกรณีออกหมายค้น ให้ระบุสถานที่ที่จะค้น และชื่อหรือรูปพรรณบุคคล หรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น กำหนดวันเวลาที่จะทำการค้น และชื่อกับตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้นนั้น

บรรณานุกรม

หนังสือ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2551.

_____. คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1. พิมพ์ครั้งที่ 9. พลสยาม พริ้นติ้ง : กรุงเทพมหานคร, 2551.

เข็มชัย ชุติวงศ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุงเทพมหานคร ; สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2551.

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2549.

_____. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2551.

คนึง ฦาไชย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

_____. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

จรัญ ภักดีธนากุล. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553.

จิรนิติ หะวานนท์. สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , 2543.

ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552.

ภาสกร ฌานสุธี. คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2552.

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2543.

วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551.

สมยศ เชื้อไทย. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2551.

หยุด แสงอุทัย. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคำพิพากษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บ้านการเรือน, 2507.

อนุมัติ ใจสมุทร, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยหลักทั่วไปตลอดถึงการไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 1 ถึงมาตรา 171 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2514.

บทความ

จิรนิติ หะวานนท์, “หลักการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ : เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอเมริกันและกฎหมายเยอรมัน,” ดุลพาห. ปีที่ 31. เล่ม 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2527) : 34-52.

ประดิษฐ์ เอกมณี. “ค้น. ” ดุลพาห. เล่ม 4. ปีที่ 44 (ตุลาคม-ธันวาคม 2540) : 120-135.

ประธาน วัฒนพานิช. “ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. ” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 9. ฉบับที่ 2. (กันยายน-พฤศจิกายน 2520) : 150-151.

วรวิทย์ ฤทธิทิศ. “สื่อมวลชนกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิในชีวิตส่วนตัว,” ดุลพาห. เล่มที่ 4. ปีที่ 39. (กรกฎาคม-สิงหาคม)

วิทยานิพนธ์

ชลลดา จินตเสถียร. “ข้อยกเว้นการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ ตามมาตรา 226/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. ” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, 2553.

ชูชีพ ปิณฑะศิริ. “การละเมิดสิทธิส่วนตัว.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.

ธิติ สายเชื้อ. “พยานหลักฐานตามสมควรในการที่ศาลจะออกหมายค้น.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549.

ฐานิศร์ วรรณสุข. “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา : ศึกษากรณีสิ่งซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย. ” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ณรงค์ ใจหาญ. “ความสำคัญผิดในเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจทำได้. ” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.

มโน ซอศรีสาคร. “การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ ค้น ยึด โดยมิชอบ : ศึกษาเฉพาะกรณีพยานวัตถุและพยานเอกสาร. ” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.

ศิริกุล ภู่พันธ์. “ข้อความคิดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

เอกสารอื่น ๆ

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เรวัต ฉ่ำเฉลิม และคณะ. “รายงานการวิจัย เรื่อง เหตุให้มีอำนาจจับและค้น.” สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. “โครงการวิจัย เรื่อง การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด.” สำนักงานศาลยุติธรรม, พฤษภาคม 2551.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 130/2544).

สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

Books

David H. Flaherty. Privacy Edition. Privacy and Data Protection : An International Bibliodraphy. NewYork : Knowledge Industry Publication Inc, 1984.

H. Morley Swingle. Search and Seizure Law in Missouri. Missouri : Missouri Association of Prosecuting Attorneys, 2009.

Leonard Jason-Lloyd. An Introduction to Policing and Police Powers. Great Britain : Cavendish Publishing, 2000.

M.D. A. Freeman. The Police and Criminal Evidence Act 1984. London : Sweet & Maxwell, 1985.

Maurizio Passerrin d' Entreves & Ursula Vogel Editor. Public and Pravate : Legal political and philosophical perspectives. New York : Routledge, 2000.

Volker Krey, German Criminal Procedure Law. Stuttgart Germany : W. Kohlhammer, 2009.

Articles

Aminie Woolworth. "The Good Faith Exception: "What is It Good for?" The Michigan Supreme Court Overturns Twenty Years of Precedent Holding It was Worth "Absolutely Nothing." U. Det. Mercy L. Rev. 83. 441. (summer 2006) : 441-478.

Arturas Panomariovas, Egidijus Losis. "Proportionality : From the Concept to the Procedure." the Jurisprudence of University of Wroclaw., 2. 120. (2010) : 258-272.

Craig S. Lerner. "The Reasonableness of Probable Cause." George Mason Law & Economics Research Paper No. 05-18; Texas Law Review. Vol. 81. No. 4 : 981-984.

Kit Kinports. “Diminishing Probable Cause and Minimalist Search.” Ohio State Journal of Criminal Law Vol 6. 649 (2009) : 653-655.

The Alameda County District Attorney's Office. “Exigent Circumstances.” point of view. volume 38. Number 1. (winter 2010) : 1-23.

_____. “Plain View ” point of view. volume 36. Number 4. (Fall 2008) : 11-16.

_____. “Search Incident to Arrest” point of view volume 36 Number 2 (winter 2005) : 1-11.

Timothy P. O’Neill. “Lawyers’ Forum : Scope of ‘probable cause’ probably will widen.” Chicago Daily Law Bulletin (Friday, May 9, 2003) : 6.

Other Materials

Delaware court. “Legal Memorandum 02-264 : Nighttime Search Warrant,” <http://courts. delaware. gov/ legal%20memoranda/List.aspx>.

Leonard Jason-Lloyd. An Introduction to Policing and Police Powers Great Britain : Cavendish Publishing, 2000. “Chapter Updates for Police Powers of Arrest 1/12/2006.” <http://www.routledgelaw.com/textbooks/ 9781859417058/updates/4. asp>.

Michael J. Bulzomi. “Knock and Announce : A Fourth Amendment Standard. ” The FBI Law Enforcement Bulletin (May, 1997) <http://www2.fbi.gov/publications/leb/1997/may976.htm.>.

The Crown Prosecution Service. “Misconduct In Public Office. ” <http://www.cps.gov.uk/legal/l_to_o/misconduct_in_public_office/>.

The U.S. Government Printing Office. "4th Amendment US Constitution-Search and Seizure," <www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con015 .pdf>

U.S. Department of Justice. "Delayed notice search warrant : A Vital and Time-Honored Tool for Fighting Crime," 2004. <http://www.justice.gov/dag/patriotact213 report.pdf>.

Vinesh Basdeo. "A Constitutional Perspective of Police Powers of Search and Seizure in the Criminal Justice System" master ' s thesis. University of South Africa, 2009.

ประวัติการศึกษา

ชื่อ	นางสาวประภัสสร ประกอบแก้ว
วันเดือนปีเกิด	10 กรกฎาคม 2527
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549
	เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 59 พ.ศ. 2550 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่ง	นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา